

République du Sénégal

Un Peuple - Un But - Une Foi

Primature



■ **Autorité de Régulation des Marchés publics** ■

GUIDE D'APPLICATION

du décret 2014-1212 du
22 septembre 2014 portant
CODE DES MARCHES PUBLICS



GUIDE D'APPLICATION

DU DECRET 2014-1212 DU 22 SEPTEMBRE 2014 PORTANT

CODE DES MARCHES PUBLICS

Mot du Directeur général



Suite à l'adoption du nouveau Code des marchés publics par décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014, l'ARMP a procédé à la finalisation d'un guide interprétatif dont l'objectif principal est de rappeler les différentes modalités et conditions d'application dudit code et des textes juridiques subséquents.

Il s'agit d'une initiative de l'ARMP consistant à mettre à la disposition des acteurs de la commande publique un instrument visant à expliciter la réglementation en vigueur. En effet, en sa qualité de régulateur du système national de gestion des marchés publics, l'ARMP met l'accent sur l'efficacité des procédures de passation des marchés, passe nécessairement par une correcte application par les différents acteurs.

Lesquels doivent, en conséquence, être suffisamment outillés et disposer des informations les plus complètes sur ces dernières. Il n'est plus à démontrer que les marchés publics sont des instruments privilégiés de développement économique et social, eu égard, entre autres, aux montants importants qu'ils impliquent et aux opportunités de création d'emplois qu'ils induisent.

L'opportunité d'une telle initiative est avérée, en raison des défis majeurs qui traversent les marchés publics et les délégations de service public, requérant en effet célérité et qui induisent diligence, expertise et efficacité. L'atteinte de ces objectifs ne peut être atteinte sans un système de gestion des marchés publics adossé à des procédures exhaustives dans leur contenu et explicites dans leur signification, facilement accessibles et correctement appréhendées par les différents acteurs, dont il est attendu une bonne maîtrise desdites procédures ainsi qu'un engagement sans faille à leur bonne application.

La commande publique met en jeu des fonds publics dont les règles d'utilisation doivent reposer sur les principes de la bonne gouvernance. A cet égard, la célérité, l'efficacité et la transparence requises sont tributaires du niveau de compréhension et de respect, par chacun des intervenants, des procédures mises en place et des délais impartis pour leur exécution.

Ainsi, nous mettons entre les mains des acteurs de la commande publique le présent guide interprétatif des marchés publics et délégations de service public, qui revêt une importance capitale dans le dispositif législatif et réglementaire de gestion des marchés publics, puisqu'il a vocation à ne laisser subsister aucune zone d'ombre ni à minimiser les risques liés à l'incertitude et à l'approximation dans l'interprétation des dispositions juridiques.

Le Directeur général
Saer NIANG

Note de présentation

La révision du cadre réglementaire des marchés publics préconisée par le plan d'actions issu de la revue analytique du système de passation des marchés (CPAR) avait généré un nouveau texte réglementaire en la matière : le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 qui a abrogé et remplacé le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics.

Ce texte consolidait les acquis de la réglementation antérieure qui avait introduit un certain nombre d'innovations :

- il procurait une sécurité juridique renforcée s'appuyant sur un Code des Obligations de l'Administration (COA) modifié pour prendre en compte les mutations observées dans les normes internationales en matière de passation de marchés publics ;
- il s'appuyait également sur la réglementation communautaire en matière de marchés publics, notamment les directives n° 04/2005/CM/UEMOA et n° 05/2005/CM/UEMOA. La première de ces directives porte sur les procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Quant à la deuxième, elle traite du contrôle et de la régulation de ces deux catégories de contrats publics dans le même espace communautaire.

Mais quelques années après l'adoption du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011, les pouvoirs publics sénégalais ont constaté *« des difficultés pour les autorités contractantes de mener à bien leurs procédures de passation de marchés et partant, d'absorber les crédits mis à leur disposition, en raison notamment de la lourdeur desdites procédures »*.

Ce constat a conduit à l'adoption du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant nouveau Code des marchés publics, lequel abroge le décret du 27 juillet 2011 précité.

Le nouveau Code couvre un champ d'application plus étendu, englobant désormais les marchés passés par certaines agences qui bénéficiaient jusqu'ici de régimes dérogatoires en matière de passation de marchés. Il consacre enfin la mise en place de nouvelles structures qui, combinées à de nouvelles règles de procédures, donnent naissance à un système intégré doté d'une dynamique propre.

Aux fins d'assurer la vulgarisation des réformes et de garantir un fonctionnement adéquat des nouvelles Commissions des marchés publics, il importe que tous les intervenants du système de passation de la commande publique aient une même interprétation de ces différentes réformes des marchés publics et des différents textes d'application pris dans ce secteur. Le présent guide a pour objet de rappeler les conditions d'application des textes en vigueur en matière de marchés publics. A cet effet, il met un accent particulier sur :

- les modifications opérées sur le cadre institutionnel de la passation, du contrôle et de la régulation des marchés ;
- l'extension du champ d'application de la réglementation ;
- la notion d'accord-cadre ;
- la nécessité de réaliser des études préalables et de veiller à une bonne programmation des marchés ;
- les modalités de la planification ;
- la problématique du financement des marchés et de l'existence de crédits et autorisations préalables ;
- la durée du contrat et la programmation du financement ;
- le contenu des dossiers d'appel d'offres ;
- les différents modes de passation des marchés ;
- les nouveautés concernant les commissions de passation des marchés ;
- les modalités d'application du régime des préférences ;
- les délais réglementaires de passation des marchés ;
- le régime des offres spontanées ;
- la conservation des documents (registre infalsifiable, documents de projets).

En outre, il rappelle le dispositif de sanctions en cas de violation de la réglementation des marchés publics.

Le présent guide se réfère ainsi à ces deux directives précitées mais aussi à d'autres normes telles que les directives BIRD et IDA en matière de passation des marchés publics, sans oublier l'Accord de l'OMC sur les marchés publics ou encore la loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés de biens, de travaux et de services.

Il est impératif de prendre connaissance des dispositions contenues dans les textes d'application (arrêtés et circulaires) du Code des marchés publics pour garantir une mise en œuvre intégrale du dispositif réglementaire des marchés publics.

LISTE DES ABREVIATIONS

AAPC	Avis d'Appel public à la Concurrence
ARMP	Autorité de Régulation des Marchés publics
BIRD	Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement
CCAG	Cahier des Clauses Administratives générales
CCAP	Cahier des Clauses Administratives particulières
CDBF	Cour de Discipline budgétaire et financière
CMP	Code des marchés publics
CNCA	Commission nationale des Contrats de l'Administration
CNUDCI	Conférence des Nations Unies pour le Droit commercial international
COA	Code des Obligations de l'Administration
CPAR	Revue analytique du système de passation des marchés
CRD	Comité de Règlement des Différends
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DCMP	Direction centrale des Marchés publics
DSP	Délégation de service public
IDA	International Development Association
MOD	Maîtrise d'Ouvrage délégué
NINEA	Numéro d'Identification nationale des Entreprises et Associations
ORMP	Observatoire régional des Marchés publics
PME	Petites et moyennes entreprises
PMI	Petites et moyennes industries
PRM	Personne Responsable du Marché
SAPPM	Société anonyme à Participation publique majoritaire
SN	Société nationale
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
CPM	Cellule de passation des marchés

TABLE DES MATIERES

I. DEFINITIONS ET PRINCIPES	15
I.1 Les définitions - les marchés publics et délégations de service public	16
I.2 Le Code des marchés publics et les principes de la commande publique	18
I.2.a Le renforcement de la transparence dans la passation des marchés publics	18
I.2.b La recherche d'une plus grande efficacité dans la passation des marchés publics	18
I.2.c La protection renforcée du principe de l'égalité des chances dans le choix de l'attributaire du marché public	18
I.2.d La lutte contre la pratique anticoncurrentielle dite du « dumping »	18
I.2.e La promotion de l'éthique dans la passation des marchés publics	19
II. QUELQUES NOUVEAUTES MAJEURES APPORTEES PAR LE NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS	20
II.1 Les changements à caractère institutionnel	21
II.1.a L'organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics	21
II.1.b L'organe de régulation et de contrôle a posteriori des marchés publics	21
II.1.c Les Commissions des marchés publics	22
II.1.d Les Cellules de contrôle de la passation des marchés publics	23
II.2 Les changements à caractère opérationnel	25
II.2.a La mise en place d'un système d'information fiable	25
II.2.b L'allègement des procédures	26
II.2.c Les marchés passés par certaines communes	26
II.2.d La dispense de forme écrite pour certaines commandes	27
II.2.e La dispense de contrôle préalable par la DCMP	28
II.2.f L'institution de voies de recours pour tous les acteurs de la commande publique	30
II.3 Changements apportés en matière de maîtrise d'ouvrage	31

III.1 Au plan institutionnel**34**

III.1.a L'Etat et ses services déconcentrés, organismes ou agences non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité 34

III.1.b Les collectivités locales et leurs services déconcentrés, les organismes ou agences non dotés de la personnalité morale, placés sous leur autorité y compris les groupements mixtes et les établissements publics locaux visés respectivement par les articles 283 et 236 de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales 34

III.1.c Les établissements publics 35

III.1.d Les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, (...) dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général 35

III.1.e Les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire 35

III.1.f les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) à e) de l'article 2.1 du code des marchés publics 36

III.2 Au plan matériel**37**

III.2.a Les délégations de maîtrise d'ouvrage et les marchés passés par les délégataires de maîtrise d'ouvrage 37

III.2.b Les marchés passés en application d'accords de financement ou de traités internationaux sous réserve de l'application de dispositions contraires résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux 37

III.2.c Les contrats portant participation des cocontractants des personnes publiques à l'exécution d'un service public 37

Dispositions dérogatoires 38

III.2.d Les acquisitions aux enchères publiques effectuées par le service du mobilier national 38

III.2.e Les acquisitions effectuées par les missions diplomatiques et consulaires 39

III.2.f Les services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance juridique et de représentation juridique 39

III.2.g Les services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert des titres ou d'autres instruments financiers 39

III.2.h les contrats de travail 40

III.2.i L'achat de carburant destiné aux véhicules de l'Administration 40

III.2.j L'achat de titres de transport aérien ou maritime 41

III.2.k	L'hébergement et la restauration des participants, dans les réceptifs hôteliers ou les structures ayant une telle vocation, à l'occasion de l'organisation de sommets officiels, de séminaires ou ateliers	41
III.2.l	Les opérations d'acquisition ou de location de terrains, bâtiments et autres biens immobiliers	
III.2.m	Les opérations de sponsoring	41
III.2.n	Les opérations de publication par voie de presse d'insertions publicitaires et les publiereportages par voie audiovisuel	43
III.2.o	Les médicaments et produits essentiels utilisés dans la médecine d'urgence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé	43
III.2.p	L'acquisition de médicaments et produits pharmaceutiques essentiels par les services et formations sanitaires	44
III.3	La notion d'Autorité contractante	44
III.3.a	Autorité contractante et personne morale de droit privé	45
III.3.b	Autorité contractante et service décentralisé	45
III.3.c	Autorité contractante et Personne Responsable des Marchés	45
III.4	Les Autorités contractantes déconcentrées	45
IV.	LES ORGANES DE LA COMMANDE PUBLIQUE	46
IV.1	Les organes de passation	47
IV.1.1	Les cellules de passation des marchés	47
IV.1.2	Les Commissions des marchés	48
IV.1.2.a	L'ancrage institutionnel et les missions des Commissions des marchés	48
IV.1.2.b	Composition et nombre de représentants de l'Autorité contractante dans les Commissions des marchés	48
IV.1.3	Positionnement de la PRMP vis-à-vis des autres organes de passation des marchés	52
IV.1.4	Durée du mandat des membres de la Commission des marchés	52
IV.1.5	Règles applicables en matière de conflits d'intérêt	53
IV.2	Les organes de contrôle	53
IV.2.1	L'organe de contrôle a priori de la passation des marchés	54
IV.2.1.a	Seuils de contrôle	54
IV.2.1.b	Avis et autorisations	54

IV.2.1.c Réserves	55
IV.2.1.d Délais de contrôle	56
IV.2.1.e Désaccords entre l'Autorité contractante et la DCMF	57
IV.2.2 L'organe de régulation et de contrôle a posteriori	57
V. LES REGLES DE PREPARATION DES MARCHES PUBLICS	58
V.1 La définition des besoins	59
V. 2 La planification de la passation des marchés	60
V.2.a Les plans de passation des marchés	60
V.2.b La publicité des opérations de planification	60
V.2.c Les règles applicables en matière de révision des plans	62
V.3 L'allotissement du marché	62
V.4 L'élaboration de documents types de passation de marchés	63
V.5 Les critères de qualification	64
V.6 La question des crédits budgétaires préalables	67
VI. LES FORMALITES DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS	69
VI.1 Le respect des délais des procédures de passation des marchés	70
VI.1.a Pour les candidats et soumissionnaires	70
VI.1.b Pour les Autorités contractantes	70
- Au stade préalable à l'ouverture des offres	
- Au stade de l'évaluation	
- Au stade de l'approbation du choix de la Commission des marchés	
- Au stade de la signature du marché	
- Au stade de l'approbation	
- Au stade de la notification	
- Au stade de la publication de l'avis d'attribution définitive	
VI.2 L'obligation de fournir les documents relatifs à la passation aux autorités compétentes	71
VI.3 Les formalités de publicité	72
VI.3.a Comment procéder à la publication des appels d'offres ?	72
VI.3.b Le support de la publication	72
VI.3.c La spécificité de la publicité pour les marchés des communautés rurales	73

VI.3.d	Prise d'effet des délais de publication	73
VI.3.e	La publication électronique des avis	73
VI.4	Présentation de quelques procédures de passation de marchés publics	74
VI.4.1	Les modalités de mise en œuvre de la manifestation d'intérêt	74
VI.4.1.a	La mise en œuvre de la publication de l'avis à manifestation d'intérêt	75
VI.4.1.b	Le contenu de l'avis à manifestation d'intérêt	75
VI.4.1.c	L'établissement de la liste restreinte	75
VI.4.2	La limitation des participants pour les appels d'offres restreints	76
VI.4.3	Une nouveauté du Code : les marchés passés suite à une offre spontanée	77
VI.4.4	Réduction des délais d'appel d'offres	79
VI.4.5	Les difficultés d'application de l'article 52 du Code des marchés publics	79
VI.4.6	L'interprétation des dispositions portant sur les marchés par entente directe	81
VI.4.6.a	L'urgence impérieuse	82
VI.4.6.b	Les notions de secret et d'intérêt supérieur de l'Etat	84
VI.4.6.c	Les marchés classés secret	84
VI.4.7	Les modalités de conclusion des marchés de clientèle	86
VI.4.8	Les marchés à commande	88
VI.4.9	Les marchés à tranches conditionnelles	89
VI.4.10	Les marchés afférents à des programmes d'investissement, d'entretien et de maintenance d'équipements complexes	90
VI.4.11	L'institution d'une nouvelle catégorie de procédure : les accords-cadres	90
VI.4.12	le cas des marchés de fournitures par crédit-bail	91
VI.4.13	Le cas des marchés de fournitures par location-vente	92
VI.4.14	Les marchés de gestion et d'entretien par niveau de services (GENIS)	92
VI.4.15	La procédure de demande de renseignements et de prix	93
VI.4.16	La suppression de la procédure de l'adjudication	96
VI.5	Les exigences vis-à-vis des candidats et fournisseurs	96

VI.5.1 L'exigence de production des pièces administratives aux seules entreprises nationales en cas d'appel d'offre international	96
VI.5.2 L'attestation de qualification et de classement des entreprises	97
VI.5.3 Le délai de production des pièces justificatives	98
VI.5.4 L'interdiction des soumissions concertées	98
VI.5.5 La lettre de soumission	98
VI.5.5.a Les mentions de l'acte de soumission	98
VI.5.5.b Les rabais	99
VI.5.6 Les garanties	99
VI.5.6.a Les conditions d'agrément	99
VI.5.6.b Les différents types de garantie et leur montant	99
- La garantie de soumission	
- La garantie de restitution d'avance	
- La garantie de bonne exécution	
- La retenue de garantie	
VI.5.7 Contenu de l'acte d'engagement	102
VI.6 La réception et le traitement des candidatures et offres	102
VI.6.1 La présentation et la sécurisation des offres	102
VI.6.1.a La présentation des offres	102
VI.6.1.b La sécurisation des offres	103
VI.6.2 Les formalités liées à l'ouverture des plis pour les marchés de travaux, de fourniture, de service et de prestations intellectuelles	103
VI.6.2.a Commission des marchés et commission interne de dépouillement	103
VI.6.2.b Le rejet des plis hors délais	104
VI.6.2.c L'organisation de la séance d'ouverture	104
VI.6.2.d L'établissement d'un procès verbal d'ouverture des plis	104
VI.6.3 La possibilité de procéder au rejet de l'offre pour cause d'absence de garantie de soumission au moment de l'ouverture des plis	105

VI.6.4 Règles applicables en matière de participation des entreprises publiques	105
VI.6.5 Application de la combinaison économiquement la plus avantageuse en matière d'allotissement	106
VI.6.6 L'examen de la variante	106
VI.6.6.a Modalités de présentation	106
VI.6.6.b Modalités d'évaluation	107
VI.6.6.c Les options	107
VI.6.7 Les offres anormalement basses	107
VII. SIGNATURE ET APPROBATION DES MARCHES PUBLICS	109
VII.1 La signature des contrats	110
VII.2 L'approbation des contrats	110
VII.2.1 Les autorités compétentes	110
VII.2.1.a Pour les marchés de l'Etat	110
VII.2.1.b Pour les marchés des collectivités locales	110
VII.2.1.c Pour les marchés des établissements publics, agences et autres organismes visés à l'article 2.1 d) ;	110
VII.2.1.d Pour les marchés des SN et des SAPPM	110
VII.2.1.e En cas d'avenants	110
VII.2.2 Les délais d'approbation	111
VII.2.3 La prise d'effet de l'approbation	111
VIII. LES REGLES EN MATIERE D'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS	113
VIII.1 Le prix du marché	114
VIII.1.1 Les incoterms	114
VIII.1.2 Le contrôle des prix du marché	114
VIII.2 Le règlement du prix du marché	115
VIII.2.1 Le versement d'avances aux titulaires de marchés publics	115
VIII.2.1.a Le montant des avances	115
VIII.2.1.b Le remboursement des avances	116
VIII.2.2 Le versement d'acomptes aux titulaires de marchés publics	117
VIII.2.3 Les délais de paiement	117
VIII.2.3.a Le droit à paiement	117

VIII.2.3.b	Le délai de constatation du droit à paiement	117
VIII.2.3.c	Le délai de paiement des acomptes	118
VIII.2.3.d	Les intérêts moratoires en cas de retard	118
VIII.2.4	Les règles de paiement des sous-traitants	118
VIII.2.4.a	Les conditions préalables	118
VIII.2.4.b	Le droit au paiement direct	118
VIII.2.5	: Le nantissement des créances nées du marché	119
VIII.3	Les modifications au cours de l'exécution du marché	120
VIII.3.1	Les modifications relatives au prix	120
	La révision du prix	
	- Eléments déclencheurs de la révision	
	- Formule de révision	
	L'actualisation du prix	
VIII.3.2	Les modifications relatives aux prestations	123
VIII.3.2.a	Les avenants	123
VIII.3.2.b	Les ordres de services	124
VIII.3.2.c	Les marchés complémentaires	125
VIII.4	Les incidents d'exécution du marché public	125
VIII.4.1	L'ajournement	125
VIII.4.2	La résiliation	126
VIII.4.3	La force majeure	129
VIII.4.4	La substitution d'entreprise	130
VIII.5	La fin des prestations	130
VIII.5.1	Le procès verbal de réception des prestations	130
VIII.5.2	Le classement et l'archivage des dossiers de marchés	131

IX. LES REGLES DU CONTENTIEUX DES MARCHES PUBLICS	132
IX.1 Les recours dans la procédure de passation de marché	133
IX.2 Les procédures de dénonciation	135
IX.3 Les consignations	136
IX.4 Les délais	136
IX.5 Le Contrôle et les sanctions des irrégularités commises dans la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de service public	137
IX.5.1 Les sanctions visant les actes	138
IX.5.1.1 Contrôle et sanctions de la légalité des actes en matière de marchés publics par le juge de l'excès de pouvoir	138
IX.5.1.2 Contrôle et sanctions des irrégularités à la procédure de passation des marchés publics par le CRD	139
IX.5.1.3 Contrôle de la Cour des comptes	140
IX.5.2 Le contrôle et les sanctions visant les personnes	140
IX.5.2.1 Contrôle et sanctions prononcées par le CRD	140
IX 5.2.2 Contrôle et sanctions par les juridictions judiciaires et administratives	141
IX.5.2.2.a Les sanctions prononcées par les juridictions pénales	141
IX.5.2.2.b Les sanctions prononcées par les juridictions administratives	141
IX 5.2.3 Sanctions prononcées par la Chambre de discipline budgétaire de la Cour des comptes	142
ANNEXE : AVIS ET DECISIONS DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS CITES	145



I. DEFINITIONS ET PRINCIPES



I.1 Les définitions

La notion de marché public

Un marché public désigne un contrat conclu à titre onéreux par une Autorité contractante avec un tiers pour répondre à ses besoins en matière de travaux, fournitures et services.

Un marché public présente donc plusieurs caractéristiques : la présence d'un contrat, conclu avec un tiers, son objet et son caractère onéreux.

- Un marché public est un contrat

Les marchés publics sont des contrats. Ils consacrent ainsi un accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique : l'Autorité contractante et son cocontractant.

- Un contrat à titre onéreux

Le caractère onéreux exprime l'idée d'un prix que l'Autorité contractante doit verser à son cocontractant en rémunération de sa prestation. Ce critère lié au « *prix* » exclut des marchés publics certaines opérations, notamment les subventions que les collectivités publiques peuvent accorder à des opérateurs privés. En effet, cette notion de « *subvention* » constitue une contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l'intérêt général mais qui est initiée et menée par un tiers. Il s'agira d'une subvention si l'initiative du projet vient de l'organisme bénéficiaire et si aucune contrepartie directe n'est attendue par la personne publique du versement de la contribution financière. Cette notion d'initiative implique non seulement l'impulsion du projet, mais aussi sa conception et sa définition.

De même, les prestations que la personne publique obtient à titre gratuit ne peuvent jamais être qualifiées de marchés publics.

Ce critère du prix distingue le marché public du contrat de délégation de service public pour lequel la rémunération du cocontractant est principalement assurée sur le produit de l'exploitation du service délégué.

- Un contrat devant avoir un objet bien déterminé

Un marché public est un contrat qui doit répondre aux besoins de l'administration en matière de fournitures, de services ou de travaux. L'objet du marché est un élément fondamental qui doit être précisément défini en vue de répondre à un besoin de la personne publique.

Ces caractéristiques expliquent donc que les dispositions du Code des marchés publics ne sont pas applicables dans les cas suivants :

- accords-cadres, marchés et services ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, bâtiments existants ou autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le contrat d'acquisition ou de location, entrent dans le champ d'application du Code des marchés publics¹ ;
- accords-cadres et marchés ayant pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à être diffusés dans les media.

¹Cette question a été traitée dans le présent guide.

Tableau reprenant les éléments de distinction entre marché public et DSP

Type de contrat		Objet	Financement	Paielement	Risques d'exploitation
Marché public		Fourniture de biens, services ou travaux	Fonds publics	Autorité contractante	Autorité contractante
Délégations de service public	Concession	Investissement et exploitation d'un service public	Concessionnaire	Par les usagers, au profit du Concessionnaire : perception de redevances en fonction des résultats de l'exploitation	Concessionnaire
	Affermage	Exploitation d'un service public pour son propre compte, moyennant des redevances à verser à l'Autorité concédante	Autorité concédante	Par les usagers, au profit du fermier : perception de redevances	Fermier
	Régie intéressée	Exploitation d'un service public pour le compte de l'administration	Autorité concédante	Par l'Autorité concédante qui verse au délégataire une prime fixée en pourcentage du chiffre d'affaires complétée d'une prime de productivité et éventuellement par une part des bénéfices. Les tarifs payés par les usagers sont collectés par le délégataire mais reversés à l'Autorité concédante	le Régisseur pour l'essentiel

I.2 Le nouveau Code des marchés publics et les principes de la commande publique

I-2-a : Le renforcement de la transparence dans la passation des marchés

La transparence dans la passation des marchés suppose, entre autres, la disponibilité en temps utile de l'information en amont et en aval du lancement des consultations ; cette exigence se traduit par l'obligation faite aux Autorités contractantes, non seulement de publier par des canaux appropriés et dans les délais requis, les informations relatives aux opérations de passation de marchés, mais aussi de satisfaire les requêtes des candidats en matière de transmission d'informations.

I-2-b : La recherche d'une plus grande efficacité dans la passation des marchés publics

Le nouveau Code des marchés publics introduit des innovations majeures allant dans le sens d'un accroissement de l'efficacité des procédures. En effet, les acquisitions de biens et services ainsi que la réalisation de travaux, doivent être effectuées avec la plus grande célérité pour permettre à l'Etat de répondre, dans des délais acceptables, à ses obligations de service public.

I-2-c : La protection renforcée du principe de l'égalité des chances dans le choix de l'attributaire du marché public

Les dispositions de l'article 40.1 du Code des marchés publics sont introduites pour lutter contre le favoritisme, pratique qui porte atteinte à la libre concurrence. Aux termes de cet article, *« Toute personne qui a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants un intérêt direct ou indirect, notamment en tant que dirigeant, associé ou employé, dans une entreprise candidate à un marché examiné par la commission à laquelle elle appartient, doit en faire la déclaration, se retirer de la commission et s'abstenir de participer à toutes opérations d'attribution du marché considéré »*.

Cette disposition sur les conflits d'intérêts est déterminante dans le traitement égalitaire des candidats et soumissionnaires.

L'article 40.1 du Code des marchés publics vient en complément du dernier alinéa de l'article 38 du même code qui précise que *« les membres des comités techniques d'étude et d'évaluation des offres ainsi que les experts sont tenus aux mêmes obligations de déclaration de conflit d'intérêt et de secret que les membres des commissions des marchés »*.

Cette même obligation est applicable également à tout agent qui intervient dans les procédures de marchés publics. La déclaration de conflits d'intérêt est à renouveler chaque année.

I-2-d : La lutte contre la pratique anticoncurrentielle dite du « dumping »

Cette pratique anticoncurrentielle peut être notée sur un marché *« intérieur »*, comme sur celui dit *« international »*.

Le dumping interne, axé sur le marché intérieur, vise à éliminer la concurrence. Il désigne la pratique consistant à vendre un produit à un prix « cassé » parfois inférieur même au coût de revient des produits vendus. Le dumping international est destiné à écouler des surplus sur les marchés extérieurs, faute de demande interne. Il consistera donc, pour une entreprise ou pour un Etat, à vendre un produit déterminé moins cher à l'étranger que sur le marché intérieur. Cette définition est applicable, par exemple, à une entreprise qui réside en dehors de l'espace UEMOA et qui propose une offre dans le cadre d'une mise en concurrence à l'initiative d'une Autorité contractante sénégalaise.

Il est arrivé à plusieurs reprises, qu'un marché soit attribué à un soumissionnaire alors que le prix proposé par ce dernier se situe largement en deçà du coût normal des prestations prévues.

Bien que dans pareils cas, l'Administration se trouve exposée au risque de non exécution des prestations, elle ne pouvait écarter le candidat concerné faute de base légale pouvant fonder sa décision de rejet.

En vertu des dispositions de l'article 59.4 du Code des marchés publics, de telles offres peuvent dorénavant être écartées par la Commission des marchés, à condition que le caractère anormalement bas du prix par rapport à la réalité économique soit reconnu par la majorité des membres de ladite commission et après que le soumissionnaire concerné ait été invité à justifier le niveau de son offre

I-2-e : La promotion de l'éthique dans la passation des marchés publics

Face aux importants enjeux qui s'attachent aux marchés publics et qui ont pour noms «bonne gouvernance», «*crédibilité de l'Etat*» et «*contrôle citoyen*», il importe d'inciter tous les acteurs impliqués dans le processus de passation et d'exécution, à observer des règles d'éthique spécifiques.

A cet effet, il a été élaboré une charte de transparence et d'éthique adoptée par décret n° 2005-576 du 22 juin 2005. Ce texte définit les conduites individuelles et collectives à tenir pour assurer la transparence et l'efficacité dans la passation des marchés publics, en même temps qu'il rappelle les types de contrôle à exercer par les organes et les personnes compétents, ainsi que les sanctions applicables en cas de faute.

En application du point f) de l'article 44 du Code des marchés publics, parmi les renseignements que doit fournir tout candidat à un marché public, figure « *une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des dispositions de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics adoptée par décret et qu'il s'engage à les respecter* ».

Pour imprimer durablement cette direction dans les comportements, le décret visé ci-dessus décide que la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics fait obligatoirement partie des annexes de tout dossier d'appel d'offres.

L'arrêté n°00861 du 22 janvier 2015 fixe le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de cette Charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics.

En outre, la promotion de l'éthique dans la passation des marchés publics implique que tout agent public de l'Autorité contractante intervenant dans les procédures de marchés publics, tout membre de la Commission des marchés ou des comités techniques d'étude et d'évaluation soient tenus à une obligation de déclaration de conflit d'intérêt renouvelable chaque année.



II. QUELQUES NOUVEAUTES MAJEURES APPORTEES PAR LE NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS

Les changements apportés par la nouvelle réglementation sont évoqués dans le rapport de présentation du Code des marchés publics. Il s'agit ici de les passer en revue d'une manière plus détaillée afin d'en faciliter la compréhension et la mise en œuvre.

II.1 Les changements à caractère institutionnel

(Article 30 nouveau du Code des obligations de l'administration et Articles 138 à 145 du Code des marchés publics).

En application des directives de l'UEMOA en la matière, et conformément aux objectifs du Country Procurement Assessment Report (CPAR), le domaine des marchés publics a connu des mutations profondes s'étant traduites notamment par la mise en place de nouveaux organes chargés du contrôle et de la régulation des marchés publics.

II.1.a : L'organe de contrôle a priori de la passation des marchés

Par décret n° 2007-547 du 25 avril 2007 (modifié), un organe administratif a été créé au sein du Ministère de l'Economie et des Finances sous la dénomination de Direction centrale des Marchés publics (DCMP). La DCMP est chargée principalement d'assurer le contrôle a priori des procédures de passation de marchés publics, d'émettre des avis sur les décisions concernant l'attribution des marchés publics et d'accorder, à la demande des Autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur. La conséquence immédiate de cette restructuration a été la suppression de la Commission nationale des Contrats de l'Administration.

La DCMP occupe une position stratégique dans le nouveau dispositif de la réforme du système des marchés publics en assurant la publication des plans de passation des marchés publics, la régularité des procédures et dossiers d'appel d'offres, l'autorisation d'utiliser certaines procédures spécifiques et l'octroi de dérogations y afférentes.

La DCMP assure une mission de conseil aux Autorités contractantes et assure la gestion d'un système d'information au profit des acteurs de la commande publique.

La DCMP dispose de services déconcentrés qui sont dénommés « pôles régionaux ».

Les modalités d'exécution de ses missions sont étudiées dans la partie du guide consacrée au contrôle des marchés publics.

Aussi il sera décliné la mission de conseil et de gestion de système d'information de la DCMP, sans oublier les prérogatives de ses services déconcentrés (pôles régionaux).

II.1.b : L'organe de régulation et de contrôle a posteriori

La fonction de régulation du système est assurée par l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) qui est une structure administrative indépendante dotée d'une autonomie financière et de gestion. Les missions de l'ARMP s'articulent autour du principe qui vise à séparer les fonctions de contrôle a priori des marchés publics (conférées à la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d'intervenir sur l'ensemble du secteur, à travers des missions d'assistance dans l'élaboration des politiques ou des documents standards, mais aussi dans le cadre de la formation des acteurs, du règlement des litiges et du contrôle à posteriori.

Elle a été créée par le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 qui en fixe l'organisation et le fonctionnement. Elle est composée de trois organes que sont : le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des Différends et la Direction générale.

De tous ces organes, c'est le Conseil de Régulation qui dispose des pouvoirs les plus étendus.

Il est régi par les articles 5 à 17 du décret instituant l'ARMP. Il a pour fonction principale l'administration de l'ARMP, la définition et l'orientation de sa politique générale et l'évaluation de sa gestion. Quant à sa composition, il faut retenir que le Conseil de Régulation est un organe tripartite de neuf (9) membres représentant, sur une base paritaire, l'Administration publique, le Secteur privé et la Société civile.

La durée de leurs mandats est de trois ans renouvelables une fois. Ils sont astreints à un devoir d'impartialité et de neutralité dans l'exécution de leurs fonctions.

Quant au CRD, il est régi par les articles 18 à 23 du décret précité. Selon les termes même de l'article 20 de ce texte, le CRD est chargé de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public.

En outre, toujours en application de cette même disposition, il reçoit et enregistre les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu'à leur exécution. Il siège ainsi soit sous la forme d'une Commission Litiges, soit en Formation disciplinaire.

Sa composition est déterminée comme suit par le décret :

- le président du Conseil de Régulation (qui en assure la présidence) ;
- un autre membre parmi les représentants de l'Administration ; selon l'article 18 du décret instituant l'ARMP, au moins un des membres de l'Administration doit être un magistrat ;
- deux membres appartenant l'un au secteur privé et l'autre à la société civile, désignés par le Conseil de Régulation.

Après étude des recours, le CRD peut :

- tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur les irrégularités et violations des réglementations communautaires et nationales qu'il constate ;
- ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l'exécution de la procédure de passation ; l'attribution définitive du marché étant suspendue jusqu'au prononcé de la décision de la Commission des litiges ;
- rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges relatifs à l'exécution des marchés publics et délégations de service public.

Enfin, le troisième organe qu'est la Direction générale de l'ARMP est dirigé par un Directeur général, recruté sur appel d'offres par le Conseil de Régulation. Cet organe est régi par les articles 24 à 32 du même décret. Son mandat est de trois ans renouvelable une fois.

Il est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'ARMP sous le contrôle du Conseil de Régulation à qui il rend compte de sa gestion. Il est assisté d'un secrétariat particulier et d'un service administratif et financier.

Mais, dans ses fonctions stricto sensu, il est assisté par trois directions que sont :

- la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques ;
- la Direction de la Formation et des Appuis techniques ;
- la Direction des Statistiques et de la Documentation.

D'autres changements à caractère institutionnel ont également été introduits, notamment au niveau des Commissions des marchés.

II.1.c : Les Commissions des marchés

Les Commissions des marchés sont constituées au niveau des Autorités contractantes énumérées à l'article 2 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics.

Les textes spécifiques à prendre en compte pour bien appréhender les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions des marchés sont :

- les articles 35 et 40 du Code des marchés publics,
- l'arrêté n° 00861 du 22.01.2015, fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics pris en application de l'article 44-F du Code des marchés publics,
- l'arrêté n° 00862 du 22.01.2015 relatif aux commissions régionales et départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar, pris en application de l'article 36-7 du Code des marchés publics, relatif aux commissions régionales et départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar pris en application de l'article 36, alinéa 7 du code des marchés publics.

Quelle que soit leur Autorité contractante de rattachement, ces commissions sont chargées de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des marchés. Elles sont appuyées dans l'exécution de leurs tâches par des cellules de passation des marchés.

L'article 36.alinéa 4 du Code des marchés donne à l'Autorité contractante la possibilité de mettre sur pied une commission spécifique pour un marché particulier lorsque la nature ou l'importance des prestations le justifient. L'appréciation des conditions pour la mise en place d'une telle commission est du ressort de l'Autorité contractante. A titre d'illustration, cette option est appropriée dans la passation des marchés relatifs à des projets internationaux pilotés par un comité interétatique selon des procédures prescrites dans des conventions internationales ou des protocoles. Dans tous les cas, les modalités de constitution d'une commission spécifique à un marché particulier ne doivent pas déroger aux dispositions pertinentes du Code des marchés publics.

II.1.d : Les Cellules de contrôle de la passation des marchés publics

Les cellules de passation sont évoquées à l'article 35 du Code des marchés publics. La lecture de cette disposition doit être complétée par l'examen de la circulaire du Premier Ministre en date du 28 décembre 2007 (0005 PM) qui leur est consacrée. Les missions des cellules de passation des marchés publics sont précisées par l'arrêté n° 865 du 22-01-2015 pris en application des articles 35 et 141 du Code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes.

Ces cellules sont chargées de :

- l'examen préalable des dossiers d'appel à la concurrence, des rapports d'analyse comparative des offres, des procès-verbaux d'attribution provisoire et des projets de contrat pour les marchés dont les marchés dont les montants n'ont pas atteint les seuils de revue de la DCMP ;
- l'examen préalable de tout document à soumettre à l'Autorité contractante en matière de marchés publics ;
- l'examen préalable de tout document à transmettre à des tiers en matière de marchés publics ;
- l'examen préalable de tout document à signer avec des tiers en matière de marchés publics ;
- le classement et l'archivage de tous les documents relatifs aux marchés publics passés par les différents services ;
- l'établissement, en début d'année, du plan consolidé annuel de passation des marchés de l'Autorité contractante ;
- l'établissement de l'Avis général de passation des marchés et sa publication conformément aux articles 6 et 56 du Code des marchés publics ;
- l'insertion des avis et autres documents relatifs à la passation des marchés dans le système national informatisé de gestion des marchés ;
- la tenue du secrétariat de la Commission des marchés ;
- l'appui aux différents services pour les opérations de passation de marchés ;
- la réalisation et la tenue de tableaux de bord sur les délais de mise en œuvre des différentes étapes des procédures de passation des marchés et de réalisation des calendriers d'exécution des marchés ;

- l'identification des besoins de formation des services en matière de marchés publics ;
- la liaison avec les missions extérieures, notamment celles d'audit des marchés, initiées par l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;
- l'établissement de rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés à l'intention des autorités compétentes pour transmission à la Direction centrale des Marchés publics et à l'Autorité de Régulation des Marchés publics ; l'établissement, avant le 31 mars de chaque année, à l'intention de l'autorité dont elles relèvent, de l'ARMP et de la DCMP d'un rapport annuel sur l'ensemble des marchés passés au cours de l'année précédente.

Ces cellules assurent de fait au sein des Autorités contractantes un contrôle qualité des procédures de passation des marchés. Ce contrôle est impératif avant toute transmission aux autorités signataires, de contrôle ou d'approbation.

Mais il convient de retenir que pour les procédures visées aux articles 64 et 65 du Code des marchés publics (consultation préalable d'un organe de contrôle avant de déclarer la procédure infructueuse ou de ne pas y donner suite), cette compétence des cellules s'efface devant celle de la DCMP. C'est aussi le cas pour les demandes d'avis, préalablement au recours à une procédure dérogatoire à l'appel d'offres ouvert.

Dans ces différents cas, quand bien même les prestations envisagées par l'Autorité contractante n'atteindraient pas les seuils de procédures formalisées, le contrôle préalable est de la compétence de la DCMP.

Au sein des départements ministériels et des collectivités locales, les responsables des cellules de passation des marchés sont nommés par arrêtés pris par le ministre de tutelle ou tous autres actes appropriés.

Conformément aux termes de la circulaire prise par le Premier Ministre, ces cellules doivent être mises en place conformément aux directives ci-après :

- au sein des départements ministériels disposant de Secrétariat général, la cellule de passation de marchés est placée sous la tutelle directe du Secrétaire général ;
- au sein des départements ministériels ne disposant pas de Secrétariat général, la cellule de passation de marchés est directement rattachée au Cabinet du Ministre ;
- au sein des collectivités locales, les cellules de passation des marchés sont placées, selon le cas, sous la tutelle directe des secrétaires général ou municipal ; ou de l'organe exécutif en cas de non existence du poste de secrétaire ;
- au sein des établissements publics, sociétés nationales, sociétés à participation publique majoritaire et agences de droit public dotées de la personnalité morale, les structures déjà existantes chargées de la passation des marchés peuvent être conservées sous réserve de s'assurer que leurs attributions incluent les activités qui sont ciblées par l'arrêté susvisé du Ministre chargé des Finances.

Tout comme pour les membres de la Commission des marchés, les copies de nomination et leurs déclarations, avant leur prise de service, valant engagement à respecter le décret n°2005-576 du 22 juin 2005 portant charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics, doivent être transmises à la DCMP et à l'ARMP.

II.2 Les changements à caractère opérationnel

Les changements principaux à caractère opérationnel introduits dans le processus de passation des marchés sont les suivants :

II-2.a : La mise en place d'un système d'information fiable

La création du portail www.marchéspublics.sn constitue l'une des innovations majeures du nouveau système. Ce site est un dispositif informatique destiné à la diffusion complète et régulière de toute l'information disponible en amont et en aval de la passation de marchés. Pour satisfaire cette exigence de premier ordre, les dispositions des articles 56 et 57 du Code des marchés publics fixent de façon non exhaustive, les types d'informations à mettre à disposition dans le système.

Celui-ci revêt un caractère statique relatif à la publication et dynamique qui concerne les interactions possibles entre les candidats et les autres acteurs du processus.

Le portail des marchés publics du Sénégal est un site Web qui offre une porte d'entrée sur une large gamme de ressources et de services centrés sur les activités de l'ARMP et de la DCMP.

Cette plateforme est destinée aux fournisseurs et tout autre acteur intéressé par les marchés publics passés par les différents ministères, collectivités locales, sociétés nationales, sociétés à participation publique majoritaire, agences, etc.

Le système d'information assure une gestion globale des marchés publics et comprend deux espaces qui sont accessibles selon la qualité des acteurs :

- le Front-office ou espace public, destiné au grand public et visible à travers le portail Web des marchés publics ;
- le Back-office ou espace privé réservé aux Autorités contractantes, à la DCMP et à l'ARMP. Il offre aux Autorités contractantes une plateforme centrale de gestion des plans de passation de marchés (PPM) et de traitement des dossiers.

Le système est configuré pour permettre à chaque entité de publier la liste des membres de sa Commission des marchés et de sa Cellule des marchés ainsi que ses avis d'appel d'offres, avis généraux de passation de marchés, avis d'attribution etc...

En ce qui concerne les plans de passation de marchés, les Autorités contractantes les élaborent et les transmettent à la DCMP au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée (et au plus tard le 30 avril de l'année budgétaire considérée pour les communes ayant un budget initial inférieur à 300 millions de F CFA) ; celle-ci se chargera de leur publication dans le portail après la vérification de leur conformité et leur validation. Cette publication devra intervenir dans les trois (03) jours francs qui suivent la réception du Plan.

L'ARMP quant à elle alimente le site en publiant toutes les données relatives aux réclamations, aux décisions du CRD, décrets, circulaires et directives.

A cet effet, plusieurs espaces lui sont destinés. Il s'agit de :

- l'espace législation qui regroupe l'ensemble des textes réglementaires relatifs aux marchés publics ;
- l'espace réservé aux documents types pour l'élaboration des DAO ;
- l'espace «actualités» et qui regroupent les informations pertinentes, rapports d'activités, rapports d'audits, etc.

Ce portail offre ainsi au public une interface multimodale, lui permettant d'accéder à toutes les informations pertinentes relatives aux procédures de passation des marchés publics

Il est à retenir que les listes des membres des commissions et des cellules ne font pas encore l'objet de publication. En effet, cet aspect n'a pas pu être dématérialisé du fait de la signature de l'attestation de la charte de transparence.

II.2.b : L'allègement des procédures

Avec la nouvelle réglementation, certaines procédures de marchés publics sont allégées en raison soit de la nature de l'Autorité contractante, soit du montant des prestations.

Cet allègement des procédures est ainsi consacré dans plusieurs domaines :

- les marchés passés par certaines communes (arrêté n° 00863 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 79 du Code des marchés publics, relatif aux procédures applicables aux marchés passés par certaines communes);
- la dispense de forme écrite pour certaines commandes (arrêté n°00107 du 07-01-2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignement et de prix en application de l'article 78 du Code des marchés publics);
- la dispense de contrôle préalable par la DCMP pour les marchés se trouvant en dessous de certains seuils (arrêté n° 00106 du 07-01-2015) fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de marché, pris en application de l'article 141 du Code des marchés publics).

La lecture de ces différents articles devra nécessairement être complétée par celle des arrêtés pris pour leur application, lesquels apportent des précisions et autres éclaircissements utiles aux Autorités contractantes.

II.2.c : Les marchés passés par certaines communes

L'allègement des procédures pour les marchés passés par ces catégories d'Autorités contractantes est prévu à l'article 79 du Code des marchés publics qui précise que *«Les marchés passés par les communes dont le budget ne dépasse pas un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, peuvent faire l'objet de procédures allégées, comportant en particulier des formalités de publicité et des cahiers des charges adaptés (...)»*.

Ainsi, en application de l'alinéa 1er de l'arrêté n° 00863 du 22 janvier 2015 précité, sont concernés par cet allègement, les marchés passés par les communes dont le budget annuel initial est inférieur à 300 millions de francs CFA, à condition qu'ils soient imputables audit budget.

L'attention des Autorités contractantes est attirée sur deux points : le premier est que même si le budget de la commune est inférieur à 300 millions de francs CFA mais que le marché envisagé n'est pas imputable à celui-ci, il ne sera pas fait application de l'article 79 du code des marchés publics. C'est le cas par exemple des marchés financés par un partenaire au développement ou par l'Etat, dans le cadre d'un programme national de développement.

Le second point sur lequel l'attention des communes est attirée est que même si elles se trouvent dans les critères définis à cet article 79 et son décret d'application, elles peuvent choisir de ne pas faire application de la procédure dérogatoire. En effet, à l'examen de l'article 79 précité, le recours aux procédures adaptées est une faculté, et pas une obligation.

Cette disposition doit toujours être interprétée en prenant en compte le contenu de l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances pris pour son application.

Ces allègements tiennent compte également de la volonté de faciliter l'accès des PME locales aux marchés de leur localité.

- Pour la passation des marchés de travaux de montants estimatifs inférieurs à 50 millions FCFA TTC, ainsi que des marchés de fournitures et services (à l'exclusion des marchés de prestations intellectuelles) de montants estimatifs inférieurs à 25 millions FCFA TTC, les communes concernées peuvent procéder à une publicité allégée qui s'affranchit des règles normales de mise en concurrence posées par le Code des marchés publics. Concrètement, elles publient par affichage public, à la fois au niveau de leurs sièges, de ceux des préfectures dont elles relèvent, et des chambres de métiers couvrant leurs localités, les avis généraux et spécifiques de passation de marchés, ainsi que les avis d'attribution provisoire et définitive.

Les accusés de réception ou décharges des bordereaux de transmission de demande d'affichage adressés aux structures énumérées ci-dessus font foi aux fins d'attestation de la date de publication effective des avis précités.

- S'agissant des renseignements et justifications requis des candidats aux marchés, les communes concernées, peuvent exonérer les candidats de l'obligation de produire les documents suivants : l'attestation de la Caisse de Sécurité sociale, celle de l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), celle des services chargés des recouvrements fiscaux et celle de l'inspection du Travail, pour tout marché dont le montant est inférieur à 25 millions FCFA TTC.

- Il est par ailleurs procédé à une réduction à trois, du nombre minimum de candidats à consulter dans le cadre d'une demande de renseignements et de prix simple ou à compétition restreinte pour les marchés de travaux, fournitures et services pour tenir compte du nombre peu élevé d'entreprises intervenant au niveau local.

Enfin, dans leurs procédures de passation des marchés, les communes dont le budget est inférieur à 300 millions de FCFA peuvent, sauf dispositions contraires, utiliser tout document simplifié officiel de passation de marchés.

L'arrêté n° 863 a pour objectif de dynamiser l'initiative locale notamment en facilitant le déclenchement de la procédure des marchés se situant en dessous d'un certain seuil mais aussi, et surtout, en facilitant l'accès des PME locales aux marchés.

II.2.d : La dispense de forme écrite pour certaines commandes

Cette dispense est instituée par l'arrêté n° 107 précité du 7 janvier 2015, pris en application de l'article 78 du Code des marchés publics relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix.

Ce dispositif précise que les commandes répondant aux conditions suivantes peuvent ne pas donner lieu à des formes écrites et faire l'objet de règlement sur mémoires ou factures :

TYPE DE PROCEDURE DE DRP A APPLIQUER ↓	SEUILS ↓
La demande de renseignements et de prix simple	• travaux d'un montant estimatif inférieur à 5 millions de francs CFA toutes taxes comprises ; • prestations intellectuelles d'un montant estimatif inférieur à 5 millions de francs CFA toutes taxes comprises; • fournitures ou services d'un montant estimé inférieur à 3 millions de francs CFA toutes taxes comprises

L'objectif recherché à travers ce plafonnement des cumuls est d'encourager les Autorités contractantes à recourir le plus possible à des consultations par le regroupement des commandes.

II.2.e : La dispense de contrôle préalable par la DCMF

Cette dispense est précisée par les dispositions de l'arrêté n° 00106 du 07-01-2015 pris en application de l'article 141 du Code des marchés fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de marchés.

Afin de bien mettre en exergue l'allègement des procédures sur ces différentes questions, il convient de procéder à un raisonnement à contrario pour souligner qu'en dessous de certains seuils, les Autorités contractantes n'ont pas à observer ces formalités.

Les tableaux suivants résument le contenu de cet arrêté afin de rendre celui-ci plus lisible.

Tableau des seuils de dispense d'examen préalable par la DCMF des dossiers de marché

LES AUTORITES CONTRACTANTES	LES SEUILS EN FONCTION DU TYPE DE MARCHE
Pour l'Etat, y compris ses services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité, les collectivités locales y compris leurs services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous leur autorité, les groupements mixtes et les établissements publics locaux, ainsi que pour les établissements publics :	- marchés de travaux inférieurs à 300 000 000 F CFA ; - marchés de fournitures inférieurs à 200 000 000 F CFA ; - marchés de services et prestations intellectuelles inférieurs à 150 000 000 F CFA.
Pour les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général.	- marchés de travaux inférieurs à 400 000 000 F CFA ; - marchés de fournitures inférieurs à 250 000 000 F CFA ; - marchés de services et prestations intellectuelles inférieurs à 200 000 000 F CFA.
Pour les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire	-marchés de travaux inférieurs à 600 000 000 F CFA ; -marchés de fournitures inférieurs à 400 000 000 F CFA -marchés de services et prestations intellectuelles inférieurs à 250 000 000 F CFA.
Pour les marchés passés par les associations formées par ces personnes morales	-le seuil relatif à la nature du marché à passer applicable à l'autorité contractante désignée comme coordonnateur ; -si un coordonnateur est désigné en dehors des autorités contractantes composant l'association ou si un coordonnateur n'est pas formellement désigné, le seuil le plus élevé parmi ceux applicables aux autorités contractantes composant l'association pour la nature du marché à passer.

En fonction des Autorités contractantes, si le marché se trouve en dessous de ces seuils, le dossier d'appel à la concurrence est dispensé d'un examen préalable par la DCMP.

En application du parallélisme des formes, à chaque fois que le dossier d'appel à la concurrence sera dispensé de ce contrôle préalable, il en sera de même du rapport d'analyse comparative d'offres ou de propositions, du procès-verbal d'attribution provisoire et du projet de marché. Mais également, dès lors que le dossier d'appel à la concurrence aura fait l'objet de revue a priori, il en sera de même de tous les autres éléments ci-avant listés, quel que soit leur montant.

Toutefois, les dispenses de contrôle préalables ne doivent pas empêcher les Autorités contractantes concernées d'être rigoureuses sur ces procédures, d'ailleurs objet de contrôle qualité au niveau interne par la Cellule de contrôle de la passation des marchés. Ainsi, en cas d'avis défavorable sur des dossiers d'appel à la concurrence, rapports d'analyse comparative des offres, procès-verbaux d'attribution provisoire ou projets de contrats, la personne responsable des marchés ne pourra poursuivre la procédure qu'après avis favorable de la DCMP.

Concernant la portée des prérogatives de la CPM pour les marchés n'atteignant pas les seuils de revue de la DCMP, il est précisé que c'est la DCMP qui se chargera d'émettre des avis sur les décisions de déclarer sans suite ou infructueux les procédures d'appels d'offres ouvert (article 64 et 65 du CMP).

Par ailleurs, même si les prestations envisagées n'atteignent pas les seuils de revue par la DCMP, celle-ci demeure compétente pour donner un avis préalable à l'utilisation des procédures dérogatoires à l'appel d'offres ouvert. Cette intervention préalable et systématique de l'organe de contrôle est aussi applicable aux marchés dites à « *exécution fractionnée* » : les marchés à commande, de clientèle, à tranches). En définitive, il importe de retenir que l'allègement des procédures ne signifie pas pour autant une liberté totale sur ces étapes de la passation des marchés publics. En effet, en cas d'irrégularités, le CRD peut tout de même être saisi par toute personne qui y a intérêt.

II-2.f : L'institution de voies de recours pour tous les acteurs de la commande publique

Il n'y avait pas dans le code de 2002 institué par le décret n° 2002-550 du 30 mai 2002 un mécanisme clair, précis, indépendant et efficace en matière d'attribution (avec une procédure formalisée assortie de délais de réponse) au moyen duquel les acteurs de la commande publique pouvaient introduire un recours.

Dans la continuité des Codes de 2007 et 2011, les dispositions des articles 138 et suivants du nouveau Code des marchés publics, reprenant l'article 31 du Code des Obligations de l'Administration modifié (COA) ont mis fin à cette faiblesse du système en instaurant un instrument véritable de recours aussi bien pour les candidats, les soumissionnaires que pour les titulaires et les Autorités contractantes tant en matière d'attribution que d'exécution des marchés publics.

A chaque étape de la procédure de passation de marché, le Code des marchés prescrit à l'Autorité contractante des obligations assorties de délais, en matière de transmission d'informations aux candidats mais aussi aux autres acteurs que sont la DCMP et l'ARMP.

De la même manière, les candidats qui s'estiment lésés disposent de délais bien établis par le Code pour introduire des recours. Il est donc important pour chaque acteur, de s'enquérir des délais qui lui sont impartis pour exercer ses droits.

En tout état de cause, le nouveau Code statue sur le sort réservé à toute action initiée par un acteur en dehors des délais prescrits.

Les recours sont portés devant le CRD, organe de l'ARMP. Ils s'inspirent largement des procédures contentieuses avec un délai de saisine, des moyens et des prétentions à exposer devant le CRD qui peut prendre, selon la nature des faits qui lui sont exposés, des décisions correctives ou disciplinaires, ainsi que des avis en matière d'exécution.

En outre, le Code des marchés publics admet la possibilité pour les personnes physiques ou morales qui y ont intérêt et qui n'ont pas eu satisfaction devant l'autorité de régulation, de saisir la chambre administrative de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne les litiges relatifs aux marchés des Sociétés nationales et des SAPPm qui eux, relèvent des tribunaux de droit commun (article 139 du CMP).

II.3 : Changements apportés en matière de maîtrise d'ouvrage

En traitant des notions de « maîtrise d'ouvrage » et de « maîtrise d'ouvrage déléguée », le nouveau Code des marchés (tout comme les anciens textes de 2007 et 2011) comble un vide laissé par les précédents textes.

Pour rappel, le Maître d'Ouvrage (MO) est la personne morale mentionnée à l'article 2 du Code des marchés publics pour le compte de laquelle la prestation est effectuée. Il a pour rôle, entre autres, de déterminer la localisation de l'ouvrage, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les fournitures, études et travaux projetés.

Le Maître d'Ouvrage peut confier à une personne de droit public ou privé qui prend alors la dénomination de « Maître d'Ouvrage délégué » (MOD) ou « Mandataire », tout ou partie de ses attributions relatives notamment aux activités de préparation, de passation et d'exécution du marché. L'article 31 du Code des marchés publics dispose à cet effet :

« L'autorité contractante peut déléguer tout ou partie de ses attributions relatives à la passation et à l'exécution de marchés concernant la réalisation :

- 1. d'ouvrages, de bâtiments ou d'infrastructures, y compris la fourniture de matériels et équipements nécessaires à leur exploitation ;*
- 2. de programmes d'intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes, comprenant un ensemble de travaux, fournitures et services.*

Les règles de passation des marchés utilisées par le mandataire de l'Autorité contractante dénommé Maître d'Ouvrage délégué sont celles qui s'appliquent à l'Autorité contractante, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte de l'intervention du Maître d'Ouvrage délégué ».

Le Maître d'Ouvrage ne peut déléguer ses pouvoirs qu'aux entités suivantes :

- les personnes morales et organismes mentionnés à l'article 2.1 du Code des marchés publics;
- les personnes publiques ou privées auxquelles est confiée la réalisation de programmes ou de projets financés sur fonds d'aide extérieure ou agréées par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis de l'ARMP.

Une convention de MOD ne peut être passée en principe qu'au terme d'un appel public à la concurrence, en application de l'article 80 du Code des marchés publics.

Toutefois, certaines structures peuvent exercer du fait des dispositions réglementaires qui les régissent, des missions de MOD au profit de leur ministère de tutelle. Dans ces cas, la procédure de sélection par appel d'offres est sans objet, dès lors le MOD s'impose au MO, en vertu d'un texte réglementaire.

Il convient de rappeler à ce propos, qu'aux termes des circulaires n° 13/PM/SGG du 12 mars 1971 et n° 007/PR/SG du 11 mars 1987, la maîtrise d'ouvrage des travaux de bâtiments publics et l'administration des crédits y afférents, sont du ressort de la Direction de la Construction, service relevant du Ministère chargé de la Construction.

D'ailleurs, les relations contractuelles entre une Autorité contractante et une entité placée sous sa tutelle ne sont pas régies par les dispositions du Code des marchés publics.

Toutefois, ces deux parties ne peuvent se passer de l'obligation de conclure une convention.

La convention de MOD doit contenir les dispositions suivantes, sous peine de nullité :

- l'ouvrage ou le projet qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées au Maître d'Ouvrage délégué, les conditions dans lesquelles l'autorité contractante constate l'achèvement de la mission du Maître d'Ouvrage délégué, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
- le mode de financement des fournitures, services ou travaux ainsi que les conditions dans lesquelles le Maître de l'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
- les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par l'autorité contractante aux différentes phases de l'opération, y compris les phases de la réalisation marché qui sont soumises à l'approbation préalable de celle-ci.

Le MOD est tenu de respecter l'enveloppe financière définie par le Maître d'Ouvrage ; il assumera la responsabilité de tout dépassement. A l'inverse, le Maître d'Ouvrage assumera la responsabilité des dépassements résultant de ses propres carences.

Tout ou partie des attributions suivantes sont exercées par le MOD au titre de la convention signée avec le Maître d'Ouvrage :

1. *définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage ou le projet concerné sera exécuté ;*
2. *organisation et conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du projet jusqu'à l'attribution provisoire ;*
3. *signature des marchés après approbation du choix du titulaire par l'Autorité contractante ;*
4. *gestion des marchés passés au nom et pour le compte de l'Autorité contractante ;*
5. *paiement ou autorisation des paiements aux titulaires des marchés ;*
6. *réception de l'ouvrage ou du projet ;*
7. *accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.*

Ces attributions sont énumérées à l'article 32 du Code des marchés publics.

Tout acte accompli par le MOD relativement au projet concerné doit strictement relever des attributions ci-dessus énumérées ; c'est en substance le sens de l'avant dernier alinéa de l'article 32 du Code des marchés publics « le Maître d'Ouvrage délégué n'est tenu envers l'Autorité contractante que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celle-ci ».

La convention de MOD doit prévoir de manière explicite un système permanent de suivi et de contrôle qui exige l'approbation de l'Autorité contractante pour tout acte important.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention, le MOD est assujéti aux obligations suivantes :

- mise en place d'une Commission et d'une Cellule de passation des marchés constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du CMP ;
- sélection des candidats et attribution des marchés selon les dispositions pertinentes du CMP.



III. LE CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS



III.1 Au plan institutionnel

Le Code des marchés publics s'applique aux marchés conclus par les Autorités contractantes suivantes :

III.1.a : l'Etat et ses services déconcentrés et les organismes ou agences non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité

Le concept « *Etat* » regroupe la Présidence, la Primature, les ministères, le Pouvoir judiciaire et les organes de représentation nationale, en l'occurrence l'Assemblée Nationale et le Conseil économique, social et environnemental.

Les dispositions du règlement intérieur de ces institutions ne sauraient être interprétées comme autorisant la moindre dérogation aux dispositions du Code des marchés publics.

L'Etat, dans son système organisationnel et selon les secteurs d'activités, crée des agences ou organismes non dotés de la personnalité morale. Ce défaut de personnalité morale n'empêche pas l'application du CMP pour les marchés passés par ces agences et organismes qui agissent au nom et pour le compte de l'Etat. Il en est ainsi pour le FONGIP (Fonds de Garantie des Investissements prioritaires) créé par le décret n° 2013-691 du 17 mai 2013 et dont la soumission au Code des marchés publics a posé un débat à un moment donné. Cet organisme, comme toutes les autres agences de l'Etat placés sous son autorité, est effectivement soumis au Code des marchés publics comme le précise son article 2.

III.1.b *les collectivités locales, leurs services déconcentrés, organismes non dotés de la personnalité morale, placés sous leur autorité y compris les groupements mixtes et les établissements publics locaux visés respectivement par les articles 283 et 236 et de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales.*

Les collectivités locales au Sénégal regroupent les communes et les départements. Ces entités qui sont dotées de la personnalité morale et ayant à leur tête des organes élus chargées de la gestion d'affaires locales, sont soumises au Code des marchés publics. En outre, pour des raisons d'efficacité économique et de coopération entre ces collectivités locales, ces dernières peuvent créer des groupements. Ces derniers sont dotés de la personnalité morale.

A ce sujet, l'article 16 du Code des collectivités locales précise que «*Les collectivités locales peuvent entreprendre, suivant des modalités fixées par décret, des actions de coopération entre elles, avec l'Etat ou toute autre structure appropriée en vue de la promotion et de la coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques*».

En outre, l'alinéa 2 de l'article 283 du même Code dispose que «*Les collectivités locales peuvent s'associer pour l'exercice des compétences d'intérêt commun, conformément à l'article 279 du présent code, en créant des organismes publics de coopération*».

Comme exemple de groupement de collectivités locales, on peut citer les communautés d'agglomération. Les collectivités locales confient certains projets communs à ces entités dont la formation doit être autorisée par la loi. Par conséquent, il est tout à fait logique que ces groupements, du fait de leur objet, soient également soumis au Code des marchés publics.

Les établissements publics locaux sont également soumis au Code des marchés publics. Un établissement public local est un organisme public créé par une collectivité locale, doté d'une personnalité morale et spécialisé dans un secteur bien précis. Ce secteur peut relever de l'éducation, de l'économie ou encore du social.

III.1.c : Les établissements publics

A l'instar des établissements publics locaux, ceux à vocation nationale ont la personnalité morale, des organes propres et un secteur spécial d'activités. Pour leurs marchés, ils sont soumis aux dispositions du Code. Comme exemple d'établissement public, on peut citer notamment, les universités, la Caisse des dépôts et des consignations, l'IFAN, l'IPRES, etc.

III.1.d : Les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, (...) dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général

La soumission de ces entités au Code des marchés publics permet d'éviter que des services de l'Etat ou les collectivités locales échappent au Code en faisant passer leurs marchés par celles-ci.

Les critères qu'il faut vérifier à ce niveau sont de deux ordres :

- l'origine du financement de ces organismes : l'Etat ou une collectivité locale. Cela signifie qu'une partie des ressources de ces organismes peut provenir du secteur privé. Mais il ne faut pas que ce secteur privé soit majoritaire dans le financement de ces entités.
- le critère de l'intérêt général : les prestations envisagées doivent relever de l'intérêt général. Elles doivent donc avoir un intérêt national ou local qui cadre avec les missions premières de l'Etat ou de la collectivité locale.

III.1.e : Les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire (...)

La loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes a abrogé l'article 49, alinéa 2, et le titre III.de la loi n°90-07 du 26 juin 1990 relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique.

Les définitions données à ces sociétés sont rappelées ci-après :

Les sociétés nationales sont des sociétés par actions de droit privé dont le capital est intégralement souscrit par l'État et, le cas échéant, par d'autres personnes morales de droit public. Dans tous les cas, la participation directe de l'État est supérieure à 50% du capital social. Leur création est autorisée par la loi.

Les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, régies par le Code des Obligations civiles et commerciales, sont des sociétés dans lesquelles une ou plusieurs personnes publiques possèdent directement ou indirectement au moins 50% du capital social. La participation d'une personne publique au capital social de ces sociétés par l'intermédiaire d'un organisme est calculée comme suit :

- si la puissance publique possède 50% du capital social de l'organisme intermédiaire, sa participation est décomptée pour une valeur égale à la part détenue par l'organisme intermédiaire lui-même ;*
- dans le cas contraire, la participation publique est calculée au prorata de sa participation au capital social de l'organisme intermédiaire ».*

Elles étaient appelées avant, « sociétés d'économie mixte » du fait de la composition du capital.

Ces sociétés doivent, pour leurs marchés, appliquer les dispositions du Code des marchés public malgré leur statut privé.

A ce niveau, il convient d'aborder la situation du FONSIS.

Concernant le FONSIS, le texte de référence est la loi n° 2012-34 du 31 décembre 2012. La question de la soumission de cet organisme au Code des marchés publics soulève des difficultés d'interprétation qui peuvent être résolues par une lecture croisée de la loi précitée et du Code des marchés publics.

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2012-34 du 31 décembre 2012 « (...) Le FONSIS est une société anonyme d'investissement dont le capital est détenu à 100 % par l'Etat qui peut ouvrir celui-ci à ses démembrements. Toutefois, la participation directe de l'Etat est fixée au minimum à 70 % du capital social de la société ».

Plus loin, l'article 20 de la même loi précise que « Les règles de passage des marchés conclus par le FONSIS sont fixées dans un manuel de procédures qui détermine les règles applicables aux marchés conclus. Le manuel de procédures et tout amendement y afférent ne sont applicables qu'après approbation du Conseil. Ce manuel de procédures est un manuel de classe mondiale, adhérant aux principes des manuels de procédures des meilleurs fonds souverains mondiaux. Ce manuel doit reprendre les principes généraux d'appel à concurrence ».

De par sa composition, le FONSIS est bien une Société Anonyme à Participation Publique Majoritaire et est soumis, de ce fait, au Code des marchés publics. En effet, celui-ci inclut en son article 2, les SAPPM dans la liste des structures soumises au Code.

Le manuel de procédures auquel fait référence l'article 20 de cette loi du 31 décembre 2012 semble vouloir instituer une dérogation à ce champ d'application du Code des marchés publics. Toutefois, cette disposition d'un texte qui n'a pas de valeur réglementaire ne saurait soustraire cet organisme du champ d'application du Code. D'ailleurs, cette exclusion de ce champ d'application du Code serait contraire aux dispositions de la directive communautaire CM/UEMOA du 09 décembre 2005.

En effet, l'article 4 de cette directive, qui est une norme ayant une valeur supra législative, inclut bien les sociétés à participation financière publique majoritaire (ce qu'est le FONSIS) dans son champ d'application. Or, exclure le FONSIS du champ d'application du Code des marchés publics reviendrait à dire que les procédures d'acquisition lancées par celle-ci ne sont pas soumises non plus à la directive précitée.

En outre, et surtout, eu égard à l'article 25 du Code des Obligations de l'Administration, les organismes comme le FONSIS ne peuvent pas invoquer la particularité de leur statut pour se soustraire au champ d'application du code. En effet, cette disposition du COA pose une règle d'« exclusivité » du Code des marchés publics quand il dispose : « (...) Aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d'acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le code des marchés publics ou prises en application de ce code ».

III.1.f : les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) à e) de l'article 2.1 du code des marchés publics

Ces associations sont également soumises au Code des marchés publics. Cette soumission au Code est logique car ces associations sont créées par des organismes qui eux-mêmes doivent appliquer la réglementation des marchés publics. Là encore, on cherche à éviter que ces organismes se soustraient au Code en utilisant ces associations pour passer leurs contrats de services, de fournitures ou de travaux publics.

III.2 Au plan matériel

Outre les marchés de travaux, fournitures et services dont les montants sont supérieurs aux seuils de passation en application des dispositions des articles 53 et suivants du CMP, sont également soumis au Code des marchés,

III.2.a. les délégations de maîtrise d'ouvrage et les marchés passés par les délégataires de maîtrise d'ouvrage

Les dispositions des articles 2.2 et 31 du Code des marchés publics affirment clairement l'application des dispositions du Code des marchés tant s'agissant du choix du délégataire par l'Autorité contractante que des contrats passés par le délégataire dans le cadre de l'exécution de sa mission.

III.2.b. les marchés passés en application d'accords de financement ou de traités internationaux sous réserve de l'application de dispositions contraires résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux

Ces marchés sont également soumis au CMP. Les marchés passés en application d'accords de financement concernent ceux auxquels l'Autorité contractante fait recours pour exécuter un programme financé par exemple par la Banque mondiale, la BAD ou tout autre bailleur de fonds ou encore un pays partenaire au développement du Sénégal.

En cas de divergences entre les textes règlementant les marchés passés en application d'accords de financement ou de traités internationaux et ceux du Code des marchés publics, les premiers prévalent et doivent être appliqués par les Autorités contractantes.

III.2.c. les contrats portant participation des cocontractants des personnes publiques à l'exécution d'un service public

Le COA, en son article 10 (issu de la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n° 65-61 du 19 juillet 1965) évoque ces contrats portant participation des cocontractants des personnes publiques à l'exécution d'un service public. Ces contrats désignent les délégations de service public et les contrats de partenariat.

Une convention de délégation de service public est un contrat administratif par lequel une personne morale de droit public confie, pour une période déterminée, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé. La rémunération du délégataire est totalement ou essentiellement liée aux résultats provenant des revenus de l'exploitation du service. Rentrent dans cette catégorie le contrat de concession et la régie intéressée.

La concession est le contrat par lequel une personne publique charge le concessionnaire soit d'exécuter un ouvrage public ou de réaliser des investissements relatifs à un tel ouvrage et de l'exploiter en vue d'assurer un service public, soit uniquement d'exploiter un ouvrage ou des équipements publics en vue d'assurer un service public. Dans tous les cas le concessionnaire exploite le service public en son nom et à ses risques et périls en percevant des rémunérations des usagers de l'ouvrage ou des bénéficiaires du service concédé.

Quant à la régie intéressée, elle désigne le contrat par lequel une personne publique confie l'exploitation d'un service public à un cocontractant qui en assume la gestion pour le compte de ladite personne publique et reçoit de cette personne publique une rémunération calculée en fonction des revenus ou des résultats de l'exploitation du service.

Les dispositions du COA sont sans équivoque quant à la soumission des contrats de délégation de service public aux règles du CMP. En effet, l'article 10 du COA précise que *«leur passation est soumise aux principes et méthodes applicables aux achats publics définis par les articles 23 à 33 du présent code»*. Or, ces différents articles du COA font référence notamment aux principes fondamentaux applicables aux achats et à la soumission au Code des marchés publics pour les règles de préparation, de passation, d'approbation ou d'exécution et de contrôle.

De fait, les dispositions de l'article 25 du COA précisent bien « qu'aucune réglementation ou procédure particulière à une Autorité contractante, à une catégorie d'acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le code des marchés publics ou prises en application de ce code ».

Le dispositif mis en place par le COA est complété par l'article 82 du Code des marchés publics relatif aux procédures de passation de ces contrats portant participation à l'exécution du service public, lequel définit les règles de passation des conventions de délégation de service public.

- Dispositions dérogatoires

Les procédures de passation telles que fixées par le Code des marchés publics font l'objet de quelques dérogations qui portent sur :

III.2.d : Les acquisitions aux enchères publiques effectuées par le service du mobilier national.

Cette dérogation est prévue à l'article 3.4.a du CMP. Le service chargé du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères publiques sans limitation de prix et sans appliquer les procédures prévues par ledit Code. Le règlement de ces achats peut avoir lieu sur production du procès-verbal de vente de la personne habilitée à effectuer les ventes aux enchères. Le montant des dépenses effectuées dans ces procédures comme l'importance du mobilier acquis n'entraînent pas l'application des règles applicables en matière de marchés publics.

Il est indiqué aux autorités contractantes que ce concept de « *mobilier national* » peut s'entendre au sens large et même inclure des œuvres d'art . En effet, le 11 novembre 2013, le Comité de Règlement des Différends a été saisi par le Ministère de la Culture et du Patrimoine d'une demande d'avis relative à la procédure d'acquisition d'œuvres d'art au profit de la Direction du Patrimoine culturel. Le CRD eut la position suivante :

«(...) la complexité et la particularité de l'objet du contrat d'acquisition font que le processus de conclusion de ce dernier est incompatible avec bon nombre de règles du Code des marchés publics ;

Considérant que l'article 3.4.a) dudit Code, dans la logique de prendre en compte de telles spécificités, a aménagé une dérogation pour le service chargé du mobilier national qui peut faire des acquisitions aux enchères publiques sans limitation de prix et sans appliquer les procédures prévues par le Code des marchés publics ;

Que le mobilier national, même s'il n'est pas défini par le Code des marchés publics ou par un autre texte juridique en vigueur, ne peut exclure le domaine privé artistique de l'Etat composé, selon l'article 2 du décret n° 67-034 du 11 janvier 1967, des objets suivants :

- les œuvres picturales et fresques ;
- les tapisseries d'art ;
- les sculptures et bas-reliefs ;
- les poteries et céramiques d'art ;
- les mosaïques.

²Avis n° 008/13/ARMP/CRD du 27 novembre 2013 du CRD statuant en Commission Litiges sur la soumission de la procédure d'acquisition d'œuvres d'art aux règles du Code des marchés publics.

«Qu'ainsi, il y a lieu d'admettre que la dérogation de l'article 3.4.a) du Code des marchés publics doit s'appliquer à la procédure d'acquisition d'œuvres d'art au profit de la Direction du Patrimoine culturel ».

III.2.e. : Les acquisitions effectuées par les missions diplomatiques et consulaires. Ces marchés ne sont pas non plus soumis au Code, en application de l'article 3.4.b du CMP. Par services consulaires il faut comprendre les ambassades et les consulats.

III.2.f. : Les services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance et de représentation juridiques
Cette dérogation est prévue à l'article 3.3.a) i du CMP. Les Autorités contractantes n'appliquent pas le Code des marchés publics quand elles ont recours, à l'occasion d'un litige les concernant, aux services d'un arbitre, d'un avocat ou de tout autre professionnel, du moment que les prestations en question relèvent d'une mission d'assistance juridique ou de représentation.

Il convient de rappeler que les services d'arbitrage et de conciliation, ainsi que d'autres modes alternatifs similaires de règlement des conflits, sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes dont la spécificité de la réglementation qui régit leurs activités rendrait incompatible toute mesure de publicité et de mise en concurrence, sans oublier le caractère intuitu personae de ces prestations et de la nécessité d'en garantir, à ce stade, la confidentialité.

Concernant spécifiquement la représentation en justice par les avocats, il convient de préciser que ceux-ci sont régis par des principes relatifs notamment au respect du secret des relations avec leurs clients et à leur indépendance, dont le respect s'impose au pouvoir réglementaire.

En outre, du fait du caractère imprévisible d'un contentieux et de l'incertitude sur le volume et la durée des prestations, appliquer le code des marchés publics pourrait se révéler, à certains égards, peu efficient. En effet, le recours au service d'un arbitre, d'un conciliateur ou d'un avocat, à des moments qui ne pouvaient être fixés à l'avance et l'impossibilité d'estimer la quantité des prestations à fournir, ou leur délai d'exécution, rend matériellement impossible toute opération de planification, de publicité, de définition ou d'évaluation préalable des besoins, etc.

La difficulté porte sur le terme d'assistance qui doit se lire en liaison avec celui de représentation juridique. Il est ici fait référence aux situations contentieuses. En revanche, il ne faudrait pas confondre cette situation prévue à l'article 3.3.a.i. du Code des marchés publics, avec les missions relevant des prestations intellectuelles qui, elles, sont soumises au Code. C'est le cas par exemple du recours à un cabinet d'avocats pour assister une Autorité contractante dans une procédure de passation d'un contrat complexe.

III.2.g. : Les services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert des titres ou d'autres instruments financiers en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des Autorités contractantes, et des services fournis par des banques centrales
Pour illustrer ces cas prévus à l'article 3.3.a.ii du Code des marchés publics, il convient de retenir l'exemple des procédures d'emprunts obligataires effectuées par ces Autorités contractantes, ou encore celui de leurs opérations boursières. Pour ces types d'opérations financières, le Code des marchés publics ne s'applique pas.

Cette exclusion visée à l'article précité se justifie par des raisons pratiques liées aux spécificités des marchés financiers.

En effet, dans le cadre des besoins que les personnes morales soumises au Code peuvent avoir en matière d'acquisition sur le marché financier, il est nécessaire de prendre rapidement des décisions qui ne peuvent être retardées par une excessive formalisation des procédures.

Incontestablement, les marchés de services financiers exigent, en effet, tout à la fois un degré de confidentialité et une réactivité incompatibles avec les délais de mise en concurrence fixés par le code des marchés publics.

Mais attention, la disposition précitée vise bien les services fournis par les banques centrales. Cela signifie que les emprunts et services financiers classiques effectués auprès des établissements ou banques commerciales restent des marchés de services soumis au Code.

III-2.h. : Les contrats de travail

Les contrats de travail conclus par les Autorités contractantes visées à l'article 2 du Code des marchés publics, même s'ils impliquent des prestations pour celles-ci, sont des opérations différentes des marchés publics et sont régis par le droit privé (code du travail).

Ces contrats visés à l'article 3.3.b sont exclus du champ d'application du Code.

Cette exclusion recouvre le cas où la personne publique souhaite recruter elle-même des agents ou des employés, sans passer par un intermédiaire. En effet, quand la personne publique passe par un intermédiaire pour recruter un ou des agents, on est dans le cadre d'un mandat qui porte sur une prestation de services.

Ainsi, les marchés ayant pour objet le recours à des agences d'intérim ou à des cabinets de recrutement ne sont pas exclus du champ d'application du CMP. Ils s'analysent comme des marchés de services. L'Autorité contractante devra nécessairement organiser une mise en concurrence pour sélectionner l'intermédiaire qui procédera au recrutement des agents. Par contre, une fois recrutés, les relations entre ces agents et cette Autorité contractante seront exclues du champ d'application du CMP.

Mais pour que cette dérogation puisse s'appliquer, il est obligatoire que le contrat par lequel l'Autorité contractante procède elle-même au recrutement présente les caractéristiques d'un contrat de travail.

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. La qualification en contrat de travail suppose ainsi la réunion de trois critères **cumulatifs** :

- un travail pour le compte d'autrui ;
- un emploi rémunéré ;
- un lien de subordination caractérisé par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.

III.2.i. : L'achat de carburant destiné aux véhicules de l'Administration

Conformément aux dispositions de l'article 3.4.c) i. du CMP, les opérations portant sur les produits pétroliers suivants dénommés super carburant, essence ordinaire et gasoil ne sont pas soumises aux procédures de passation de marchés, pour autant que ces produits soient destinés aux véhicules de l'Administration ainsi que le gaz butane à usage domestique.

Ces acquisitions doivent cependant être soumises à l'application du prix en vigueur figurant au barème de la structure des produits pétroliers publié périodiquement par la Commission nationale des Hydrocarbures du Ministère chargé de l'Energie. Ces procédures donnent lieu simplement à règlement sur mémoires ou factures.

Mais cette disposition exclue de cette dérogation, les produits destinés à l'exploitation. Pour ne pas se tromper sur le sens de cette notion d'« exploitation » l'interprétation qu'il faut faire de cette disposition est que dans tous les cas où ces produits ne sont pas destinés à l'usage des véhicules de l'Administration, il y a lieu d'appliquer le Code des marchés publics. L'Autorité contractante devra utiliser le critère de « la destination de ces produits pétroliers » pour savoir si le Code des marchés publics devra être applicable à la procédure d'acquisition.

III.2.j. : L'achat de titres de transport aérien ou maritime

Ces achats ne sont pas soumis au Code des marchés publics en application de l'article 3.4.c) ii. du CMP. La seule condition qui est posée est que ces achats doivent être effectués pour les besoins des missions des agents de l'Autorité contractante.

III.2.k. : L'hébergement et la restauration des participants, dans les réceptifs hôteliers ou dans les structures ayant une telle vocation, à l'occasion de l'organisation de sommets officiels, de séminaires ou atelier Il faut comprendre cette dérogation comme étant une volonté, pour les pouvoirs publics sénégalais, de faciliter l'organisation de tels événements.

Mais pour cette dérogation également, il importe de procéder à une interprétation stricte de l'article 3.4.c) iii du Code des marchés publics.

Pour ces dépenses et quel que soit leur montant, l'application du Code des marchés publics n'est pas davantage requise. Cependant, ces dépenses doivent être circonscrites aux besoins des « participants » et se rattacher aux nécessités de l'organisation de sommets officiels, de séminaires ou ateliers.

Cette précision est importante car toutes les prestations entrant dans le cadre de ces événements ne sont pas exclues du code des marchés publics. Cette disposition vise uniquement « l'hébergement » et « la restauration ». En effet, à titre d'exemple, si l'Autorité contractante a besoin, par exemple, de la confection et de la fourniture d'imprimés pour les besoins de communication sur de tels événements, le code des marchés publics sera applicable.

III.2.l. : Les opérations d'acquisition ou de location de terrains, bâtiments et autres biens immobiliers Relativement au champ d'application du Code des marchés publics, la DCMP a eu à soumettre, le 09 janvier 2009, une demande d'avis à l'ARMP concernant l'applicabilité du Code aux opérations ayant pour objet l'acquisition ou la location, pour les besoins de l'Administration, de terrains, bâtiments et autres biens immobiliers .

Dans cette procédure de demande d'avis, la DCMP exposait à l'ARMP avoir adopté une position sur les contrats de location d'immeubles à usage de bureaux administratifs qui, selon elle, ne sauraient être assimilés à des marchés publics au sens de la réglementation en vigueur.

Après avoir relevé les moyens développés par la DCMP, le CRD précisait que la demande d'avis posait précisément la problématique suivante : « *la soumission ou, inversement, l'exclusion des marchés de location d'immeubles à usage de bureaux du champ d'application du Code des marchés publics* ». Plus globalement, il fallait se déterminer sur « *l'applicabilité des règles de passation des marchés publics aux acquisitions ou locations des terrains, bâtiments et autres biens immobiliers existants* ».

³Avis N° 001/09/ARMP/CRD DU 26 janvier 2009 du CRD statuant en Commission Litiges sur la saisine de la DCMP relative à l'application du Code des marchés publics aux marchés relatifs à l'acquisition ou à la location de terrains, bâtiments existants ou autres biens immeubles

Après avoir rappelé les différentes dérogations consacrées par le texte en vigueur à l'époque, et défini la notion de marché public, le CRD apporta la réponse suivante :

« *Considérant que l'acquisition ou la location d'immeubles existants a principalement pour objet des ouvrages déjà réalisés qui ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de marchés de travaux ayant pour objet la réalisation par quelque moyen que ce soit d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par l'Autorité contractante ;*

(...)

Que s'agissant, par ailleurs, des marchés de fournitures ou de services, outre cette exigence de définition préalable des besoins, il faut relever que la cession ou la location de biens immeubles existants se distinguent de ces marchés de par leur objet en ce que, d'une part, les marchés de fournitures portent sur des biens mobiliers, d'autre part, les marchés de services ont pour objet soit une prestation de services correspondant à de la main d'œuvre, sans concrétisation d'un ouvrage : maintenance ou entretien, soit une prestation intellectuelle où il s'agit de production de l'esprit, de réflexion, soit la maîtrise d'ouvrage ;

Qu'il en résulte que les contrats de vente ou de location de terrains ou de bâtiments existants se distinguent de par leur objet des marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

Qu'en conséquence, les règles de passation de ces marchés, telles qu'établies par le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics, ne leur sont pas applicables ;

Considérant que cette exclusion ne concerne pas cependant les contrats de financement conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement se rapportant au contrat de vente ou de location d'immeubles existants ; qu'en conséquence, l'exclusion doit s'entendre comme suit :

- *lorsque le contrat de vente ou de location d'immeubles existants est conclu entre l'Autorité contractante et un vendeur, un bailleur ou le constituant d'un droit réel, il ne sera pas soumis à la réglementation sur les marchés publics, même s'il comporte un aspect financier comme par exemple le cas d'une convention ayant pour objet la mise à disposition et la cession à terme d'un bâtiment existant dont les loyers correspondent à la valeur du bien majorée des intérêts et charges ;*

- *lorsque le contrat relatif à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier existant s'accompagne d'une convention distincte conclue avec un organisme de crédit, seule cette convention sera soumise à la réglementation sur les marchés publics ».*

Même si cette dérogation n'est pas codifiée avec le décret de 2014, il est indiqué aux Autorités contractantes que les opérations relatives à l'acquisition ou à la location de biens immeubles, quel qu'en soient les modalités financières, présentent des caractéristiques particulières qui rendent inadéquate l'application de règles de passation des marchés publics.

Il n'est pas possible en effet d'imposer aux personnes publiques de mettre en concurrence des agences immobilières ou des propriétaires, sauf à les priver du droit de choisir l'endroit précis où elles veulent s'installer.

Mais il peut arriver qu'une entité soumise au Code des marchés publics décide de donner mandat à un organisme ou toute autre structure privée, pour lui trouver des biens immobiliers à acquérir ou à louer. Dans ce cas, aux fins de sélection de ce mandataire, il devra nécessairement faire application du Code des marchés publics. Les seules opérations qui échapperont à l'application du Code seront l'acquisition des immeubles en question.

III.2.m. Les opérations de sponsoring

La question s'est posée de savoir si une opération de sponsoring, souvent utilisée par les administrations pour valoriser davantage leur image et soutenir de bonnes initiatives, doit être soumise au Code des marchés publics. La réponse est négative, et l'ARMP a eu à le rappeler en réponse à une demande d'avis formulée par l'ARTP⁴.

Dans cette affaire, c'est par lettre en date du 26 mars 2012 que le Directeur général de l'ARTP a saisi le CRD d'une demande d'avis sur le sponsoring qu'il envisageait d'effectuer avec la chaîne de télévision Origine SA, à travers l'émission « D'un village à l'Autre ».

L'ARTP souhaitait accompagner, sur le plan logistique et financier, la télévision 2STV pour lui permettre d'atteindre à travers l'émission « D'un village à l'Autre », l'objectif de participer à l'éveil, à la conscientisation et la sensibilisation des populations par rapport aux aspects clés de la politique étatique de réduction de la fracture numérique. Dans ce cadre, elle voulait savoir si elle pouvait directement conclure un contrat de sponsoring avec un partenaire et si ledit contrat est exclu du Code des marchés publics.

Pour l'ARMP, « Considérant que le sponsoring se définit comme un contrat par lequel une structure publique ou privée finance une activité culturelle, sportive, artistique ou scientifique en échange d'une promotion et d'une publicité ; que de ce fait, la convention de sponsoring porte sur un projet élaboré en dehors de toute demande émanant de l'Autorité contractante et dont la direction ainsi que la responsabilité sont totalement détenues par le cocontractant ;

Qu'ainsi, la notion d'initiative du projet permet de distinguer les marchés publics et les conventions de sponsoring induisant l'exclusion de ces dernières du champ d'application du Code des marchés publics ;

Considérant, toutefois, que si les clauses de la convention font apparaître l'existence d'une contrepartie directe et proportionnée à la valeur sur le marché de la prestation, celle-ci se révèle être tout simplement une commande publique de prestation de service et comme telle, elle est susceptible d'être requalifiée en marché public ».

Deux critères doivent donc guider les Autorités contractantes afin de savoir si l'opération échappe ou pas au code des marchés publics :

- l'initiative du projet doit objectivement venir de la personne privée,
- il ne doit pas y avoir de contrepartie directe et importante qui pourrait s'apparenter à un prix que l'autorité contractante verse à la personne privée.

III.2.n. : Les opérations de publication par voie de presse d'insertions publicitaires ainsi que les publi-reportages par supports audiovisuels

Cette dérogation est prévue à l'article 3-4-c-iv du Code des marchés publics. Elle a pour intérêt de faciliter la communication des Autorités contractantes qui peuvent ainsi, dans des conditions procédurales souples, informer rapidement les acteurs de la commande publique.

Bien entendu outre pour le support «papier», cette dérogation prévue par cette disposition s'applique également aux publications faites par voie électronique.

Pour les publi-reportages, on peut penser par exemple à des campagnes de sensibilisation sur un programme de vaccination, d'inscription sur les listes électorales, etc.

⁴Avis n° 005/12/ARMP/CRD du 03 avril 2012 du CRD statuant en Commission Litiges sur la saisine de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes concernant la soumission d'un contrat de sponsoring au Code des marchés publics.

III.2.o. : Les médicaments et produits essentiels utilisés dans la médecine d'urgence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé

Cette dérogation est prévue à l'article 3.4.c.v du Code des marchés publics ; elle se veut une réponse adéquate aux situations d'urgence auxquelles les structures de santé peuvent être confrontées. Cette situation d'urgence peut en effet être incompatible avec les délais normaux de mise en concurrence.

Les conditions cumulatives d'application de cette dérogation sont :

- une situation de rupture de stocks,
- que les médicaments à acquérir fassent partie de la liste établie par arrêté du ministre en charge de la santé.

III.2.p. : L'acquisition de médicaments et produits pharmaceutiques essentiels, par les services et formations sanitaires

Tout comme le point précédent, cette dérogation instituée à l'article 3.4.c.v a été instituée pour éviter que l'approvisionnement en médicaments et produits jugés essentiels soient retardé, voire compromis par la longueur des délais de mise en concurrence.

La disponibilité de ces «médicaments» et «produits essentiels» pour les sujets qui en sont les destinataires pourra ainsi être préservée.

En effet, le caractère formalisé des procédures de marchés publics impliquerait que ces structures et formations soient obligées de se résoudre à avoir des lignes infructueuses ou à relancer un appel d'offres, ce qui occasionnerait inmanquablement de longues situations de rupture de stock.

Mais cette dérogation doit être lue et appliquée en tenant obligatoirement compte de l'arrêté du ministre en charge de la santé fixant les modalités de l'approvisionnement pharmaceutique des services et formations sanitaires.

III.3 La notion d'Autorité contractante

Selon les définitions du CMP, le terme «Autorité contractante» désigne les personnes morales visées à l'article 2 du Code des marchés qui renvoie à :

- « *l'Etat, les collectivités locales, y compris leurs services déconcentrés et les organisations non dotées de la personnalité morale, placées sous leur autorité ;*
- *les établissements publics ;*
- *les groupements mixtes des collectivités locales ;*

Les groupements mixtes sont ceux constitués par accord entre l'Etat et une ou des collectivités locales (communes, départements) ou entre celles-ci et un établissement public à caractère administratif, en vue d'une œuvre ou d'un service présentant une utilité pour chacune des parties.

- *les établissements publics ;*
- *les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général ;*
- *les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire;*
- *les associations formées par les personnes visées par les Autorités contractantes précédemment citées ».*

Le même article précise également que « *les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d'une Autorité contractante sont soumis aux règles qui s'appliquent, conformément au présent décret, aux marchés passés directement par ladite Autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation de marchés concernant la réalisation d'ouvrages ou de projets doit être effectuée dans les conditions stipulées aux articles 31 à 34 du présent décret ».*

La Personne morale de droit privé qui agit pour le compte d'une Autorité contractante et dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par celle-ci doit faire application du Code des marchés publics.

III.3.a. : Autorité contractante et personne morale de droit privé

Conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les personnes morales de droit privé peuvent avoir le statut d'Autorité contractante pour l'application des règles gouvernant la passation des marchés publics.

III.3.b : Autorité contractante et services déconcentrés

S'agissant de la notion de services déconcentrés, elle recouvre les services qui assurent le relais de l'Administration centrale ou d'une collectivité locale.

Ces services sont des Autorités contractantes au sens de l'article 2 du Code des marchés publics.

III.3.c. Autorité contractante et Personne Responsable des Marchés

La notion d'Autorité contractante ne saurait être confondue avec celle de Personne Responsable des Marchés publics (PRMP).

Conformément aux termes des définitions du Code des marchés, le terme «*personne responsable du marché*» désigne la personne chargée de conduire la procédure de passation du marché, **de signer le marché au nom de l'Autorité contractante** et de représenter l'Autorité contractante lors de l'exécution du marché.

Le décret portant Code des marchés publics désigne en son article 28 les personnes responsables des marchés chez les différentes Autorités contractantes. Ainsi, pour les marchés de l'Etat et dans chaque département ministériel, c'est le Ministre chargé du département concerné, qui est **responsable des marchés passés par les services centraux**, des marchés passés dans la Région de Dakar et des marchés des agences ou organismes non dotés de la personnalité morale relevant de son département. Toutefois, l'article 27 du CMP précise aussi que l'Autorité contractante peut désigner d'autres personnes responsables des marchés en précisant les catégories et les montants des marchés pour lesquels celles-ci disposent des compétences de personnes responsables de marchés. Il relève donc de l'Autorité contractante d'organiser la délégation, en cas de nécessité, des pouvoirs de PRMP, conformément aux textes réglementaires applicables en matière de délégation de pouvoirs.

Toujours en application de l'article 28 précité, selon l'Autorité contractante considérée, la PRMP est incarnée par :

- pour les marchés des collectivités locales, respectivement pour les départements et les communes : les présidents de conseil départemental et les maires ou leurs représentants dûment habilités ;
- pour les marchés des établissements publics, agences et autres organismes ayant la personnalité morale, visés à l'article 2.1 d) du code : l'organe exécutif désigné conformément aux règles qui leur sont applicables ;
- pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, le directeur général, quel qu'en soit le montant.

III.4 Les Autorités contractantes déconcentrées

Cette question a été traitée au paragraphe ci-dessus.



IV. LES ORGANES DE LA COMMANDE PUBLIQUE



IV.1 Les organes de passation

La PRMP chargée de conduire la procédure de passation du marché, de signer le marché au nom de l'Autorité contractante et de représenter l'Autorité contractante lors de l'exécution du marché est assistée dans l'exécution de ses missions par les Cellules de passation des marchés et les Commissions des marchés.

IV.1.1 Les cellules de passation des marchés

Au niveau de chaque Autorité contractante est mise en place une cellule de passation des marchés chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation de marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la Commission des marchés. Mais lorsqu'une Autorité contractante regroupe en son sein d'autres Autorités contractantes, une cellule de passation devra être mise en place au niveau de l'Autorité contractante principale et des autorités contractantes secondaires.

Les cellules de passation sont évoquées à l'article 35 du Code des marchés publics. La lecture de cette disposition doit être complétée par l'examen de la circulaire du Premier Ministre en date du 28 décembre 2007 (0005 PM) qui leur est consacrée. Les missions des Cellules de passation des marchés publics sont précisées par l'arrêté n° 865 du 22-01-2015 pris en application des articles 35 et 141 du Code des marchés publics relatif aux Cellules de passation des marchés des Autorités contractantes.

Ces cellules sont chargées de :

- l'examen préalable des dossiers d'appel à la concurrence, des rapports d'analyse comparative des offres, des procès-verbaux d'attribution provisoire et des projets de contrat pour les marchés dont les marchés dont les montants n'ont pas atteint les seuils de revue de la DCMP ;
- l'examen préalable de tout document à soumettre à l'Autorité contractante en matière de marchés publics ;
- l'examen préalable de tout document à transmettre à des tiers en matière de marchés publics ;
- l'examen préalable de tout document à signer avec des tiers en matière de marchés publics ;
- le classement et l'archivage de tous les documents relatifs aux marchés publics passés par les différents services ;
- l'établissement, en début d'année, du plan consolidé annuel de passation des marchés de l'Autorité contractante ;
- l'établissement de l'Avis général de passation des marchés et sa publication conformément aux articles 6 et 56 du Code des marchés publics ;
- l'insertion des avis et autres documents relatifs à la passation des marchés dans le système national informatisé de gestion des marchés ;
- la tenue du secrétariat de la Commission des marchés ;
- l'appui aux différents services pour les opérations de passation de marchés ;
- la réalisation et la tenue de tableaux de bord sur les délais de mise en œuvre des différentes étapes des procédures de passation des marchés et de réalisation des calendriers d'exécution des marchés ;
- l'identification des besoins de formation des services en matière de marchés publics ;
- la liaison avec les missions extérieures, notamment celles d'audit des marchés, initiées par l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;
- l'établissement, avant le 31 mars de chaque année, à l'intention de l'autorité dont elles relèvent, de l'ARMP et de la DCMP d'un rapport annuel sur l'ensemble des marchés passés au cours de l'année précédente.

Ces cellules assurent de fait au sein des Autorités contractantes un **contrôle qualité** des procédures de passation des marchés. **Ce contrôle est impératif** avant toute transmission aux autorités signataires, de contrôle ou d'approbation.

Au sein des départements ministériels et des collectivités locales, les responsables des Cellules de passation des marchés sont nommés par arrêtés pris par le Ministre de tutelle ou tous autres actes appropriés.

Conformément aux termes de la circulaire prise par le Premier Ministre, ces cellules doivent être mises en place conformément aux directives ci-après :

- au sein des départements ministériels disposant de Secrétariat général, la Cellule de passation de marchés est placée sous la tutelle directe du Secrétaire général ;
- au sein des départements ministériels ne disposant pas de Secrétariat général, la Cellule de passation de marchés est directement rattachée au Cabinet du Ministre ;
- au sein des collectivités locales, les Cellules de passation des marchés sont placées, selon le cas, sous la tutelle directe des secrétaires général et municipal ou de l'organe exécutif en cas de non existence du poste de secrétaire ;
- au sein des Etablissements publics, Sociétés nationales, Sociétés à participation publique majoritaire et Agences de droit public dotées de la personnalité morale, les structures déjà existantes chargées de la passation des marchés peuvent être conservées sous réserve de s'assurer que leurs attributions incluent les activités qui sont ciblées par l'arrêté susvisé du Ministre chargé des Finances.

Tout comme pour les membres de la Commission des marchés, les copies des actes de nomination et leurs déclarations, avant leur prise de service, valant engagement à respecter le décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 portant Charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics, doivent être transmises à la DCMP et à l'ARMP.

IV.1.2 Les Commissions des marchés

IV.1.1.a. : L'ancrage institutionnel et les missions des Commissions des marchés

Les missions des Commissions des marchés sont principalement précisées à l'article 35 du CMP. Le Code des marchés publics en fait des organes à part entière de la passation des marchés publics. Les Commissions des marchés sont chargées de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des marchés.

IV.1.1.b. : Composition et nombre de représentants de l'Autorité contractante dans les Commissions des marchés
Les Commissions des marchés sont composées de représentants de l'Autorité contractante dont le nombre et les conditions de désignation sont déterminés pour chaque catégorie d'Autorité contractante par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis de l'Organe chargé de la Régulation des Marchés publics, ainsi que des représentants des autres administrations et organismes concernés mentionnés aux articles 36 et 37 du CMP.

La présidence des Commissions des marchés est également assurée par le représentant habilité de l'Autorité contractante.

Outre les représentants de l'Autorité contractante, participent également aux Commissions des marchés :
1. pour les marchés de l'Etat passés en dehors de la Région de Dakar : un représentant du Gouverneur de région.

2. lorsqu'il s'agit des marchés des collectivités locales (communes et département, avec l'acte III de la décentralisation), l'Autorité contractante est assistée de deux membres du conseil municipal, ou départemental, selon le cas. En outre, le comptable de la collectivité ou son délégué assiste aux réunions de la Commission des marchés avec voix délibérative.

3. dans le cas des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participations publiques majoritaires, établissements publics, agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale, mentionnés à l'article 2.1 d) du CMP : un représentant du Ministre chargé de la tutelle de la société, établissement, agence ou organisme concerné et un représentant du Contrôleur financier.

L'arrêté n° 00864 du 22-01-2015 pris en application de l'article 36-1 du Code des marchés publics fixe le nombre et les conditions de désignation des membres des Commissions des marchés des Autorités contractantes.

- pour l'Etat : trois (3) représentants dont le président et le responsable du service maître d'œuvre ou son représentant ; pour les collectivités locales : deux (2) représentants composés de l'organe exécutif et, selon le cas, du Secrétaire général ou municipal ;

- les agences ou autres organismes non dotés de la personnalité morale, placés sous tutelle de l'Etat ou des collectivités locales ne peuvent disposer de Commissions de marchés propres que pour les activités dont la responsabilité de la passation des marchés y relatifs leur est spécifiquement conférée par actes réglementaires, telle que la maîtrise d'ouvrage déléguée, pour des activités précises ; dans de tels cas, le nombre de représentants de l'Autorité contractante est de 4 dont le Président ; les autres membres sont : le directeur financier de l'agence ou organisme, ou son représentant ; le responsable des services techniques de l'agence ou organisme, ou son représentant ; le responsable chargé des approvisionnements et marchés de l'agence ou organisme, ou son représentant ;

- pour les Sociétés nationales, les Sociétés anonymes à participation publique majoritaire, les Etablissements publics et les Agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale : quatre (4) représentants qui sont le président et les personnes ci-après : le directeur financier de la société ou son représentant ; le responsable des services techniques ou son représentant ; le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou son représentant.

Une certaine spécificité est à noter cependant pour les Commissions régionales des Marchés publics dans les régions autres que Dakar. C'est l'objet de l'arrêté n° 862 du 22-01-2015 pris en application de l'article 36, alinéa 7 du Code des marchés publics. L'article 1er de cet arrêté prévoit, dans chaque chef-lieu de région administrative (autre que Dakar, donc), une commission régionale des marchés publics, chargée de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des marchés publics des services déconcentrés de l'Etat et des organismes non dotés de la personnalité morale placée sous l'autorité de l'Etat, y compris les projets et programmes installés dans le ressort.

C'est le représentant de l'Etat au niveau de chaque région, en l'occurrence le Gouverneur, qui est chargé de la mise en place de cette commission régionale.

L'article 2 de cet arrêté fixe comme suit, la composition de ces commissions régionales :

- le représentant du Gouverneur qui en assure la présidence ;
- un représentant du service régional maître d'œuvre ;
- le représentant du Contrôleur régional des finances.

Ce même schéma est reconduit au niveau des départements. Le dernier point de ce même article 1er indique en effet que « dans chaque département, à l'exception des départements se situant dans les chefs-lieux de région et ceux de la région de Dakar, une commission départementale des marchés publics, chargée de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des marchés des services déconcentrés de l'Etat et des organismes non dotés de la personnalité morale placés sous l'autorité de l'Etat, y compris les projets et programmes installés dans le ressort, la commission départementale des marchés publics est mise en place par arrêté du préfet de département ».

Quant à la commission départementale est composée des membres suivants :

- le représentant du préfet qui en assure la présidence ;
- le représentant du service départemental maître d'œuvre ;
- le représentant du Contrôleur régional des finances.

Pour chaque membre titulaire de la Commission des marchés, il est également désigné un suppléant.

Un représentant du service maître d'œuvre assure les fonctions de rapporteur de la Commission, qu'elle soit régionale ou départementale. Le représentant du gouverneur ou du préfet de département, en sa qualité de président de la commission, désigne un rapporteur.

Comme pour les autres commissions de marchés, doivent être envoyées à l'ARMP et à la DCMP, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les copies des actes de nomination des membres de ces commissions régionales ou départementales et de leurs suppléants, ainsi que leur déclaration portant prise de connaissance du décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 sur la Charte de transparence et d'éthique. Cette formalité d'envoi doit être effectuée par le gouverneur de région ou le préfet de département.

Par ailleurs, l'article 38 du CMP prévoit également la possibilité, pour le président de la commission, de désigner un comité technique d'étude et d'évaluation des offres. Le rôle de ce comité sera d'apporter à l'Autorité contractante une expertise technique afin de l'éclairer sur ses choix. A cet effet, ce comité technique remet à la commission de l'Autorité contractante des éléments d'analyse et d'évaluation des offres ; il peut également faire participer à ses travaux, avec voix consultative, tout expert choisi en fonction de ses compétences particulières et de la nature des prestations objet du marché. Les membres de ce comité technique, et tout expert y siégeant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilités, d'interdiction et de conflits d'intérêt applicables à ceux des Commissions de marché.

En outre, la DCMP peut désigner des personnes qualifiées en qualité d'observateurs pour contrôler les opérations d'ouverture et d'évaluation des offres. La réglementation a voulu, au moyen de ce procédé, renforcer la transparence dans le choix de l'attributaire du marché.

NB : Concernant la composition des commissions des marchés

Par avis en encadré ci-dessous, en date du 28 février 2018, le Comité de Règlement des Différends de l'ARMP a rendu un avis concernant la prise en compte de certaines spécificités mettant certaines autorités contractantes dans l'impossibilité de se conformer à l'exigence de désigner un responsable des services techniques ou son représentant dans la commission des marchés publics.

AVIS N° 002/18/ARMP/CRD DU 28 FEVRIER 2018 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DE L'HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR RELATIVE A LA CONDUITE A TENIR PAR RAPPORT AUX OBSERVATIONS DE DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS (DCMP) PORTANT SUR LA COMPOSITION DE SA COMMISSION DES MARCHES PUBLICS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

VU la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration, modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n° 2017-527 du 11 avril 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

VU la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

VU la résolution n° 04-17 du 20 avril 2017 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends ;

VU demande de l'Hôpital Principal de Dakar du 22 février 2018 ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Ely Manel FALL, Conseiller juridique chargé des études et de la stratégie de développement de l'ARMP, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de monsieur Oumar SAKHO, Président ; de madame Habibatou Babou WADE, de messieurs Alioune Badara FALL et Abdourahmane NDOYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente décision ;

Par lettre, reçue le 23 février 2018 au bureau du courrier de l'ARMP, l'Hôpital Principal de Dakar a saisi le Comité de Règlement des Différends d'une demande d'avis relative à la conduite à tenir par rapport aux observations de la DCMP portant sur la composition de sa commission des marchés, pour la gestion 2018.

LES MOYENS DEVELOPPES PAR LE REQUERANT

Selon le requérant, par rapport aux spécificités de l'hôpital, les membres siégeant au titre de responsables des services techniques sont au nombre de quatre (04), répartis ainsi qu'il suit :

- un pour le matériel biomédical,
- un pour les produits pharmaceutiques
- un pour les autres fournitures
- un pour les travaux

Il informe que depuis l'exercice 2010, la liste de la commission des marchés est toujours configurée de la sorte au niveau des services techniques.

Cependant, il renseigne que, pour cette année, la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) leur a demandé de se conformer aux dispositions de l'article 2.d de l'arrêté n°00864 du 22 janvier 2015 du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan qui fixe un seul responsable pour les services techniques, en modifiant la composition de sa commission des marchés.

C'est pourquoi, l'hôpital demande au CRD un avis sur la conduite à tenir par rapport à cette situation ou de l'autoriser à maintenir la composition de sa commission des marchés comme telle.

OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que la demande d'avis porte sur la manière de se conformer à l'exigence de désigner un responsable des services techniques ou son représentant dans la commission des marchés publics des autorités contractantes tel que l'Hôpital Principal de Dakar.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que parmi les membres des commissions de marchés des autorités contractantes, visées aux articles 2.c et 2.d de l'arrêté n° 00864 du 22 janvier 2015 du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, ces dispositions prescrivent la désignation du responsable des services techniques ou son représentant ;

Qu'ainsi, la DCMP recommande à ces Autorités contractantes, dans le cadre de son contrôle des actes de nomination des membres des commissions de marchés, de se conformer à la prescription, en nommant un responsable (titulaire et suppléant) représentant les services techniques ;

Considérant que la commission des marchés, organe habilité à ouvrir, évaluer les offres et à proposer l'attribution, doit être imprégnée des enjeux, objectifs et résultats des achats afin de pouvoir optimiser ses décisions dans une logique d'efficacité ;

Qu'il est constant que personne n'est plus indiquée que les agents des services techniques, initiateurs ou bénéficiaires des commandes, pour comprendre et apprécier la portée d'une décision d'achat sur le fonctionnement et l'atteinte des objectifs de son service ;

Que de plus, il est difficile voire impossible de disposer d'un agent ayant les compétences lui permettant d'édifier la commission des marchés relativement aux implications de ses décisions sur la prise en charge et l'atteinte des objectifs au niveau de chaque centre de décision d'une administration ;

Qu'ainsi, même si la formulation « responsable des services techniques ou son représentant » n'est pas des plus heureuses par rapport à l'objectif recherché, le sens qu'il faut donner à la disposition est que les Autorités contractantes concernées, doivent désigner un responsable ou son représentant par service technique, visé dans l'organigramme officiel ;

EMET L'AVIS QUI SUIT :

1) Constate que la DCMF recommande aux Autorités contractante, visées aux articles 2.c et 2.d de l'arrêté n° 00864 du 22 janvier 2015 du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, de nommer un responsable (titulaire et suppléant) représentant les services techniques dans leur Commission des marchés ;

2) Dit qu'il est difficile voire impossible de disposer d'un agent ayant les compétences lui permettant d'édifier la Commission des marchés sur les implications de ses décisions pour la prise en charge et l'atteinte des objectifs au niveau de chaque centre de décision d'une administration ;

3) Dit qu'en conséquence, le sens qu'il faut donner à la disposition est que les Autorités contractantes concernées, doivent désigner un responsable ou son représentant par service technique visé dans l'organigramme officiel ;

4) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à l'Hôpital Principal de Dakar ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), le présent avis qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

**Le Président
Oumar SAKHO**

**Les membres du CRD
Habibatou Babou WADE Abdourahmane NDOYE
Alioune Badara FALL**

**Le Directeur Général,
Rapporteur
Saër NIANG**

IV.1.3 Positionnement de la PRMP vis-à-vis des autres organes de passation des marchés

Les modalités de désignation des membres des cellules de passation des marchés et des Commissions de marchés par voie d'arrêté confèrent au représentant légal de l'Autorité contractante un rôle essentiel dans ce processus. L'article 3 de l'arrêté susvisé donne compétence à l'Autorité contractante de nommer :

- le Président de la commission ;
- ses différents représentants et leurs suppléants (ceux de l'Autorité contractante elle-même) ;
- tous les autres membres de la Commission.

L'article 3 de l'arrêté susvisé prévoit également que chaque Autorité contractante désigne le rapporteur de la Commission des marchés. Il doit faire partie des membres de la cellule de passation des marchés.

Aucun membre de la Commission des marchés ne peut intervenir dans le fonctionnement des structures de contrôle interne ou au niveau de la Cellule de passation des marchés de l'Autorité contractante. Ces limitations s'expliquent par la nécessité de séparer les fonctions de passation des fonctions de contrôle. Aussi, considérant que la cellule de passation des marchés contrôle le bon fonctionnement de la Commission, il s'avère logique que ces deux organes internes soient totalement distincts aussi bien dans leur composition que dans leur fonctionnement.

Dans la logique des pouvoirs importants que lui confèrent le Code des marchés publics dans les procédures, la présidence des Commissions des marchés est assurée par le représentant habilité de l'Autorité contractante (alinéa 6 de l'article 36 du Code).

De par son positionnement, en l'occurrence son rôle de représentant légal de l'Autorité contractante, la PRMP a ainsi une certaine autorité (en termes d'hierarchie) sur les autres organes internes de passation des marchés publics.

IV.1.4 Durée du mandat des membres de la Commission des marchés et de leurs suppléants

Les membres de la Commission des marchés représentant l'Autorité contractante sont nommés pour un an. Toutefois, les textes réglementaires n'interdisent pas le renouvellement de leur mandat qui est souhaitable afin d'assurer la pérennité du système et la professionnalisation de la fonction.

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté précité précisent que les actes de nomination des membres de la Commission et de leurs suppléants interviennent en début d'année. Ils sont transmis au plus tard le 5 janvier à l'ARMP et à la DCMP.

IV.1.5 Règles applicables en matière de conflit d'intérêts

Le Code des marchés publics dispose en son article 40 que « *toute personne qui a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, un intérêt direct ou indirect, notamment en tant que dirigeant, associé ou employé, dans une entreprise candidate à un marché examiné par la commission à laquelle elle appartient, doit en faire la déclaration, se retirer de la commission et s'abstenir de participer à toutes opérations du marché considéré* ».

Toutefois, les standards applicables en matière de gestion des conflit d'intérêts soulignent également la nécessité de clarifier le positionnement des agents publics désignés pour composer la Commission des marchés en évitant de conférer soit la présidence, soit la majorité des votes au sein de la commission à des agents qui ont eu ou auront à intervenir au plan technique au stade de la définition des projets et des documents d'appel d'offres ou de consultation, ou encore dans la négociation des contrats ou qui, enfin, exercent sur le plan financier ou comptable, des responsabilités au sein de l'Autorité contractante.

IV.2 Les organes de contrôle

Au niveau interne : la compétence des cellules de contrôle de la passation des marchés publics

Toutes les Autorités contractantes doivent s'assurer de l'existence de ce contrôle interne qui a pour objet la garantie du respect des dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics. Ce contrôle est effectué par les cellules de passation des marchés publics conformément aux articles 35 et 141 du CMP.

En matière d'établissement du rapport sur la passation et l'exécution des marchés de l'Autorité contractante, une certaine confusion peut avoir lieu sur leur fréquence. En effet, d'une part, l'article 144 du Code des marchés publics indique que ce rapport est « *annuel* », alors que d'autre part, l'article 1er de l'arrêté n° 865 du 22/01/15, dit que celui-ci est « *trimestriel* » et annuel. Ainsi, avec ce nouvel arrêté il n'y a plus de confusion entre les deux types de rapport (annuel et trimestriel) il intègre les deux.

En réponse à ces indications différentes selon ces textes, il est indiqué aux cellules de passation d'établir au moins un rapport annuel. En considération du principe de la hiérarchie des normes, ne commettra pas un manquement la cellule qui, certes n'a pas établi un rapport trimestriel, mais en a fait un pour l'année précédente. Dans une telle situation, la cellule concernée sera en conformité avec le décret portant Code des marchés publics (la règle du rapport trimestriel est posée par un arrêté, lequel a une valeur inférieure au décret).

En tout état de cause, ce rapport annuel est à établir avant le 31 mars de chaque année à l'attention de l'autorité dont relève la cellule, de l'Organe chargé de la régulation des marchés publics et la Direction chargée du contrôle des marchés publics. Elle comportera au moins :

- les indications sur le nombre de marchés, le type de procédure choisi, les actes concrets de contrôle effectué au niveau interne ;
- la liste des entreprises défaillantes ;
- la nature des manquements constatés ;
- un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe.

IV.2.1 L'organe de contrôle a priori de la passation des marchés

La DCMP est chargée du contrôle a priori de la procédure de passation des marchés. Les principales responsabilités de la DCMP au titre de cette mission de contrôle sont définies à l'article 141 du CMP.

IV.2.1.a. Seuils de contrôle

Ce contrôle s'applique à titre principal à tous les marchés publics à partir de seuils fixés par arrêté du Ministre en charge des Finances, notamment sur les projets de DAO, les rapports d'évaluation, les procès-verbaux d'attribution provisoires et les projets de marchés. Il est toutefois systématique en matière d'accords-cadres, de marchés à commande, de marchés de clientèle et de marchés à tranche conditionnelle quel que soit le montant, d'appel d'offres restreint et d'entente directe.

En deçà de certains seuils, le contrôle a priori est assuré par la cellule de passation des marchés, ce qui devrait contribuer significativement à l'allègement de la procédure. Les tableaux qui détaillent l'application de ce contrôle a priori sont exposés dans la partie du présent guide qui traite des allègements de procédures (pages 24 et suivantes).

Toutefois, il y a lieu de noter que la circulaire du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan n° 94 du 23-02-15 prévoit que pour tous les marchés dont les montants n'ont pas atteint les seuils de revue à priori par la DCMP, l'examen préalable des dossiers d'appel à la concurrence, des rapports d'analyse comparative des offres, des procès-verbaux d'attribution provisoire et des projets de contrat est assuré par la Cellule de passation des marchés (CPM).

A ce titre, l'avis de non objection délivré par la CPM est nécessaire pour la poursuite des procédures de passation et cet avis de non objection doit faire l'objet d'un écrit à l'image de celui de la DCMP.

IV.2.1.b. Avis et autorisations

Dans le cadre de l'exécution de ses missions, telles que précisées ci-dessus et conformément aux dispositions du CMP (principalement les articles 76 et 141 et suivantes), les Autorités contractantes saisissent la DCMP de demandes d'avis ou d'autorisations. L'article 2 du décret n°2007-547 du 25 avril 2007 portant création de la Direction centrale des Marchés publics indique cependant que la DCMP a pour mission d'accorder, à la demande des Autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur.

Mais il convient de préciser la différence entre un avis et une autorisation de la DCMP.

Le Code des marchés publics précise certains cas où l'Autorité contractante sollicite un avis et d'autres où c'est plutôt une autorisation préalable qui doit être demandée.

A titre d'exemple, l'article 141 parle d'« avis » pour les dossiers d'appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation concernant :

- les marchés à commande, les marchés de clientèle et les marchés à tranches conditionnelles, quel que soit le montant ;
- les marchés que l'Autorité contractante souhaite passer par appel d'offres restreint ;
- les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
- les conventions de délégation de service public ;
- les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil d'examen juridique ;
- le rapport d'analyse comparative des offres ou propositions et le procès-verbal d'attribution provisoire du marché établis par la Commission des marchés, relatifs aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Pour sa part, l'article 76.1 du Code utilise le terme « autorisation » pour les marchés passés par entente directe en raison de la détention d'un droit d'exclusivité ou de la nature complémentaire des prestations (...). En revanche, cette disposition fait recours au terme « avis » pour les marchés considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l'autorité n'est pas compatible avec les délais et règles de forme exigées par la procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint et les marchés passés dans le cadre de mesures de mobilisation générale et de mise en garde.

A chaque fois que les consultations de la DCMP sont obligatoires (au regard des seuils ou du type de procédure), l'avis que rendra cet organe de contrôle sera donc dit « conforme ». Cela implique que l'Autorité contractante devra s'y conformer ; si elle est en désaccord avec le sens de l'avis, elle ne pourra pas poursuivre la procédure sans saisir le CRD de l'ARMP.

Les points 2 et 3 de l'article 142 du CMP apportent néanmoins une distinction à faire à ce niveau.

Aux termes du point 2 de cette disposition, *« Si l'Autorité contractante passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics sur un dossier d'appel à la concurrence, elle doit motiver sa décision par écrit et en rendre compte à l'autorité d'approbation du marché dont elle relève et en informer l'Organe chargé de la Régulation des Marchés publics »*.

Quant au point 3, il précise que *« si l'autorité contractante n'accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulées par la Direction chargée du contrôle des marchés publics concernant la possibilité d'utiliser un procédure autre que l'appel d'offres ouvert ou relatives à la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends près l'Organe chargé de la régulation des marchés publics »*.

Au sens de ces dispositions, l'avis qui porte sur un dossier d'appel à la concurrence ne serait pas « conforme » puisque l'Autorité contractante peut continuer la procédure en se contentant de rendre compte à l'autorité d'approbation du marché et d'informer simplement l'ARMP. Mais pour le point 3 ci-dessus, si l'avis porte sur une procédure dérogatoire à l'appel d'offres ouvert ou sur une attribution provisoire, il serait donc « conforme », d'où l'impossibilité de poursuivre la procédure sans saisine du CRD de l'ARMP.

Il découle donc de ces deux dispositions que les avis de la DCMP ont une portée variable en fonction de l'objet de la consultation.

Quant au terme « autorisation » au sens du Code des marchés publics, il désigne le nécessaire accord que l'Autorité contractante doit avoir de la part d'un organe qui a été sollicité à cet effet. Cette autorisation a la même portée qu'un avis conforme. C'est dans ce sens qu'il convient de comprendre l'article 9 du code qui dispose : *« Au cours de la phase de préparation des marchés, l'Autorité contractante doit (...) obtenir le cas échéant, les autorisations préalables auxquelles la conclusion du marché est soumise, sous peine de nullité... »*.

IV.2.1.c : Réserves

Il faut comprendre cette notion de « réserves » comme étant l'expression d'un doute que manifeste, sur tel ou tel autre aspect de la procédure ou du dossier, l'organe de contrôle bien qu'un avis favorable soit formulé. Ces réserves doivent être toujours motivées.

La DCMP peut en effet considérer une procédure globalement régulière mais tout en soulevant un manquement qui n'est pas substantiel au demeurant. C'est cette situation que prévoit l'article 142.2 du Code des marchés publics qui dispose « *si l'autorité contractante passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable de la Direction chargée du contrôle des Marchés publics sur un dossier d'appel à la concurrence, elle doit motiver sa décision par écrit et en rendre compte à l'autorité d'approbation du marché dont elle relève et en informer l'Organe chargé de la Régulation des Marchés publics* ».

La décision de ne pas prendre en compte les réserves formulées par la DCMP ne peut donc pas être implicite et isolée. Si elle décide de poursuivre la procédure en l'état, l'Autorité contractante doit établir les motifs pour lesquelles elle a décidé de ne pas tenir compte desdites réserves et les transmettre (accompagnées de l'avis de la DCMP) aux autorités visées par cet article 142.2.

IV.2.1.d. Délais de contrôle

La DCMP rend ses avis dans des délais très stricts. Conformément aux dispositions de l'article 142 du CMP, ces délais sont fixés par décision de l'ARMP. En l'absence d'une réponse dans le délai imparti, l'avis de la DCMP est réputé favorable et la procédure de passation du marché peut se poursuivre.

Ces délais auxquels fait référence l'article 142 du Code ont été fixés de la façon suivante :

- avis sur tout dossier d'appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de consultation : 10 (dix) jours ouvrés à compter de la réception du dossier par la DCMP.
- avis sur les documents d'analyse comparative des offres et d'attribution provisoire du marché ou de la délégation de service public :
 - pour les marchés ou délégations dont le dossier d'appel à la concurrence a fait l'objet d'une revue préalable : 5 (cinq) jours ouvrés à compter de la date de réception du dossier par la DCMP ;
 - pour les marchés ou délégations dont le dossier d'appel à la concurrence n'a pas fait l'objet d'une revue préalable : 7 (sept) jours ouvrés à compter de la date de réception du dossier par la DCMP ;
- avis juridique et technique sur les projets de marchés ou de convention de délégation de service public : 5 (cinq) jours ouvrés à compter de la date de réception du dossier par la DCMP.

Ces délais sont dits « *francs* » et c'est une règle générale applicable aux actes de l'Administration publique, donc à ceux de la DCMP.

Pour leur calcul, il faut les comprendre comme étant des jours entiers (de 0 à 24h). Un délai calculé en jour franc ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire au premier jour ouvrable suivant.

Pour les marchés relevant d'une urgence impérieuse ou devant être passés dans le cadre de mesures de mobilisation générale et de mise en garde, l'article 76 du Code des marchés publics indique que la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics devra se prononcer dans les vingt quatre heures.

IV.2.1.e. : Désaccords entre l'Autorité contractante et la DCMP

Compte tenu des missions de la DCMP en matière d'examen des projets de marchés, des désaccords peuvent également survenir en cette matière entre l'autorité chargée du contrôle et l'Autorité contractante.

L'article 142 du Code des marchés publics renvoie à deux types de situations :

- soit le désaccord porte sur le choix du recours à une procédure autre que l'appel d'offres ouvert ou sur la proposition d'attribution du marché et dans ces cas elle ne peut poursuivre la procédure et doit saisir le CRD ;
- soit le désaccord porte sur le dossier d'appel à la concurrence et dans ce cas, elle doit informer l'autorité d'approbation ainsi que l'ARMP. Cette information doit être fournie de manière écrite et motivée ; l'Autorité contractante devra, à cet effet, préciser les raisons factuelles ou juridiques qui justifient son désaccord avec l'avis défavorable ou les réserves de la DCMP.

Quant au délai de traitement des dossiers qui lui sont soumis pour immatriculation, la DCMP dispose de trois (3) jours francs pour y procéder

IV.2.2 L'organe de régulation et de contrôle a posteriori

L'article 30 du COA précise que l'ARMP est chargé d'assurer des missions de contrôle a posteriori du respect de la réglementation ; le même article confère à la DCMP la mission de contrôle a priori des procédures de passation. Cette séparation institutionnelle des missions de contrôles a priori et a posteriori est également confirmée par le Code des marchés publics.

Le contenu de cette mission de contrôle a posteriori défini à l'article 145 du CMP ne se limite pas aux opérations d'audits indépendants commandés annuellement, mais inclut également des contrôles qui peuvent être exercés à tout moment portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures d'élaboration des DAO, de passation ainsi que des conditions d'exécution des marchés publics. C'est également la conclusion à laquelle conduit l'analyse des dispositions des articles 2.6, 8 et 9 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.

En l'état des textes réglementaires applicables, la DCMP n'a donc pas de pouvoir de contrôle a posteriori. C'est ce que confirment d'ailleurs l'article 2 du décret portant création de cette entité et l'article 85 du CMP.



V. LES REGLES DE PREPARATION DES MARCHES PUBLICS



V.1 La définition des besoins

C'est une étape importante de la préparation du marché puisque matérialisant la détermination de l'objet des prestations envisagées par l'Autorité contractante. L'article 5.1 du CMP dispose sur ce point : « *avant tout appel à la concurrence, consultation ou négociation, l'Autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. Les fournitures, services ou travaux qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à ces besoins* ». Cette détermination des besoins doit être juste, pertinente et complète. A ce stade, les études préalables sont fortement recommandées surtout pour les projets dont l'Autorité contractante ne peut elle-même procéder à la définition exacte de ses besoins. Plus les besoins sont définis avec toute l'exactitude requise par l'article 5 du Code, plus l'évaluation de leurs seuils financiers (article 54) sera facilitée. Quelques indications sont données ci-après.

Pour les marchés de travaux

Dans un premier temps, l'Autorité contractante procède à leur définition conformément à l'article 5 précité. Ensuite, elle prendra en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération portant sur un ou plusieurs ouvrages. Il y a opération de travaux lorsque la PRMP décide de mettre en œuvre dans une période de temps et dans un périmètre délimité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable (article 54.1 du CMP).

Une **opération** peut consister :

- en plusieurs ouvrages si elle porte sur des travaux de même nature, exécutés dans un périmètre géographique délimité (Exemple : la réfection des toitures des écoles d'une même commune ou la réalisation de trottoirs dans différents quartiers de la ville, car il en résulte une unité fonctionnelle).
- en travaux de nature différente si ceux ci sont réalisés sur un même ouvrage et sont programmés au même moment, par exemple en matière de réhabilitation d'un même bâtiment ou ensemble de bâtiments.

En revanche, plusieurs chantiers comportant des travaux de plusieurs types qui concernent des ouvrages différents ne constituent pas une même opération s'il n'existe pas d'unité fonctionnelle du fait de la variété de travaux envisagés, même s'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet global. Un ouvrage peut être défini comme le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir, par sa nature même, une fonction économique ou technique (Exemple : un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, un ouvrage d'infrastructure tel qu'un collecteur des eaux pluviales). L'Autorité contractante doit ainsi prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation qu'elle met à disposition des opérateurs. L'addition de ces deux valeurs lui permettront de savoir si elle a dépassé ou non lesdits seuils.

Pour les marchés de fournitures et les services

En ce qui concerne les fournitures et les services, l'Autorité contractante procède également à leur définition conformément à l'article 5 précité. Ensuite, tout en prenant en compte les indications de l'article 54 du CMP en ses points 2 et 3, il est procédé à une estimation sincère de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent raisonnablement être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année. Cette catégorie homogène de fournitures ou de prestations de services est constituée :

- soit en raison de leurs caractéristiques propres, indépendamment de l'activité de leur utilisateur. Par exemple : des meubles de bureaux constituent une catégorie d'achats homogène en raison de leurs caractéristiques propres même s'ils sont destinés à des services exerçant des activités de natures différentes ;
- soit du fait de leur destination commune, alors qu'ils sont de nature différente. Par exemple : les achats de matériels et mobiliers destinés à équiper un hôpital ou une salle d'opérations sont destinés à une même unité fonctionnelle et doivent être considérés comme une seule opération d'achat même s'ils portent sur des biens de nature différente. Cette notion, qui doit s'apprécier au cas par cas en fonction des prestations attendues, suppose une pluralité de services ou de fournitures concourant à un même objet. Dans cette hypothèse, l'ensemble des prestations nécessaires à l'élaboration d'un projet, et faisant partie d'un ensemble cohérent, sont prises en compte de manière globale. Si le montant total de cette évaluation est supérieur aux seuils de procédures précisés par les dispositions précitées, l'Autorité contractante devra s'y conformer.

Il est exigé des Autorités contractantes une très grande rigueur dans l'application de ces textes sur la définition des besoins et de leur évaluation et d'éviter ainsi tout fractionnement malintentionné. L'article 54 du Code du marché précise en ses points 4 et 5 que la valeur estimée des marchés comportant des lots doit prendre en compte la valeur, estimée de la totalité des lots et que les Autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sous-estimer la valeur des marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du Code.

Un contrôle strict sera exercé par la DCMP, dans les conditions précisées dans le présent guide, sur toutes ces opérations de définition des besoins, de leur évaluation et de la pertinence de l'allotissement.

V.2 La planification de la passation des marchés

V.2-a : Les plans de passation des marchés

Dans le cadre du respect des principes énoncés ci-dessus, les procédures de passation des marchés doivent être planifiées et cette planification doit également faire l'objet de procédures de publicité appropriées.

L'Autorité contractante doit ainsi élaborer et transmettre à la DCMP pour vérification de la conformité et publication dans le site web des marchés publics, un plan de passation de marchés selon le modèle adopté par l'ARMP. Ce plan est susceptible d'être mis à jour en fonction des nécessités dictées par le programme de travail de chaque structure.

L'attention des Autorités contractantes est attirée sur le fait que l'élaboration du programme de passation de marchés ne doit pas être subordonnée à la disponibilité préalable de ressources budgétaires. En effet, la fonction d'outil de planification, assignée au plan de passation de marchés, ne s'affirme que si les informations à l'état prévisionnel, sont publiées en légère anticipation par rapport à la date de notification des budgets.

Toutefois, ce plan, qui est intégré dans le processus d'élaboration du budget des Autorités contractantes, est défini sur une base annuelle ; sous réserves des révisions éventuelles, il ne saurait être modifié ou transmis à la DCMP à l'occasion de la communication pour avis des dossiers d'appel d'offres ou de consultation.

L'élaboration et la publication dans les conditions requises d'un plan de passation des marchés est une formalité substantielle qui s'impose à toute Autorité contractante. Le non respect de cette formalité entraîne l'annulation de la procédure de passation d'un marché non préalablement inscrit au PPM.

V.2-b. : La publicité des opérations de planification

«L'infructuosité» de nombreuses consultations, faute de n'avoir pas été programmées à temps pour permettre aux candidats potentiels d'y répondre, l'usage excessif de la procédure d'urgence, ainsi que celle de l'entente directe en dehors des conditions limitativement prévues par la réglementation, s'expliquent en partie par l'absence de planification du processus de passation des marchés.

Il ne faut pas confondre les modalités de publication du Plan annuel de passation des marchés publics et celles de l'Avis général. A ce niveau, il faut faire une lecture combinée des articles 6 et 56 du Code des marchés Publics.

i) La publication du Plan annuel de passation des marchés publics

Si l'élaboration de ce document relève de la compétence des Autorités contractantes elles-mêmes, selon un modèle établi par l'ARMP, sa publication est du ressort de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics. Celle-ci fera apparaître ces Plans sur le portail des marchés publics : (www.marchespublic.sn)

Dès que le Plan est publié, l'Autorité contractante concernée devra immédiatement vérifier leur conformité (par rapport au document transmis à la DCMP). En cas d'erreur ou d'omission, il faudra immédiatement en faire part à la DCMP afin que celle-ci procède à la rectification avant d'effectuer une nouvelle publication.

ii) la publication de l'Avis général

L'Avis Général est élaboré par l'Autorité contractante. Cet Avis doit être exhaustif ; à cet effet, il comportera tous les projets qui figurent dans le Plan de passation des marchés publics et qui atteignent les seuils de passation de marchés par appel d'offres ouvert.

A quelle période faut-il procéder à la publication de l'Avis général ?

Cette publication doit intervenir au plus tard le 15 janvier de l'année prévue pour leur passation.

Quel support de publication utiliser ?

Ces Avis doivent cumulativement être publiés au moyen des supports ci-après :

- le portail des marchés publics (www.marchespublics.sn) ;
- un journal quotidien de grande diffusion (au minimum) ;

Si l'Autorité contractante fait une insertion de son Avis général dans un support électronique (son site Internet, par exemple), cette publication ne peut nullement être exclusive ; elle doit nécessairement être en complément de celles visées ci-dessus.

En outre, même si l'article 56 du Code des marchés publics ne le précise pas, la publication sur le portail sus-indiqué et celle effectuée dans un quotidien doivent rigoureusement être identiques quant à leur contenu ; au nom du principe de la mise en concurrence effective, elles ne doivent pas comporter des indications contraires susceptibles d'informer différemment les potentiels candidats.

Concernant l'application des règles procédurales qui se rapportent au plan annuel de passation, il faut se référer à l'article 6 du CMP. Cette disposition précise que les Plans de passation de marchés doivent être communiqués à la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée ; celle-ci vérifie la conformité du document et en assure la publication dans les trois (03) jours francs suivant la réception.

Des précisions sont apportées sur la suite procédurale après la transmission à la DCMP de ces plans de passation. En effet, si la Direction chargée du contrôle des marchés publics émet des observations sur la conformité du plan, l'Autorité contractante dispose d'un délai maximal de sept (07) jours pour tenir compte de ces observations. Passé ce délai, la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics publie la dernière version soumise et informe l'organe chargé de la Régulation des Marchés publics sur les observations faites et non prises en compte.

Une fois publiés, les outils de planification doivent être mis à jour périodiquement de manière à intégrer les réajustements postérieurs.

Ne peuvent pas figurer dans le Plan annuel ni dans l'Avis général publié :

- i) les marchés relevant du secret ou dont l'exécution doit d'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
- ii) les marchés pour lesquels, l'urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à l'autorité contractante.
- iii) les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde.

Pour la première catégorie de marchés, cette dérogation s'explique par le fait que la nature des prestations envisagées est incompatible avec toute mesure de publicité.

Pour les deux dernières catégories de marchés, c'est une dérogation qui trouve son fondement dans le fait que ces besoins ne sont pas raisonnablement prévisibles au moment de l'élaboration des documents de planification.

Comme autre dérogation, on peut ajouter que du fait de leur faible montant et du peu de formalisme caractérisant leur procédure de passation, les DRP simple peuvent ne pas être inscrites sur ce Plan annuel.

V.2- Les règles applicables en matière de révision des plans

Les Plans de passation des marchés publics peuvent faire l'objet de révision pour tenir compte de l'évolution des besoins de l'Autorité contractante ou de changements de circonstances.

Le Plan révisé est publié à nouveau par la DCMP dans les mêmes conditions que le document initial.

V.3 L'allotissement du marché

Le processus de détermination des besoins de l'Autorité contractante peut la conduire à user de la procédure d'allotissement.

L'allotissement est particulièrement approprié lorsque la consistance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d'une seule entreprise. Il en est de même lorsque les délais d'exécution requis ne peuvent être tenus par une seule entreprise sans dépenses supplémentaires de nature à augmenter inutilement le coût d'un projet.

C'est ce que précise d'ailleurs l'article 8 du CMP qui dispose que *« les travaux, fournitures ou services peuvent être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques ou financiers y compris, en vue de faciliter la candidature des PME. Ce choix ne doit pas avoir pour objet, ou pour effet, de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret »*.

Le choix entre un marché en lot unique et un marché en lots séparés doit se faire sur la base de considérations d'ordre économique, financier et technique, laissées à l'appréciation de l'Autorité contractante, sous réserve du respect des principes de transparence et de libre concurrence.

L'Autorité contractante a intérêt à recourir à un marché en lot unique lorsque :

- l'allotissement présente un inconvénient technique lié à la cohérence de la prestation ou à l'incapacité de l'Autorité contractante à assurer le pilotage et la coordination de plusieurs lots ;
- l'allotissement présente un inconvénient financier inhérent à l'existence de charges fixes incompressibles se rapportant à chaque lot.

Les Autorités contractantes sont en revanche encouragées à privilégier la passation de leurs marchés en lots séparés afin de faciliter aux PME l'accès à la commande publique.

L'Autorité contractante a aussi l'obligation de ne pas entraver la concurrence en favorisant certains opérateurs par une définition artificielle du ou des lot (s). Chaque lot doit en principe constituer une unité autonome pouvant être attribuée séparément et ne comporter que des prestations homogènes susceptibles d'être réalisées par une même entreprise à moins bien sûr que le lot ne comporte des prestations indissociables.

Chaque lot donne lieu à un marché distinct. Lorsqu'une même entreprise est retenue pour plusieurs lots, un marché est passé pour chaque lot séparément. Cela implique donc qu'un acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché pour chacun des lots.

Mais si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché, et donc un seul acte d'engagement, regroupant tous ces lots. Seulement, une telle possibilité ne constitue pas une exception au principe indiqué ci-dessus et selon lequel il y a autant de marchés que de lots. Il ne s'agit que d'une commodité pratique destinée à faciliter la procédure de finalisation du processus de conclusion du marché. Elle constitue ainsi, un allègement pour les marchés (et accords-cadres) comportant un nombre très important de lots.

Ces indications ne sont pas contradictoires avec le point de l'article 54 du Code des marchés publics. Celui-ci pose notamment le principe selon lequel « *La valeur estimée des marchés comportant des lots doit prendre en compte la valeur, estimée (...) de la totalité des lots (...)* ».

Cette règle implique donc que la passation de chaque marché constitué d'un lot déterminé devra suivre le formalisme applicable aux procédures prévues à l'article 53 du Code, si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils définis par celui-ci.

Cette règle d'estimation globale de la valeur d'un marché implique également une stricte application de l'article 29 du Code traitant des autorités d'approbation, si le montant total des lots atteignent ou dépassent les seuils visés à cet article. En d'autres termes, si ces seuils sont atteints ou dépassés, chaque lot du marché en question devra être approuvé par l'autorité correspondante, conformément à l'article 29 du CMP.

En tout état de cause, la dévolution des marchés en lots ne doit pas être le prétexte pour l'introduction de critères discriminatoires dans le DAO. D'ailleurs, dans le cadre de sa mission de contrôle a priori, la DCMP peut inviter les Autorités contractantes à modifier l'allotissement de certains marchés jugés non conforme aux exigences de transparence.

Le Comité de Règlement des Différends peut également, suite à des recours introduits par des candidats qui dénoncent le caractère discriminatoire de certains allotissements, ordonner la suppression des clauses incriminées dans les DAO.

V.4 L'élaboration de documents types de passation de marchés

Afin de mettre un terme aux situations conflictuelles engendrées par la mauvaise qualité des documents contractuels, notamment dans le cas des marchés dont les DAO ne sont pas soumis à la revue préalable de la DCMP, des documents types ont été élaborés à l'intention des Autorités contractantes.

En effet, une pratique harmonisée de la passation de marchés suppose l'existence d'instruments uniformisés à l'usage des acteurs impliqués.

C'est pour répondre à ce besoin qu'il a été conçu des supports documentaires parmi lesquels :

- les Cahiers des Clauses administratives générales pour chaque type de marchés ;
- des Dossiers d'Appels d'Offres types pour les travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles ;
- des modèles d'avis d'appels d'offres, de garantie de soumission, de garantie d'avance et de garantie de bonne exécution ;
- des modèles de procès-verbal d'ouverture des plis, de procès-verbal d'attribution de marchés, de procès-verbal de carence, de procès-verbal de négociation ;
- des modèles de contrats avec les clauses minimales à insérer pour les travaux, fournitures et prestations intellectuelles.

Les communes dont le budget est inférieur à trois cent millions de francs CFA (si le marché est imputable sur ce budget) peuvent, en deçà de certains seuils définis (cinquante millions pour les travaux et vingt cinq millions pour les fournitures et services) utiliser des dossiers d'appel d'offres standards spécifiques mis à leur disposition par l'ARMP.

Les Autorités contractantes doivent utiliser ces documents types mis à leur disposition sur le portail national dédié aux marchés publics.

V.5 Les critères de qualification

L'article 27 nouveau du COA précise que « *dans le respect des principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats, les acheteurs publics peuvent requérir des candidats aux marchés toute justification concernant notamment :*

- leur situation juridique y compris leur capacité de contracter et de poursuivre leurs activités ;
- les moyens matériels, humains et financiers dont ils disposent ;
- l'expérience acquise dans la réalisation d'activités analogues à celle faisant l'objet du marché ;
- l'absence de disqualification ou condamnation de l'entreprise candidate ou de ses dirigeants liée à la passation ou à l'exécution de marchés publics ou à leur activité professionnelle ;
- la régularité de leur situation vis-à-vis de l'Administration fiscale ou des organismes de protection sociale ».

Les dossiers d'appel d'offres doivent en conséquence définir des critères de qualification respectant les principes rappelés ci-dessus, excluant toute référence à caractère discriminatoire ou destinée à favoriser tel ou tel candidat. Etant défini en conformité avec l'objet du marché, ces critères ne sauraient avoir pour effet également d'exclure ou de réduire la participation des PME à la commande publique.

Les capacités techniques et financières requises visées à l'article 44 du Code des marchés publics doivent toujours être en conformité avec l'objet et l'ampleur des prestations. Même si l'article 44 susvisé ne le prévoit pas, une certaine souplesse est à observer relativement aux documents qui établissent ces capacités. Cette souplesse concerne les entreprises nouvellement créées.

Pour ces dernières, les références pour les marchés similaires, qui sont exigées pour établir la capacité technique de l'entreprise peuvent être remplacées par tout document de nature à établir le profil technique, l'expérience et la formation du Personnel clé proposé ou alors par le terme marché similaire en termes de complexité.

Egalement, pour favoriser l'accès à la commande publique aux entreprises nouvellement créées non assujettie à une expérience mais disposant d'un personnel qualifié et d'une bonne assise financière, il pourrait être fi de l'expérience similaire en termes de réalisation en mettant plutôt l'accent sur celle du personnel clé.

Pour les capacités financières auxquelles fait référence le même article 44 du CMP, en lieu et place des chiffres d'affaires des trois dernières années, une entreprise nouvellement créée peut produire son bilan d'ouverture ou tout document établi par un établissement bancaire agréé précisant que celle-ci disposent dans son compte de ressources suffisantes ou bénéficie de facilités de caisse, afin d'assurer une bonne exécution des prestations objet de la procédure dans le cadre de laquelle elle soumissionne.

Le CRD est chargé d'examiner tout recours portant sur les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées et de façon générale la conformité des documents d'appel d'offres.

La justification des capacités techniques et de la qualification d'un soumissionnaire pose souvent des problèmes d'interprétation des règles du Code des marchés publics.

Les exemples suivants illustrent ce constat.

Une clause exigeant des candidats à un marché de fournitures de véhicules, l'autorisation du constructeur est-elle de nature à entraver l'accès au marché des candidats non liés aux fabricants par un accord de vente ?

Cette question a été soulevée devant la CRD par la société Universal Auto, dans le cadre des appels d'offres suivants : Appel d'Offres n° 02/2010/MDCL/DADL lancé par la Direction d'Appui au Développement local (DADL), l'Appel d'Offres n° 01/PEJU 1 DMF 01 lancé par la Direction de la Micro finance et l'Appel d'Offres n° VE/ANCAR 01/2009 lancé par l'ANCAR⁵.

Dans sa saisine du 15 juillet 2010, la société Universal Auto dénonçait, comme enfreignant les règles de la concurrence, le fait pour les autorités contractantes d'exiger des candidats aux marchés de fourniture de véhicules neufs la production de l'autorisation du constructeur.

Se prévalant de son statut de revendeur indépendant des réseaux des constructeurs, Universal auto déclare s'approvisionner en toute légalité auprès de compagnies de distribution internationales en Europe, en Asie et aux USA. Elle déclare inscrire ses actions dans le respect des règles régissant la vente des véhicules neufs, notamment en assurant les garanties requises, un service après vente performant et un service technique doté d'outillages modernes et de personnel qualifié.

Pour apporter une réponse à la question posée, le CRD invoqua des textes autres que ceux visés par la société Universal Auto.

S'appuyant sur le Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles, pris en application de l'article 88 du Traité instituant l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, ainsi que sur l'article 24 du COA, le CRD donna raison à la société susvisée. Une partie du raisonnement du CRD est reproduite ci-après :

« Considérant qu'en matière d'achats, l'article 24 nouveau du Code des obligations de l'Administration garantit aux candidats aux marchés publics la liberté d'accès à la commande publique et l'égalité de traitement ; qu'à cet effet, l'article 27 nouveau dispose que si l'autorité contractante peut requérir des candidats au marché toute justification, c'est dans le respect de ces principes ;

Que l'autorité contractante ne peut donc rompre l'égalité des candidats en insérant dans l'expression de ses besoins ou dans les critères de sélection des candidats, des clauses de nature à entraver l'accès au marché ;

Considérant que la clause relative à la production par les candidats au marché de véhicules neufs de l'autorisation du constructeur tend à ressusciter les accords croisés de répartition des marchés ou des sources d'approvisionnement particulièrement restrictives pour la concurrence et contraires aux objectifs de marché commun ; que l'accès du marché est nécessairement entravé lorsqu'un grand nombre de distributeurs sur ce marché sont liés par l'obligation de ne vendre que les produits du fabricant avec lequel ils ont un contrat ou des accords verticaux ayant un effet similaire d'exclusion des tiers comme les revendeurs indépendants ;

⁵avis n° 017/10/ARMP/CRD du 11 août 2010 du CRD statuant en commission Litiges sur la saisine de la société Universal Auto dénonçant la pratique qui consiste à exiger des candidats aux marchés de fourniture de véhicules neufs, l'autorisation du constructeur comme enfreignant les règles de la concurrence en ce qu'elle exclue les vendeurs d'automobiles indépendants du réseau des constructeurs.

Considérant par ailleurs, que quel que soit le vendeur, celui-ci est tenu des obligations légales de garantie d'éviction et de vices cachés ;

Qu'en considération de ces éléments et de la possibilité pour l'Autorité contractante de requérir des candidats un certificat d'authenticité, il convient de déclarer irrégulière et contraire aux règles de concurrence et de libre accès aux marchés publics, l'inclusion dans les DAO d'une clause relative à l'autorisation du constructeur ».

A la lumière de cet avis du CRD, il faut juste préciser que pour une meilleure application de l'article 44 du CMP, notamment en ce qui concerne la capacité ou le savoir faire des candidats, il est important d'éviter, autant que possible, d'exiger la production d'une pièce spécifique sans aucune possibilité de fournir un document différent mais de nature à rassurer objectivement l'Autorité contractante.

- Les capacités et qualifications d'un sous-traitant peuvent-elles servir au soumissionnaire principal pour justifier les siennes' ?

Par lettre du 28 janvier 2014, l'entreprise SARRE-CONS a saisi le CRD d'une demande d'avis relative à l'interprétation du critère de qualification « *disposer d'un service après-vente et d'un magasin de pièces de rechange* » dans le cadre des marchés publics d'acquisition de véhicules.

A l'appui de sa demande, la société SARRE-CONS expose qu'elle commercialise depuis plusieurs années des véhicules neufs. Le requérant précise également que pour les interventions sur les véhicules, il a signé des conventions avec différents garages, sélectionnés sur des critères de professionnalisme et d'expérience.

Cependant, le requérant soutient qu'au-delà des conventions, il reste lié sur le plan contractuel, par les clauses du marché dès que ledit marché est signé. Par conséquent, il ne peut se soustraire à l'obligation d'offrir un service après-vente si ce critère est exigé.

C'est pourquoi, pour préserver la qualité des prestations tout en étant totalement conforme aux lois et règlements en vigueur vis-à-vis des clients du secteur public, la société SARRE-CONS sollicite l'avis du CRD pour une bonne compréhension de la sous-traitance, prévue dans le Code des marchés publics.

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d'avis a pour objet d'inviter le CRD à se prononcer sur le critère relatif à l'exigence de disposer d'un service-après vente et d'un magasin de pièces de rechanges, notamment, **la possibilité pour un soumissionnaire de s'appuyer sur un sous-traitant pour justifier ce critère.**

6AVIS N° 002/14/ARMP/CRD DU 19 février 2014 du Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges sur la demande de la société SARRE-CONS relative à l'interprétation du critère « *disposer d'un service après-vente et d'un magasin de pièces de rechange* » dans les marchés publics d'acquisition de véhicules.

Le CRD adopta le raisonnement suivant :

« (...) Considérant que la sous-traitance se définit comme l'opération par laquelle un titulaire de marché confie à un autre prestataire dénommé sous-traitant, une partie de l'exécution du contrat conclu avec l'autorité contractante dans les limites prévues par le Code des marchés publics ;

Qu'il importe d'observer que la sous-traitance permet aux soumissionnaires d'externaliser certaines tâches et de concentrer leurs moyens sur les activités qu'ils jugent stratégiques et peut constituer, en conséquence, une opportunité pour certaines entreprises ;

Qu'en outre, pour promouvoir les petites et moyennes entreprises et faciliter leur accès aux marchés publics, il y a lieu d'admettre qu'elles puissent faire état des capacités d'autres entités, notamment des sous-traitants, pour justifier les critères de qualification, à condition de prouver qu'elles ont effectivement à leur disposition, les moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché ;

Que c'est dans l'ordre d'idées qu'il est accepté que des candidats ne disposant pas de moyens matériels puissent produire des contrats de location pour justifier leur capacité technique à exécuter le marché ;

Qu'en considération des éléments ci-dessus exposés, un candidat peut bien, dans un marché de fournitures de véhicules, justifier sa qualification en s'appuyant sur un sous-traitant afin de remplir l'exigence d'un service après-vente et d'un magasin de pièces de rechange ;

Considérant toutefois qu'en cas de sous-traitance, l'entreprise titulaire du marché est pleinement responsable de la bonne exécution des prestations vis-à-vis de l'Autorité contractante ;

Que sous ce rapport, l'acceptation de la sous-traitance doit s'accompagner de mesures visant à éviter toute défaillance dans l'exécution des prestations, compte-tenu de l'importance du service après-vente dans les marchés d'acquisition de véhicules ;

Qu'à cet égard, l'Autorité contractante doit garder la prérogative d'apprécier la capacité juridique, économique, financière et technique du sous-traitant à exécuter les prestations attendues et de pouvoir l'accepter ou le refuser ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la possibilité pour un candidat aux marchés de faire prévaloir les moyens techniques d'autres entités, notamment le service-après vente et le magasin de stock de pièces de rechanges, pour prouver sa qualification peut être admise à la condition que la capacité technique et juridique de l'entité soit vérifiée et acceptée ».

V.6 La question des crédits budgétaires préalables

En application de l'article 17 du COA, « la conclusion d'un contrat susceptible d'engager les finances de la personne administrative contractante est soumise à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles d'engagement des dépenses publiques. L'inexécution de cette obligation n'est pas opposable au cocontractant de l'administration ».

Ce principe est confirmé à l'article 24 de ce même code qui précise que « la conclusion des contrats d'achat passés à titre onéreux par les acheteurs publics..... suppose l'existence de crédits suffisants..... ».

De même, l'article 9 du Code des marchés publics dispose :

« Au cours de la phase de préparation des marchés, l'Autorité contractante doit :

a) évaluer le montant estimé des fournitures, services ou travaux, objet du marché et s'assurer de l'existence de crédits budgétaires suffisants ;

b) obtenir, le cas échéant, les autorisations préalables auxquelles la conclusion du marché est soumise, sous peine de nullité, conformément au Code des Obligations de l'Administration.

Avec la nouvelle rédaction de l'article 9, les services compétents n'ont plus l'obligation de remettre au futur cocontractant, et avant la signature du marché, le document portant engagement ou autorisation des dépenses relatives au marché.

Mais l'attention des Autorités contractantes est attirée sur le fait qu'il ne faut surtout pas faire une confusion entre cette question du document portant autorisation des dépenses relatives au marché et celle qui concerne la règle de l'existence de crédits suffisants pour couvrir les prestations envisagées.

La garantie de l'existence de ces crédits budgétaires suffisants est fondamentale et est toujours en vigueur avec l'actuelle réglementation ; il est dès lors nécessaire que les Autorités contractantes transmettent ce document à la DCMP lors de la revue du contrat. D'ailleurs, l'article 85 du CMP souligne que les autorités compétentes refusent d'approuver les marchés en cas d'absence de document attestant de l'existence de crédits suffisants.

C'est dans cet esprit qu'il faut également comprendre la règle selon laquelle, en matière d'offre spontanée, le financement proposé par l'opérateur doit être mobilisé par celui-ci dès le départ, par un montage financier, complet, fiable et vérifiable⁷.

⁷Voir la partie VI.4.3 du présent guide



VI. LES FORMALITES DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS



VI.1 Le respect des délais des procédures de passation des marchés

Le respect des délais des procédures de passation des marchés est un des éléments fondamentaux de la transparence du système de passation des marchés publics, ainsi que de sa performance et les Autorités contractantes doivent particulièrement être vigilantes à ce niveau.

Il est spécifié qu'aux termes du Code des marchés publics, sauf précision contraire, les délais sont exprimés en jours calendaires.

VI.1.a. : Pour les candidats et soumissionnaires

Ces délais doivent permettre aux candidats de disposer d'un temps raisonnable pour préparer leur soumission. Ils peuvent être raccourcis en cas d'accès libre, direct et complet au dossier d'appel à la concurrence par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 63 du CMP.

Le point VI.4.4 du présent guide reprend les réductions des délais visés à l'article 63 précité.

VI.1.b. : Pour les Autorités contractantes

Pour les Autorités contractantes, le respect des délais de la procédure est tout aussi fondamental, notamment au stade de l'ouverture des offres, de leur évaluation, comme de la signature des marchés.

- Au stade préalable à l'ouverture des offres

Les procédures doivent être mises en œuvre conformément au calendrier fixé dans les plans de passation des marchés. Quant aux dossiers d'appel d'offres, ils doivent être rendus disponibles dès le lancement de la procédure. De même, et sauf en cas de modification du dossier d'appel d'offres à une date trop proche de celle fixée pour la remise et l'ouverture des offres, cette dernière ne saurait être modifiée afin de ne pas affecter l'égalité de traitement des candidats et soumissionnaires.

- Au stade de l'évaluation

Il est nécessaire pour l'Autorité contractante, d'opérer son choix dans le délai de validité des offres qui est de 90 jours. Sauf en cas de complexité particulière du marché, il est précisé à l'article 70 du CMP que la Commission compétente doit faire sa proposition d'attribution dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de l'ouverture des offres. On peut en déduire que les opérations d'évaluation doivent alors s'effectuer dans ce même délai de quinze (15) jours calendaires.

L'éventuelle complexité des opérations justifie que cette même disposition précise qu'exceptionnellement, ce délai puisse faire l'objet de prorogation dans la limite maximale de dix (10) jours, sur demande motivée de l'Autorité contractante adressée à la Direction chargée du contrôle des marchés publics. La motivation de cette demande de prorogation doit être rigoureuse ; à cet effet l'Autorité contractante peut s'appuyer sur :

- le nombre très important d'offres à évaluer ;
- la complexité des prestations objet du marché ;
- la multitude des critères d'évaluation ;
- etc.

La commission des marchés compétente dresse dans les trois (3) jours qui suivent la fin de ses travaux d'évaluation un procès-verbal dans lequel elle relate les circonstances de son analyse, c'est ce que précise l'article 84 du CMP.

- Au stade de l'approbation du choix de la Commission des marchés

La Commission des marchés fait une proposition d'attribution du marché à l'Autorité contractante. La décision de cette dernière doit intervenir dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision de la commission ou l'avis de la DCMP, conformément aux dispositions de l'article 84-3 du CMP. De fait, les délais courent systématiquement à compter de ce dernier avis dès lors que les seuils de contrôle sont atteints. En deçà des seuils de contrôle, lesquels sont toujours déterminés par une estimation globale du marché, le délai doit également courir à compter de l'avis de la DCMP, dès lors qu'il y a désaccord de l'Autorité contractante avec la Commission des marchés.

A ce stade, un autre délai doit éventuellement être observé par l'Autorité contractante. En effet, en cas de désaccord avec l'avis de la DCMP, elle peut saisir le Comité de Règlement des Différends de l'ARMP, mais elle doit le faire dans un délai de trois jours ouvrables. Ce délai court à partir de la réception des recommandations de la DCMP.

- Au stade de la signature du marché

Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, l'Autorité contractante publie un avis d'attribution. Le marché doit dès lors être transmis pour signature à la PRMP, dans un délai minimum de dix (10) jours suivant la publication de l'attribution provisoire ; c'est ce que prévoit l'article 85 du Code des marchés publics. Le respect de ce délai est très important car la signature ne doit pas intervenir dans un délai inférieur à ces dix (10) jours. Cette règle se justifie par la nécessité de laisser aux candidats évincés, un délai raisonnable pour soumettre à l'Autorité contractante, leurs contestations éventuelles dans le cadre du recours prévu à l'article 89 du Code des marchés publics.

Ce recours a ainsi pour effet de suspendre immédiatement la procédure de passation du marché conformément aux dispositions de la Directive UEMOA n°5/2005 qui précise d'ailleurs en son article 11 que le recours exercé auprès de l'Autorité contractante a pour effet de suspendre la procédure d'attribution jusqu'à la décision définitive de l'Autorité contractante, hiérarchique ou de l'Autorité de Recours non juridictionnels.

- Au stade de l'approbation

Le délai dans lequel cette approbation par les autorités compétentes visées à l'article 29 du CMP doit être donnée ou refusée est fixé à l'article 85 du CMP qui dispose que*«(...) l'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les quinze(15) jours de la transmission du dossier d'approbation (...)»*.

Au stade de la publication de l'avis d'attribution définitive

Le délai à respecter dans cette ultime phase est de quinze (15) jours (4ème alinéa de l'article 86 du CMP) suivant la notification du marché.

VI.2 L'obligation de fournir les documents relatifs à la passation aux autorités compétentes

La transparence des procédures est un principe fondamental de la passation des marchés publics ; elle est aussi une condition de la régulation du système, fonction qui garantit en définitive l'égal accès à la commande publique et l'égalité de traitement des candidats et soumissionnaires.

Cette transparence nécessite une communication volontaire de la part des Autorités contractantes tant vis à vis des candidats et soumissionnaires que des autorités de contrôle et de régulation de l'ensemble des documents relatifs aux procédures de passation des marchés et délégations de service public tant à l'occasion de la mise en œuvre des fonctions de passation, de contrôle ou de régulation que pour servir l'objectif de nourrir les outils de gestion et de statistique du système.

A cet effet, l'article 2.11 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ARMP charge cette dernière de collecter toute documentation et statistique, relatives aux procédures de passation, d'exécution ou de contrôle des marchés publics et des délégations de service public; à cet effet, l'ARMP reçoit des Autorités contractantes copies des avis, autorisations, procès verbaux, rapports d'évaluation, marchés et de tout rapport d'activité dont il assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés et conventions, **sous peine de rejet, par l'organe de contrôle, des dossiers ne respectant pas cette formalité.**

Le défaut de communication des documents susvisés est donc clairement sanctionné.

L'Autorité de régulation n'étant saisie, en dehors de la gestion des recours, qu'a posteriori dans le cadre de ses missions de revue de la conformité de la passation des marchés des Autorités contractantes ou d'inspection, il revient donc à l'organe de contrôle a priori la charge de s'assurer lors de la transmission des dossiers soumis à son contrôle que les documents susvisés ont également été transmis à l'ARMP par les Autorités contractantes, et d'en informer l'ARMP.

VI.3 Les formalités de publicité

La publicité est un principe fondamental de la commande publique. Elle est le corolaire de la transparence du système et a une triple utilité. Elle permet à l'Autorité contractante de faire connaître ses besoins aux candidats potentiels. Elle assure le libre accès à la commande publique de l'ensemble des prestataires intéressés et garantit donc une véritable mise en concurrence.

VI.3.a. : Comment procéder à la publication des appels d'offres ?

Aux termes de l'article 56 (alinéas 2 et 3) du CMP, *«chaque marché public passé par appel d'offres est précédé d'un avis d'appel public à la concurrence établi conformément à un modèle type fixé par voie réglementaire»* ;

Les avis d'appel public à la concurrence sont publiés sur le portail officiel des marchés publics et au moins dans un journal quotidien de grande diffusion (...) »

L'efficacité de la publicité est déterminante pour répondre aux objectifs de transparence.

VI.3.b. : Le support de la publication

L'article 56 susvisé précise en son alinéa 3 qu'il doit s'agir d'un journal quotidien de grande diffusion. La grande diffusion s'exprime par le nombre d'exemplaires vendus, l'étendue de la diffusion sur tout le territoire national, et l'accessibilité sans délai du quotidien le jour de la publication dans les lieux de diffusion ; les Autorités contractantes ont donc une parfaite liberté de choisir tout quotidien qui réponde à ces critères. En plus de cette publicité au moyen d'un journal quotidien de grande diffusion, l'avis doit paraître également sur le portail des marchés publics : www.marchespublics.sn.

Pour une nécessité de coordination entre la publicité nationale et celle communautaire évoquée par cet article, il faut prendre en considération l'article 41 de la directive n°04/2005/CM/UEMOA. En application de cette disposition, c'est à la Commission d'abord de procéder à la publication de l'avis. Cette publication communautaire doit intervenir douze (12) jours ouvrables au plus tard après la réception de l'avis par la Commission. En cas d'urgence, ce délai est réduit à cinq (5) jours ouvrables.

Toutefois, à défaut de publication par la Commission de l'UEMOA dans les délais impartis par la Directive susvisée, l'Autorité contractante nationale peut procéder à la publication prévue à l'article 56 du Code des marchés publics.

S'il s'agit d'un appel d'offres international, la publicité de l'avis doit paraître sur une publication à large diffusion internationale. L'utilisation d'une revue internationale vient s'ajouter à la publication effectuée sur le portail des marchés publics et même dans un journal quotidien de grande diffusion.

Même si l'article 56.3 ne le précise pas, toutes les publicités portant sur le même marché et effectuées au moyen de supports différents, doivent obligatoirement être identiques quant à leur contenu. En outre, en cas de pluralité de publication portant sur le même marché, si les avis suivants ne font pas référence au premier, la date de parution du dernier (avis) sera prise en compte pour le calcul des délais de soumission.

VI.3.c : La spécificité de la publicité pour les marchés de certaines communes

Certaines communes bénéficient d'un régime spécifique en matière de publication d'avis. Annoncés dans un premier temps par l'article 79 du CMP, les éléments de ce régime ont été par la suite précisés par l'arrêté n°00863 du 22 janvier 2015 du Ministre de l'Economie et des Finances pris en application de cette disposition.

En effet, pour la passation des marchés de travaux de montants estimatifs inférieurs à 50 millions FCFA TTC, ainsi que des marchés de fournitures et services (à l'exclusion des marchés de prestations intellectuelles) de montants estimatifs inférieurs à 25 millions FCFA TTC, les communes dont le budget annuel initial est inférieur à 300 millions de francs CFA, et dont les marchés sont imputables audit budget, peuvent opter pour des modalités de publicité adaptées, à savoir : l'affichage public, à la fois au niveau de leurs sièges, de ceux des préfectures ou sous-préfectures dont elles relèvent, et des chambres de métiers couvrant leurs localités, les avis généraux et spécifiques de passation de marchés, ainsi que les avis d'attribution provisoire et définitive.

Mais même si une commune donnée remplit les critères définis par cet article 79 et l'arrêté d'application précité, rien ne l'empêche de procéder à une publicité formalisée. La dérogation prévue dans ces textes n'est pas d'application obligatoire ; l'opportunité d'en faire usage est laissée à la libre appréciation des communes concernées.

VI.3.d. : Prise d'effet des délais de publication

Ces délais courent à compter de la date de publication de l'avis. En l'état des dispositions relatives aux obligations des Autorités contractantes, l'avis doit être publié sur le portail officiel des marchés publics et au moins dans un journal quotidien de grande diffusion.

Il est sans doute difficile de coordonner au jour près la publication électronique et la publication dans la presse. De même, cette dernière peut être effectuée une voire plusieurs fois par les Autorités contractantes. Les dispositions relatives à la prise d'effet des délais de publication doivent donc être interprétées comme imposant le dépôt des offres dans le délai réglementaire décompté à partir de la première publication. Dès lors, la seconde publication devra nécessairement faire référence au fait que l'avis a déjà été publié et aux délais restant à courir jusqu'au dépôt et à l'ouverture des offres. Les Autorités contractantes sont donc conviées à s'assurer d'une parfaite coordination tant avec les organes de presse qu'avec l'organe chargé de la gestion du portail s'agissant des délais devant courir et des mentions portées sur les avis.

L'arrêté pris par le Ministre de l'Economie et des Finances en application de l'article 79 du Code des marchés publics précise les conditions de prise d'effet des délais de publication pour les marchés des communes dont le budget annuel initial est inférieur à 300 millions de FCFA, à condition qu'ils soient imputables audit budget. Pour chaque avis publié, les délais légaux de publication courent à partir de la date d'affichage au siège de la sous-préfecture.

Pour la date de publication effective des avis généraux, des avis spécifiques de passation des marchés et des avis d'attribution provisoire et définitive, elle est attestée par les accusés de réception ou décharges de bordereaux de transmission des demandes d'affichage adressées aux structures que sont : la gouvernance, la préfecture, la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, etc.

VI.3.e. : La publication électronique des avis

L'article 56.4 du CMP dispose que « les avis généraux de passation des marchés et les avis d'appel public à la concurrence peuvent faire l'objet d'une publicité par voie électronique autre que celle visée au paragraphe précédent. Cette publicité est alors complémentaire de celle qui est assurée dans les conditions prévues au présent article ».

Cette publication électronique peut avoir comme support le site Internet de l'Autorité contractante ou de celui d'une revue connue et accessible. Mais cette publication électronique ne peut aucunement constituer la seule publication. Quand elle est effectuée, elle s'ajoute obligatoirement à d'autres publications déjà effectuées : journal de grande diffusion, portail des marchés publics, publication communautaire par la Commission et publication internationale le cas échéant.

En outre, cette publication électronique doit être accessible aux candidats. En effet, les fonctions technologiques à utiliser pour accéder au support de la publicité électronique et à l'avis lui-même doivent être simples. Si, de par ses spécificités, la technologie à utiliser pour télécharger l'avis électronique n'est accessible qu'à un nombre réduit de candidats, les principes de mise en concurrence, d'égalité de traitement des candidats et d'accès à la commande publique s'en trouveraient violés. C'est la lecture qu'il faudrait avoir de l'article 57 du Code des marchés publics, même si cette disposition ne concerne pas que les avis électroniques.

En guise de conclusion sur la question de publication des procédures d'appel d'offres, on ne rappellera jamais assez l'importance de cette formalité dont le respect sera vérifié tant à l'occasion du contrôle a priori, que celui effectué a posteriori.

L'exemple suivant illustre parfaitement ces propos⁸.

Par lettre en date du 04 octobre 2012, le maire de la Commune de Kaffrine a saisi le CRD d'une demande d'avis sur le refus du Pôle régional de Contrôle des Marchés publics de Kaolack d'immatriculer des marchés pour non respect de la formalité de publicité telle que prévu par le code des marchés publics.

Saisi par lettre BE n° 142/C.KAF en date du 29 septembre 2011 pour immatriculation des marchés concernés, sur suggestion du Payeur qui a constaté l'omission de cette formalité, le Pôle de Kaolack a refusé d'y procéder pour non respect des règles de publicité. Il y a lieu de préciser, toutefois, que, tenant compte des seuils de revue, lesdits marchés ne sont pas obligatoirement soumis au contrôle a priori. Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d'avis porte sur le contrôle exercé par la DCMP lors de l'immatriculation des marchés publics.

Le CRD adopta le raisonnement suivant :

« (...) Considérant que l'article 24 du code des Obligations de l'Administration (COA) édicte que « le non respect des formalités de publicité prescrites et la violation du principe d'égalité de traitement des candidats aux commandes publiques par les acheteurs publics entraîne la nullité de la procédure de passation ou du marché passé, à la requête de toute personne intéressée au déroulement normal de la procédure ».

Que le pôle de Kaolack ayant constaté le non respect des règles de publicité dans le cadre de la passation des marchés concernés, est fondé à refuser l'immatriculation de ces derniers sur la base du caractère préventif de son contrôle en ce sens que la conclusion de ces derniers est entachée de vices substantiels (...).

En conséquence, le CRD estime que *« le pôle de Kaolack ayant constaté le non respect des règles de publicité dans le cadre de la passation des marchés concernés, est fondé à refuser leur immatriculation sur la base de l'article 24 du COA ».*

VI.4 Présentation de quelques procédures de passation de marchés publics

VI.4.1 Les modalités de mise en œuvre de la manifestation d'intérêt

L'objectif de la manifestation d'intérêt est de constituer, pour l'Autorité contractante, une liste restreinte de soumissionnaires qualifiés pour concourir. Elle est utilisée en général en matière de marchés de prestations intellectuelles.

⁸Avis n° 13/12/ARMP/CRD du 17 octobre 2012 du CRD statuant en Commission Litiges sur la saisine de la commune de Kaffrine concernant le refus du pôle régional de contrôle des marchés publics de Kaolack d'immatriculer des marchés

VI.4.1.a. La mise en œuvre de la publication de l'avis à manifestation d'intérêt

Les avis à manifestation d'intérêt font systématiquement l'objet de publication dans les conditions établies à l'article 56 du Code des marchés publics :

Ces avis doivent paraître sur le portail officiel des marchés publics et au moins dans un journal quotidien de grande diffusion. A ces publications, peut s'ajouter une insertion électronique (site Internet de l'Autorité contractante par exemple).

Dans l'hypothèse où le projet en question aurait une portée internationale, l'avis à manifestation d'intérêt devra également être inséré dans une publication à large diffusion internationale (revue internationale, par exemple).

Lorsque le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils fixés à l'article 53, l'Autorité contractante peut ne pas effectuer de formalité de publicité et inviter directement cinq prestataires (5) à soumettre une proposition. Cette disposition est donc dérogatoire aux dispositions de l'article 56 CMP qui prescrivent des formalités de publicité adaptées en dessous desdits seuils.

VI.4.1.b. : Le contenu de l'Avis à manifestation d'intérêt

Tout Avis à manifestation d'intérêt doit comporter au moins :

- les nom et adresse de l'Autorité contractante ;
- principales activités de l'Autorité contractante ;
- les conditions de participation, notamment situation juridique, capacité technique, capacité économique et financière ;
- les critères de présélection ;
- la date limite de dépôt des offres ;
- l'adresse à laquelle les offres doivent être envoyées.

Même si l'article 83 du Code des marchés publics ne le précise pas, l'Autorité contractante doit nécessairement préciser dans l'Avis à manifestation d'intérêt, l'objet précis du projet concerné.

VI.4.1.c. : L'établissement d'une liste restreinte

Le délai minimal à accorder aux Consultants pour déposer leur manifestation d'intérêt est de 15 jours calendaires à compter de la publication.

Si le nombre de Consultants-candidats ayant répondu n'atteint pas le nombre de 3, à la date réception des manifestations d'intérêt ou après évaluation, la concurrence n'est pas garantie.

Par conséquent, un nouveau délai (de minimum 10 jours ouvrables) sera ouvert.

Pour établir la liste restreinte, la commission des marchés compétente se conformera obligatoirement aux critères définis dans l'Avis à manifestation d'intérêt. Ne doivent figurer dans cette liste que les Consultants qui justifient d'une aptitude à exécuter les prestations.

Cette aptitude doit s'apprécier notamment par :

- l'expérience du Consultant : missions similaires déjà exécutées, ou qui sont en train d'être exécutées (à condition qu'ils établissent qu'au moins 70% des prestations a été exécuté) ;
- la formation et les diplômes ;
- les publications effectuées par le Consultant et qui sont en rapport avec le projet faisant l'objet de l'Avis à manifestation d'intérêt ;
- tout autre critère non discriminatoire, qui établit la qualité technique du profil du Consultant.

Les Consultants qui figurent dans la liste restreinte seront par la suite mis en concurrence ; à cet effet, l'Autorité contractante remettra aux présélectionnés une Demande de Propositions.

Le CMP précise toutefois, en son article 80, que l'Autorité contractante adresse une demande de proposition au trois premiers candidats présélectionnés au moins. Cette disposition ne saurait cependant pas être interprétée comme étant de nature à limiter le nombre de candidats à retenir ; elle n'a d'autre objet que garantir un minimum de compétition pur l'attribution du marché. En tout état de cause, la Demande de Propositions à adresser aux Consultants présélectionnés doit comporter toutes les informations qui leur permettront de bien préparer leur soumission. Le dossier transmis devra comporter notamment :

- les termes de référence ;
- une lettre d'invitation qui reprend les critères de sélection et leur mode d'application détaillé ;
- une Demande de Proposition qui précise toutes les règles applicables à la Consultation, dont les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations faisant l'objet de la consultation.

L'article 83-2 du CMP prévoit la possibilité de procéder à un avis à manifestation d'intérêt pour constituer une base de données d'entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.

Là également, la présélection s'effectuera sur la base de la qualité technique des candidatures (expérience de marchés similaires, ou qui sont en train d'être exécutées -à condition qu'ils établissent qu'au moins 70% des prestations a été exécuté- ; s'il s'agit des PME ou des entreprises nouvellement créées, il faudra plutôt prendre en compte le profil du personnel clef proposé).

Ces entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services présélectionnés seront par la suite mis en concurrence par l'Autorité contractante.

VI.4.2 La limitation des participants pour les appels d'offres restreints

L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable a lui-même choisi et décidé de consulter. La procédure restreinte permet à l'Autorité contractante de limiter le nombre d'offres à examiner. Elle pourra ainsi se concentrer sur les offres émanant des opérateurs offrant les meilleures garanties de capacités à exécuter les prestations faisant l'objet du marché, ce qui facilitera, a priori, la comparaison des offres.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 74 du CMP, l'Autorité contractante est tenue de mettre en concurrence un nombre de candidats permettant d'assurer une concurrence réelle et qui ne peut être inférieur à trois.

La procédure de sélection obéit aux mêmes règles que la procédure de pré qualification en ce sens qu'elle relève également de la responsabilité de la Commission des marchés compétente.

S'agissant du nombre de candidats à retenir, il est bien précisé par le CMP qu'il ne saurait être inférieur à trois. De fait, il est recommandé de retenir au moins cinq candidats pour autant qu'ils répondent aux critères de sélection requis.

L'attention des Autorités contractantes est particulièrement attirée sur le choix des candidats retenus ; il doit permettre d'assurer une diversification de l'accès à la commande publique des entreprises et une réelle concurrence. Toutes les dispositions doivent être prises en conséquence pour s'assurer de la participation effective des entreprises retenues. La non participation, sans motif légitime, des entreprises retenues sera ainsi de nature à remettre en cause l'inscription de ladite entreprise dans la base de données que l'Autorité contractante aura pu constituer.

VI.4.3 Une nouveauté du Code : les marchés passés suite à une offre spontanée

Cette nouveauté a été introduite dans le Code des marchés publics par l'article 81. L'offre spontanée est une proposition de projet (fournitures, services ou travaux) émanant d'un opérateur économique. En effet, les entreprises peuvent adresser à l'Autorité contractante une offre spontanée, afin de lui présenter un projet répondant à un besoin qu'il n'aurait pas identifié.

Ce concept d'offre spontanée revêt une grande importance au regard de la possibilité qu'il offre en termes d'accès aux moyens techniques et conceptuels innovants du secteur privé.

Mais l'attention des Autorités contractantes est attirée également sur le fait que certaines règles sont également à observer en matière de traitement d'une offre spontanée. L'article 81 pose un préalable : *« le fait que l'offre spontanée porte sur un domaine qui relève de la compétence de l'Autorité contractante et qui présente un intérêt général manifeste ».*

Quel traitement de l'offre spontanée ?

Deux types de procédures sont prévus par la disposition précitée et ils sont explicités ci-après.

- La procédure de principe, pour faire suite à une offre spontanée : l'Appel d'Offres Ouvert

Ce principe signifie que les offres spontanées ne permettent pas à l'Autorité contractante de contracter directement avec les entreprises qui en sont à l'origine. Si la personne publique souhaite donner suite à un tel projet, elle doit organiser la mise en concurrence de tous les opérateurs économiques potentiellement intéressés par sa mise en œuvre, offrant toutes les garanties d'impartialité de sélection. Il lui faut donc organiser un appel d'offres ouvert dans les conditions prévues par le Code des marchés publics.

A cet effet, l'article 81 du Code indique que *« le dossier d'appel à la concurrence est élaboré sur la base des études préalables réalisées par l'auteur de l'offre spontanée qui précise, à la transmission desdites études, les données confidentielles ou de propriété intellectuelle qui ne peuvent faire l'objet de divulgation dans le dossier, à l'exception d'une cession de ses droits à l'Autorité contractante ».*

Il faudra éviter en conséquence, en procédant au lancement de l'appel d'offres, à divulguer des données qui n'auraient pas dû l'être car protégées par le secret des affaires. Mais si ce secret des affaires est tellement étendu qu'il rendrait impossible le lancement de l'appel d'offres, l'Autorité contractante qui a reçu l'offre est invitée à ne pas y donner suite ; l'acceptation d'une cession des droits de l'auteur de l'offre spontanée ne doit pas être automatique ; il faut éviter que les opérateurs privés utilisent ce concept pour instituer un commerce selon leur bon vouloir.

- De la possibilité de recourir à la procédure d'entente directe avec l'auteur de l'offre spontanée

C'est une exception posée par l'article 81 du Code. Qui indique que *« l'Autorité contractante peut recourir à la négociation directe, après avis préalable de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics, avec une entreprise présentant une offre spontanée ».*

Afin d'encadrer ce recours à l'entente directe suite à une offre spontanée, la disposition précitée pose les conditions cumulatives suivantes :

- montant estimatif du marché concerné doit être au moins égal à cinquante (50) milliards de francs CFA ;
- le financement intégral du marché doit être apporté par l'entreprise dans les conditions conformes aux règles d'endettement du Sénégal ;
- l'entreprise, dans le cas où elle serait de droit non communautaire, doit s'engager à sous-traiter aux nationaux une part du marché qui ne peut être inférieure à 10% du montant total ;
- l'entreprise doit définir, le cas échéant, un schéma pouvant assurer un transfert de compétences et de connaissances.

Les Autorités contractantes doivent donc intégrer le fait qu'avec ce concept d'offre spontanée, les pouvoirs publics cherchent à stimuler l'initiative privée et l'accès des PME à une part des marchés publics, mais dans un cadre préservant la rigueur dans la gestion dépenses publiques.

Cette procédure n'échappe pas au contrôle de la DCMP puisque son avis préalable est requis.

Pour lui permettre de se déterminer en toute connaissance de cause, l'article 81 indique que l'Autorité contractante doit présenter à celle-ci un dossier constitué notamment des pièces suivantes :

- l'offre technique détaillée résultant d'études concluantes ;
- l'offre financière avec une structure des prix détaillée ;
- le schéma de financement avec les modalités de remboursement du prêt par l'Etat comme le taux d'intérêt, le différé, la durée de l'amortissement du prêt, etc.

Le contrôle de la DCMP est très attendu et ne laisse de côté aucun élément déterminant. C'est pourquoi outre les éléments que lui transmet l'Autorité contractante ayant reçu la proposition, l'avis de l'organe de contrôle est également émis sur la base d'un rapport d'expertise portant notamment sur les aspects techniques, financiers et environnementaux et c'est l'organe chargé de la Régulation des Marchés publics qui met à la disposition de la DCMP une liste d'experts indépendants.

En cas d'avis favorable de la DCMP, l'article 81 du Code formule l'indication suivante :

L'Autorité contractante peut signer un protocole d'accord avec l'entreprise, auteur de l'offre spontanée, afin de fixer les engagements des parties pour assurer une bonne négociation du marché, les délais de mobilisation du financement ainsi que l'échéancier de négociation du contrat. Les études et documents constitutifs du marché transmis au moment de la soumission de l'offre spontanée deviennent la propriété exclusive de l'Autorité contractante qui se réserve le droit de les utiliser dans le cadre d'un appel à la concurrence, en cas de non conclusion du marché pour non respect, par le titulaire de l'offre spontanée, de ses engagements.

Et en cas d'avis négatif de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics, cette même disposition précise que l'Autorité contractante peut saisir le Comité de Règlement des Différends de l'organe chargé de la Régulation des Marchés publics.

Si l'auteur du projet ne mobilise pas le financement dans les délais définis par l'Autorité contractante, celle-ci peut soit annuler la procédure, soit organiser un appel d'offres ouvert.

Pour éviter ce blocage dû au financement, il est particulièrement recommandé aux Autorités contractantes de veiller à ce que l'offre soumise contienne à l'origine des éléments bancaires ou comptables concrets qui établissent la disponibilité des fonds nécessaires à la réalisation du projet.

Par rapport à la finalisation du processus contractuel consécutivement à une offre spontanée, les Autorités contractantes devront intégrer, dans leur démarche, l'alinéa 3 de l'article 85 du Code des marchés publics qui dispose que « *L'approbation achève la procédure de passation des marchés. Aucun contrôle a priori ne peut être effectué après l'approbation du marché* ».

Dès lors, le financement proposé par l'opérateur doit être mobilisé avant cette approbation. Si cette condition n'est pas respectée, l'autorité d'approbation réservera une suite défavorable à la demande.

Une telle règle se comprend plus aisément si l'on se réfère à celle applicable dans le cadre des procédures de marchés initiées par l'autorité contractante et à propos desquels, l'alinéa 4 de l'article 85 du Code des marchés publics dispose que « *le refus d'approbation du marché par ces autorités ne peut intervenir qu'en l'absence du document attestant de l'existence des crédits suffisants* ».

VI.4.4 Réduction des délais d'appel d'offres

La réduction des délais d'appel d'offres est prévue par le CMP, notamment en son article 63.

Son usage doit être strictement limité aux cas prévus par la réglementation et les Autorités contractantes sont invitées à ne pas abuser de cette procédure.

En application des dispositions de l'article 63 du CMP, ces délais peuvent être réduits de cinq (5) jours maximum lorsque l'Autorité contractante offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis, l'accès libre, direct et complet au dossier d'appel à la concurrence et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés, sous réserve que ce mode d'accès aux informations réponde aux conditions mentionnées à l'article 57.3.

Les délais peuvent être réduits à dix (10) jours au moins pour les appels d'offres nationaux et à quinze jours (15) au moins pour ceux internationaux, en cas d'urgence dûment justifiée résultant de circonstances imprévisibles non imputables à l'Autorité contractante.

La justification de ces délais est en tout état de cause soumise à l'appréciation de la DCMP lorsque son avis est requis par les dispositions réglementaires.

VI.4.5 Les problèmes liés à l'application de l'article 52 du Code des marchés publics

Il faut sur ce point interpréter ce que prévoit le Code des marchés publics avant de voir l'application qui est faite de cet article 52 par le Comité de Règlement des Différends notamment.

Aux termes de l'article 52 du CMP :

«La participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets de l'Etat, des établissements publics, des collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à participation publique majoritaire, est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l'UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité».

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent dans les cas suivants :

1. Lorsque les marchés concernés ne peuvent être exécutés par les entreprises ci-dessus visées ;
2. Lorsque, du fait de l'envergure financière du marché et/ou de la complexité technique des travaux, fournitures ou services, la faible concurrence locale ne garantit pas une compétition transparente ou une exécution économique et diligente du marché.

L'accès aux marchés concernés est alors autorisé aux entreprises communautaires, aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires, aux entreprises non communautaires. Dans ce cas, une préférence est obligatoirement accordée aux entreprises communautaires et aux groupements conjoints susvisés, proportionnellement à la participation des entreprises communautaires, conformément aux dispositions de l'article 50 du présent Code. Un arrêté du Ministre chargé des Finances définit les modalités d'application du régime préférentiel ».

Cette disposition pose un principe d'exclusivité, sous réserve de l'application de certaines conditions, pour les entreprises nationales et communautaires. Mais une possibilité de dérogation est admise par cette même disposition.

- Les conditions d'exclusivité pour les entreprises nationales et communautaires

Les critères sont cumulatifs et ils sont liés au type de marché, à l'origine des ressources et à la fiscalité.

- Le critère lié au type de marché

Les marchés concernés par cette exclusivité sont ceux que les Autorités contractantes passent par le biais d'un appel à la concurrence et les marchés de prestations et fournitures par entente directe. Au sens du présent article, les prestations incluent les marchés de travaux.

- Le critère lié à l'origine des ressources

Les marchés décrits ci-dessus ne sont réservés aux entreprises nationales et communautaires que si le financement est prévu par les budgets de l'Etat, des établissements publics, des collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à participation publique majoritaire.

En conséquence, si le marché est financé, en partie ou en totalité, par un partenaire au développement, cette exclusivité ne pourra s'appliquer.

- Le critère fiscal et commercial

Ces marchés sont réservés aux seules entreprises sénégalaises et communautaires régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier, ou au registre des métiers au Sénégal, ou dans l'un des Etats membres de l'UEMOA.

Les Autorités contractantes doivent donc prendre en compte la domiciliation fiscale des entreprises candidates. Celles-ci, à moins qu'elles ne bénéficient d'exemption, doivent être patentées dans l'un des 8 pays membres de l'UEMOA. En outre, sur le plan commercial, ces entreprises doivent obligatoirement avoir satisfait aux formalités d'enregistrement au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou de l'un des Etats membres de l'UEMOA. Ces exigences rejoignent l'article 13 du CMP qui cite ces éléments dans la liste des mentions obligatoires devant figurer dans tout marché.

• La possibilité pour une entreprise non communautaire d'accéder à ces marchés grâce à la condition de réciprocité

Cette condition de réciprocité est établie quand les entreprises sénégalaises, peuvent en vertu d'un accord entre le Sénégal et un Etat non communautaire, soumissionner aux marchés publics dans cet Etat.

• Les possibilités d'ouverture de ces marchés aux entreprises non communautaires (même en l'absence de réciprocité)

C'est l'alinéa 2 de l'article 52 du CMP qui prévoit ces dérogations. Dans certains cas, le marché peut être ouvert aux entreprises non communautaires. Deux cas sont prévus par la nouvelle rédaction de cette disposition.

Le premier cas est la situation où les prestations concernées ne peuvent être exécutées par aucune entreprise nationale ou communautaire, ni par une entreprise non communautaire éligible en application de la règle de la réciprocité.

Mais le principal problème est de savoir comment être certain que les prestations envisagées ne peuvent être exécutées par les entreprises visées au premier alinéa de l'article 52 du CMP.

De fait, les Autorités contractantes devront prendre toutes les mesures nécessaires au moment de la définition de leur besoins pour évaluer le marché communautaire et local et ses différents acteurs publics et privés. Cette définition devra s'accompagner d'un sérieux travail de prospection. Elle rend d'autant plus nécessaire la constitution par les Autorités contractantes de bases de données mises à jour chaque année.

Le second cas de dérogation renvoie à la situation où l'envergure financière du marché et/ou la complexité technique des travaux, fournitures ou services, la faible concurrence locale ne garantit pas une compétition transparente ou une exécution économique et diligente du marché. Cette situation se rapproche en quelque sorte de la première exposée ci-dessus.

Toujours est-il que pour que ce second cas de dérogation trouve application, l'Autorité contractante doit nécessairement inclure dans le dossier à transmettre le cas échéant à la DCMP, les éléments établissant que ces conditions définies au second alinéa sont réunies.

Si l'une de ces situations dérogatoires est établie, l'accès aux marchés concernés est alors ouvert aux entreprises non communautaires, même si elles soumissionnent individuellement ou même en l'absence de condition de réciprocité avec le pays dans lequel elles sont immatriculées et domiciliées fiscalement.

Dans ce cas, l'article 52 précise qu'une préférence est obligatoirement accordée aux entreprises communautaires et aux groupements conjoints réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires proportionnellement à la participation des entreprises communautaires, conformément aux dispositions de l'article 50 du Code.

VI.4.6 L'interprétation des dispositions portant sur les marchés par entente directe

Outre l'article 81 du Code qui porte sur les procédures applicables suite à une offre spontanée, et déjà explicitée dans le présent guide, les articles 76 et 77 sont les principales dispositions du Code qui règlent la procédure du marché par entente directe.

Ces dispositions s'articulent autour, d'une part, des prestations éligibles à la procédure de l'entente directe, et, des règles de procédures applicables par les Autorités contractantes d'autre part.

Les prestations éligibles à la procédure de l'entente directe

Après examen de l'article 76 du Code des marchés publics, l'éligibilité à la procédure de l'entente directe dépend soit de la nature même des prestations, soit des circonstances dans lesquelles les besoins qui font l'objet du marché sont nés. Les Autorités contractantes peuvent recourir à la procédure de l'entente directe dans les ci-après :

- *pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention d'un droit d'exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé*

Une mise en concurrence serait inutile dans cette situation. Le droit d'exclusivité à laquelle fait référence ici l'article 76.1.a du Code des marchés publics renvoie à l'application du droit de propriété intellectuelle ou à un droit consacré expressément par un texte.

Cette règle est également prévue en matière de délégation de service public, notamment avec l'article 82-5b. En effet, selon cette dernière disposition, le choix d'un délégataire d'un service public peut se faire selon la procédure d'entente directe « *lorsqu'une seule source est en mesure de fournir le service demandé* ».

Dans le dossier adressé à la DCMP dans le cadre de la demande d'autorisation, l'Autorité contractante doit impérativement prouver que les besoins ne peuvent pas être satisfaits autrement, sans autre moyen équivalent. Elle doit également établir la preuve de cette exclusivité.

Cependant, qu'il s'agisse d'un marché public ou d'une délégation de service public, il est très important de retenir que ni la complexité des prestations, ni le fait que le même opérateur ait déjà fourni et installé les équipements de base objet du marché, ne peuvent justifier le choix de la procédure de l'entente directe sous prétexte que les besoins exprimés ne peuvent être satisfaits que par un seul et même opérateur.

- *pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l'objet d'un premier marché exécuté par le même titulaire*

La passation d'un marché par la procédure de l'entente directe peut s'expliquer ici par des raisons qu'on peut relier globalement à la continuité du service.

Concrètement, et à titre d'exemple, un marché complémentaire de fournitures peut être attribué au fournisseur initial par la procédure de l'entente directe lorsque le changement de fournisseur obligerait l'Autorité contractante à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées.

Mais pour que ces prestations complémentaires puissent faire l'objet d'un marché par entente directe, certaines conditions cumulatives doivent être réunies en application de l'article 76.1-b du Code des marchés publics :

- le marché initial doit avoir été passé selon la procédure d'appel d'offres ;
- le marché complémentaire doit nécessairement porter sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties. Ce n'est pas à l'Autorité contractante ou au titulaire du marché initial de créer le besoin qui doit faire l'objet du marché complémentaire. Il doit être objectif et imprévu au moment de la définition des besoins du marché initial.
- les prestations objet du marché complémentaire ne peuvent être techniquement ou économiquement séparées du marché principal. Ce lien est à établir dans le dossier à remettre à la DCMP.
- le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris.

Ces éléments sont cumulatifs. Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, la procédure de l'entente directe ne sera pas autorisée par la DCMP.

- *pour les prestations considérées comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige*

Ces prestations font également l'objet d'un marché par entente directe, en application de l'article 76.2 b du CMP. La nature de ces prestations les rend incompatibles avec toute mesure de publicité. Les explications sur la nature de ces prestations sont données à la page 90 du présent guide.

- *pour les marchés pour lesquels, l'urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l'autorité, n'est pas compatible avec les délais et règles de forme exigés par la procédure d'appel ouvert ou restreint*

VI.4.6.a. L'urgence impérieuse

L'urgence impérieuse au sens de l'article 76-2-b du Code des marchés publics correspond à une urgence beaucoup plus sérieuse et impérative qu'il convient de ne pas confondre avec l'urgence simple.

L'urgence simple résulte de circonstances qui ne posent pas de difficultés irrésistibles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle avec cette « urgence », les délais de publicité des appels d'offres soient simplement écourtés ; les circonstances ne justifiant pas une procédure d'entente directe.

Le caractère « *impérieux* » au sens de l'article 76-2. a du Code des marchés publics doit s'entendre non seulement sur la nature de l'événement mais également son ampleur ; les événements doivent dépasser largement le cadre normal de la vie économique et sociale (catastrophes naturelles ou technologiques).

Mais une urgence impérieuse ne suffit pas à justifier la conclusion d'un marché par entente directe ; elle doit nécessairement être également irrésistible et extérieure à la volonté de l'Autorité contractante.

Le caractère « *irrésistible* » doit être apprécié par rapport à l'ampleur des événements et aux besoins immédiats engendrés qui font qu'il est objectivement impossible d'attendre un quelconque délai avant de commencer les prestations.

Enfin, les événements doivent être extérieurs à la volonté de l'Autorité contractante. Celle-ci ne doit aucunement être à l'origine, directement ou pas, des événements invoqués pour justifier la procédure de l'entente directe. Une situation engendrée par le laxisme de l'Administration ou son manque d'anticipation n'est pas constitutive d'une urgence au sens de l'article 76-2-b du Code des marchés publics.

- *pour les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde*

Ces concepts ont été introduits dans le dispositif des marchés publics au Sénégal, par le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 abrogé.

La « *mobilisation générale* » peut s'entendre comme étant la mise en œuvre de l'ensemble des mesures de défense déjà préparées par les Autorités nationales pour faire face à une menace interne et/ou externe.

Quant à « *la mise en garde* », elle consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces militaires.

Dans ces situations, les mesures de mises en concurrence deviennent inadaptées, d'où l'utilisation de la procédure de l'entente directe en raison de la réactivité imposée par les circonstances.

La procédure à appliquer par l'Autorité contractante

La procédure de l'entente directe étant dérogatoire au principe de la mise en concurrence par l'appel d'offres ouvert, les articles 76 et 77 du Code des marchés publics ont institué des règles de contrôle très strictes pour sa mise en œuvre.

- *l'intervention de la DCMP*

L'organe de contrôle a priori intervient de manière différente selon la nature des prestations objet de la procédure de l'entente directe.

- *les autorisations*

Les autorisations préalables sont à solliciter si l'entente directe est justifiée par la détention d'un droit d'exclusivité ou par la nature complémentaire des prestations. A ce niveau, l'article 76.1 est à relier à l'article 2 du décret n° 2007-547 du 25 avril 2007 portant création de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) qui attribue à cet organe, la compétence pour l'examen externe a priori des marchés.

Cette Direction se prononcera sur la base du dossier que lui transmet l'Autorité contractante. L'Autorisation ne sera pas accordée si les conditions de la procédure de l'entente directe ne sont pas cumulativement réunies.

- les avis :

Dans certaines situations énumérées par l'article 76-2 du Code des marchés publics, l'Autorité contractante n'a pas à solliciter une autorisation auprès de la DCMP, mais plutôt un avis, ce qui est beaucoup moins contraignant. Ces avis sont à solliciter pour les marchés par entente directe portant sur des prestations considérées comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige, et pour ceux relevant d'une urgence impérieuse. Enfin, cet avis est également à solliciter pour les marchés par entente directe justifiés par une urgence impérieuse ou par des mesures de mobilisation générale et de mise en garde.

Le délai imparti à la DCMP pour rendre son avis est de 24 heures à compter de la réception du dossier communiqué par l'Autorité contractante. Mais ce délai ne s'applique que pour les marchés par entente directe justifiés par des mesures de mobilisation générale et de mise en garde et pour ceux justifiés par une urgence impérieuse.

En cas de silence de la DCMP, l'avis de celle-ci est réputée favorable en application de l'article 142 du CMP. Mais dans ce cas, pour les procédures visés aux points b et c de l'article 76.2 du CMP, l'Autorité contractante ne peut conclure la procédure de l'entente directe sans s'en référer au Premier Ministre. En réalité, dans cette situation, c'est à cette autorité de décider si la procédure doit continuer ou pas.

L'Autorité contractante devra alors remettre au Premier ministre le même dossier communiqué à la DCMP et y inclure obligatoirement la preuve de la saisine de cette dernière.

Dans l'hypothèse où la DCMP, par une décision expresse, ne donne pas droit à la demande de l'Autorité contractante, l'avant dernier alinéa de l'article 76 du Code des marchés publics prévoit : « (...) l'Autorité contractante, qui en informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends près l'Organe chargé de la Régulation des Marchés publics d'une requête motivée, accompagnée de l'avis contesté dont copie est transmise au Premier Ministre ».

Le Premier Ministre est simplement informé dans ce cas. L'annulation de l'avis express négatif est à solliciter auprès du CRD de l'ARMP. Cette saisine doit être obligatoirement accompagnée de l'avis défavorable de la DCMP. La requête doit être motivée en fait et en droit ; l'Autorité contractante doit indiquer dans le mémoire qu'il produit, en quoi l'avis négatif de la DCMP est irrégulier et / ou non fondé.

VI.4.6.b. : Les notions de secret et d'intérêt supérieur de l'Etat

L'article 76 ne se prononce pas sur le délai imparti à la DCMP pour se prononcer sur la demande d'avis formulée dans le cadre d'un marché par entente directe portant sur des prestations considérées comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige.

VI.4.6.c. : Les marchés classés secrets :

Ces marchés sont visés à l'article 76 2-a du CMP.

Sont considérés comme secrets :

i) les marchés de fournitures, services et travaux passés pour assurer les besoins de la défense nationale et concernant :

- les marchés de fournitures et de services qui ont pour objet la conception, l'essai, l'expérimentation, la réalisation, l'acquisition, le maintien opérationnel, l'utilisation ou la destruction des armes, munitions et matériels de guerre ;

- les marchés de fournitures qui ont pour objet la réalisation de démonstrateurs ou de prototypes d'armes, munitions ou matériels de guerre ;
- les marchés de fournitures qui ont pour objet les composants, les outillages, les consommables et les moyens d'évaluation et d'essais, spécifiquement conçus pour la fabrication, l'emploi ou le maintien en condition opérationnelle des armes, munitions et matériels de guerre ou l'emploi des armes, munitions et matériels de guerre ou concourant à leur efficacité militaire ;
- les marchés de service qui présentent un lien direct avec la stratégie militaire ou l'emploi des armes et qui ont pour objet soit les études exploratoires et les études technico-opérationnelles relatives aux équipements futurs, les études biologiques, médicales, hydrographiques, soit les études prospectives ;
- les marchés de travaux directement liés à la réalisation, l'emploi, le maintien en condition opérationnelle et l'évaluation des armes, munitions et matériels de guerre ;

ii) les marchés portant sur des fournitures, services et travaux :

- destinés à des fins de défense civile. Ces marchés portent sur des prestations visant à assurer l'ordre public, la protection matérielle et morale des personnes et la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que l'appui au maintien ou au rétablissement de la liberté d'action des autorités militaires sur l'ensemble du territoire ;

Pour plus de précision, on peut ajouter que ce concept de « *défense civile* » désigne les opérations de lutte contre les menaces, et les agressions que ce soit les menaces informatiques, actes terroristes, les armes de destruction et de désorganisation massive. En d'autres termes, la défense civile a pour objet de protéger la population contre les agressions.

Il convient donc de la distinguer de certaines opérations relevant de la protection civile ou de secours à la population (acquisition, pour les sapeurs-pompiers, de moyens de lutte contre les incendies, par exemple).

- relatifs à la sécurité nationale passés en vue de prévenir une menace, notamment terroriste, et plus généralement de prestataires, qui du fait de leurs prestations, accèdent à des informations ou domaines sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité et la sûreté de l'Etat et à son potentiel scientifique et économique. Relèvent notamment de ces marchés, les travaux qui doivent être exécutés dans l'espace présidentiel particulièrement au Cabinet du Président de la République, au Palais de la République et ses annexes.
- les marchés passés en vertu d'un accord international relatif à la participation des troupes sénégalaises à des opérations de maintien de la paix ;

Les critères de cette qualification

Les critères dégagés par cette disposition pour qualifier un marché de secret sont :

- les besoins en armement pour l'armée nationale ;
- la défense du territoire nationale ;
- la sécurité et la sûreté de l'Etat ;
- l'espace d'exécution des prestations : les locaux présidentiels, plus spécifiquement le cabinet présidentiel, le Palais et ses annexes.

Les règles de passation des marchés classés « secrets »

Les marchés concernés par ces critères sont placés sous le régime de l'article 76 du CMP. La nature des prestations concernées étant incompatibles avec toute mesure de publicité, ces marchés seront passés au moyen de la procédure d'entente directe dans les conditions précisées dans la disposition visée ci-dessus et explicitées dans le présent guide.

Les Autorités contractantes feront une lecture combinée de l'article 76 du CMP et de l'arrêté du Ministre chargé des Forces Armées qui fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat durant toute la procédure de passation et d'exécution du marché.

Les obligations du titulaire du marché classé secret et de ses sous-traitants éventuels

Ces marchés portant sur des domaines hautement sensibles, l'Autorité contractante peut exiger une certification justifiée par les prestations envisagées. Mais une attention particulière devra être portée par toute Autorité contractante, sur *« l'engagement du soumissionnaire et des sous-traitants à préserver de manière appropriée la confidentialité de toutes les informations classifiées en leur possession ou dont ils viendraient à prendre connaissance avant, pendant et après l'exécution du marché »*. Cet engagement est écrit et constitue une pièce contractuelle. En cas de violation dudit engagement, le contrevenant, au-delà de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'Autorité contractante, est passible de sanctions disciplinaires et pénales.

Par ailleurs, cette sous-traitance doit également se faire dans le respect des conditions habituelles de volume (maximum 40% du volume initial du marché), d'acceptation et d'agrément préalable de l'Autorité contractante.

Si l'Autorité contractante rejette les sous-traitants proposés, elle en apporte toujours les motifs écrits, à l'attention du sous-traitant concerné et du titulaire du marché.

Outre la confidentialité, les soumissionnaires, titulaires et sous-traitants doivent nécessairement établir leur capacité à exécuter les prestations, sans aucune interruption sur l'approvisionnement ou la continuité des travaux, et, ceci, même si le volume du marché augmente en cours d'exécution.

Telle est la lecture qu'il convient d'avoir de l'article 77 du CMP.

VI.4.7 Les modalités de conclusion des marchés de clientèle

La première règle qu'il convient de comprendre et d'appliquer est que pour conclure un marché de clientèle, il faut nécessairement mettre en œuvre une procédure d'appel à concurrence ; c'est ce que prévoit l'article 26 du Code des marchés publics qui exclue, par la même occasion, qu'un marché de clientèle puisse être passé par la procédure de l'entente directe par exemple. L'Autorité contractante pourra faire recours soit à la procédure d'appel d'offres ouvert, soit à celle dite « restreinte » ; elle peut aussi recourir à la procédure de DRP prévue à l'article 78 du CMP.

Conformément aux dispositions de l'article 25 du CMP, lorsque l'Autorité contractante ne peut déterminer à l'avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, elle peut avoir recours à un marché de clientèle par lequel elle s'engage à confier au prestataire ou au fournisseur retenu des commandes portant sur une catégorie déterminée de prestations de services, fournitures ou travaux d'entretien ou de maintenance, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes.

Ce concept de « Services courants » désigne des besoins fréquents (le nettoyage des locaux, le gardiennage...) pour lesquels les Autorités contractantes n'imposent pas généralement des spécifications techniques propres au marché.

L'incertitude sur le volume et le rythme des prestations est la principale condition pour choisir cette catégorie de procédure de marché.

Ce marché peut être conclu avec un ou plusieurs prestataires, entrepreneurs ou fournisseurs.

Ici, le cocontractant est choisi puis « *gardé en réserve* » et ne sera sollicité que lorsque le besoin se manifestera. Cette procédure est parfaitement adaptée aux situations où l'évènement générateur du besoin n'est pas inéluctable (exemples : acquisition de vaccins dans le cas d'épidémie ou produits phytosanitaires dans le cas de péril acridien, fournitures d'imprimés pour les élections, interventions dans le cadre de la lutte contre les inondations, etc.).

Pour ces marchés de clientèle, la période de couverture budgétaire correspond à celle d'utilisation des crédits de paiement. Les commandes que l'Autorité contractante effectue ne doivent pas excéder ladite période.

Lors de la mise en concurrence, pour permettre aux soumissionnaires de présenter une offre de prix sérieusement étudiée, il est utile que l'Autorité contractante indique les quantités de la prestation utilisée au cours d'une période écoulée dont la durée devrait, si possible, être la même que celle pour laquelle on envisage de traiter.

Les marchés de clientèle sont conclus pour une durée égale à un an, renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser trois ans. Ces marchés et leurs avenants sont soumis au contrôle de la DCMP et, ceci, quels que soient leurs montants. Il est important de préciser que si le marché de clientèle dépasse une durée d'un an, les parties peuvent fixer une date à laquelle une révision des prix pourra être effectuée dans le respect des conditions prévues à cet effet par l'article 21 du Code des marchés publics. Cette révision ne doit cependant pas augmenter les prix unitaires de plus de 20 % ; si ce pourcentage est dépassé, chacune des parties peut demander la résiliation du marché.

Globalement, il faut retenir qu'avec le nouveau Code des marchés publics tel qu'issu du décret de 2014, le dernier paragraphe du point b de l'article 25 a été profondément modifié.

Désormais, les marchés de clientèle ou à commande sont conclus pour une durée égale à un an, renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser trois ans, sauf dans les cas exceptionnels dument justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à trois ans. En conséquence, seule une bonne connaissance de la durée raisonnable d'amortissement des investissements peut garantir une bonne appréciation de la durée qu'il convient de décider pour ces types de procédure d'acquisition. L'attention des Autorités contractantes est attirée sur le fait que cette appréciation de la durée d'amortissement des investissements doit leur être propre et non guidée principalement par les indications du titulaire du marché.

Une telle recommandation se justifie par la nécessité d'éviter toute manœuvre de la part de celui-ci, dans le seul but d'obtenir une reconduction du marché alors qu'elle ne se justifiait pas. Le principe d'économie dans les procédures de commandes publiques ne doit pas être négligé en matière de marchés de clientèle ou à commandes.

Enfin, il peut arriver que la question de la conclusion d'un avenant à un marché public de clientèle pose des interrogations de la part de l'Autorité contractante. L'ARMP s'est déjà prononcée sur cette question, plus précisément sur la nécessité de conclure un avenant ou non à un marché de clientèle dont le montant maximum est atteint tandis que les crédits couvrant les futures factures sont disponibles .

Le CROUS a sollicité l'avis du CRD sur l'interprétation de l'article 25 (modifié) du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics. Dans le souci de mener à bien l'exécution du marché de clientèle pour la gestion et l'exploitation du restaurant.

Le CROUS faisait à deux interprétations possibles :

- le montant du marché étant épuisé, la continuité des paiements est subordonnée à la production d'un avenant d'augmentation.
- la signature d'un avenant n'est pas indispensable pour la prise en charge des factures dès l'instant que des crédits suffisants y afférents sont disponibles.

Partant de la définition du marché de clientèle, le CRD apporta la réponse suivante : *« il ressort qu'il n'est pas fait obligation à l'Autorité contractante de fixer dans le contrat un montant maximum contrairement au marché à commande qui doit arrêter le minimum et le maximum en valeur ou en quantité ;*

Considérant qu'ainsi, la pratique qui consiste à porter dans un marché de clientèle un montant maximum, souvent déterminé à partir de l'historique des commandes de l'Autorité contractante sur une période ou tout simplement par rapport au plafond de sa ligne budgétaire, doit être perçue comme indicative et que seuls les prix unitaires sont contractuels ;

Que dès lors, si le seuil maximal, porté à titre indicatif sur le marché de clientèle, est atteint sans que la durée d'exécution ne soit épuisée et que les crédits pour couvrir la continuation de la satisfaction du besoin existent, il ne doit pas être requis la conclusion d'un avenant pour passer commande ».

Cela n'aurait pas été possible dans un marché à commande où, justement, l'obligation de s'en tenir au maximum défini impliquerait, sous certaines conditions, la conclusion d'un avenant si les acquisitions devaient aller au-delà de ce qui était prévu et défini dans le marché.

VI.4.8 Les marchés à commande

Sur le sens du concept de « services courants » pouvant faire l'objet d'un marché à commande, il convient de se reporter à la définition donnée ci-dessus au VI.4.7.

Tout comme le marché de clientèle, le marché à commande doit obligatoirement faire l'objet d'une mise en concurrence. La procédure de passation d'un marché à commande pourra ainsi être mise en œuvre au moyen d'un appel d'offres ouvert, restreint ou au moyen d'une DRP prévue à l'article 78 du CMP.

Selon les dispositions de l'article 25 du CMP, lorsque l'Autorité contractante ne peut déterminer à l'avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, elle peut avoir recours à un marché à commandes qui fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement, les quantités des prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l'Autorité contractante en fonction des besoins à satisfaire.

Le marché à commande ressemble à bien des égards au marché de clientèle mais s'en distingue par la possibilité de déterminer en quantité ou en valeur, le minimum et le maximum des biens et services susceptibles d'être acquis.

Pour ces marchés également, la période de couverture budgétaire correspond à celle d'utilisation des crédits de paiement. Les commandes que l'Autorité contractante effectue ne doivent pas excéder ladite période.

⁹Avis N° 005/13/ARMP/CRD du 02 octobre 2013 du CRD statuant en Commission Litiges sur la saisine du Centre des Œuvres Universitaires de Saint-Louis concernant l'exécution d'un marché de clientèle.

Pour ce type de marché, il faut raisonner en termes de «*minimum*» et de «*maximum*» ; l'Autorité contractante est contractuellement engagée sur le minimum défini. Le marché fixe ainsi une tranche devant encadrer le volume susceptible d'être commandé au cours d'une période déterminée. Mais à chaque fois que l'Autorité contractante adresse un bon de commande à son cocontractant, les quantités des prestations ou fournitures à exécuter doivent être bien précisées en fonction des besoins à satisfaire. A la fin du marché, le volume global des commandes ne doit pas être inférieur au minimum ni supérieur au maximum exprimés dans la description des besoins et les documents contractuels.

C'est le bordereau des prix unitaires (éventuellement modifié) contenu dans l'offre du titulaire qui sera utilisé. La rémunération du prestataire est calculée en multipliant le prix unitaire par les quantités livrées ou exécutées. Par ailleurs, le calcul du montant de ce type de marché pour l'évaluation des seuils est effectué sur la base du maximum.

Le renouvellement des marchés à commande obéit au même régime que celui des marchés de clientèle. Ce sont les articles 14.1 et 25-b du CMP qui règlementent la durée de cette catégorie de marché. Les marchés à commandes sont conclus pour une durée égale à un an, renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser trois ans.

A ce niveau également, la limitation à trois ans maximum s'explique par les nécessité d'une remise en concurrence périodique afin de faire bénéficier à l'Autorité contractante des éventuelles innovations technologiques et de baisses des prix.

Mais dans le cadre de la procédure de passation d'un marché à commande, quel qu'en soit le montant, les Autorités contractantes doivent obligatoirement transmettre le dossier à la DCMP. Ce contrôle préalable s'applique également sur les avenants à ces contrats, sans condition de seuils.

VI.4.9 : Les marchés à tranches conditionnelles

Tout comme les deux précédents types de contrat, le marché à tranches conditionnelles doit aussi nécessairement être passé au moyen d'une procédure de mise en concurrence, sans préjudice des obligations de contrôle préalable par la DCMP et, ce, quel que soit son montant.

Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche qui doivent constituer un ensemble cohérent. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Telle est la règle fixée par l'article 25.2 du Code des marchés publics.

Concrètement, avec cette option, l'Autorité contractante a la possibilité de conclure un marché et de surseoir l'exécution d'une ou de plusieurs tranches dudit marché en attendant la réalisation de certaines conditions économiques, techniques ou financières bien spécifiées dans le DAO et le contrat.

Ces documents doivent également définir clairement les modalités de déclenchement des tranches conditionnelles, les délais de mise en œuvre ainsi que les mécanismes de révision et d'actualisation des prix qui en découleraient. En principe, le déclenchement d'une tranche conditionnelle doit être matérialisé par avenant puisque les conditions de lancement d'une tranche conditionnelle sont liées généralement à la mise en place des financements complémentaires ou une modification des modalités de financement, autant d'actes qui ne peuvent être posés que par avenant.

Les différentes tranches du marché constituent un ensemble cohérent et indissociable. Le montant du marché à prendre en compte pour la détermination des modalités de revue et d'approbation est celui qui inclut la tranche ferme et les tranches conditionnelles. C'est également sur la base de ce montant global que le marché sera enregistré.

VI.4.10 : Les marchés afférents à des programmes d'investissement, d'entretien et de maintenance d'équipements complexes

Cette catégorie de marché est visée au point 2 de l'article 14 du Code, lequel dispose : *« Les marchés afférents à des programmes d'investissement, d'entretien et de maintenance d'équipements complexes, peuvent être contractés pour plusieurs années, à la condition que les engagements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des crédits de paiement contenus dans les lois de finances ou dans les budgets des autorités contractantes, visées à l'article 2 du présent décret, autres que l'Etat et ses services déconcentrés ».*

De par leur contenu tel que précisé dans cette disposition, ces marchés s'apparentent à des marchés dits « globaux » avec notamment un ensemble de prestations différentes les uns des autres.

Les précisions apportées par cet article obligent les Autorités contractantes à réaliser une évaluation préalable très sérieuse et rigoureuse de leurs besoins ainsi qu'à une étude de leur « soutenabilité » budgétaire sur toute la durée du contrat. Ces éléments seront évidemment examinés par la DCMP dans le cadre du contrôle préalable.

Comme les autres marchés visés à cet article 14, ceux afférents à des programmes d'investissement, d'entretien et de maintenance d'équipements complexes s'exécutent sur une durée s'étalant sur une période pouvant être supérieure à un an.

Ces marchés comportent plusieurs phases de prestations, et la lecture de cet article devra se faire en relation avec les articles 17 et 24 du COA qui disposent respectivement :

« La conclusion d'un contrat susceptible d'engager les finances de la personne administrative contractante est soumise à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles d'engagement des dépenses publiques. L'inexécution de cette obligation n'est pas opposable au cocontractant de l'administration ».

« La conclusion des contrats d'achat passés à titre onéreux par les acheteurs publics.....suppose l'existence de crédits suffisants..... ».

Les Autorités contractantes devront donc s'assurer que pour chaque phase, ou pour chaque année d'exécution, les crédits de paiement sont disponibles et suffisants et ce en conformité avec les autorisations de programme en question.

VI.4.11 : L'institution d'une nouvelle catégorie de procédure : les accords-cadres

Le concept d'accord-cadre a été introduit par l'Autorité dans le nouveau Code, à l'article 25.3, lequel dispose que *« l'Autorité contractante peut également passer des marchés dans le cadre d'un accord-cadre conclu avec des fournisseurs de biens, de travaux et de services (...) ».*

Il faut considérer ce concept comme étant un instrument de planification de la commande publique, car l'Autorité contractante s'engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l'accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.

La disposition précitée précise que *« l'accord-cadre fixe les termes et conditions de la passation de marchés individuels subséquents qui peuvent être attribués pendant la durée de l'accord qui ne doit pas dépasser 3 (trois) années ».* Le Code n'institue aucun cas de prorogation de cette durée ; sera déclaré comme nul tout marché subséquent passé sur la base d'un accord-cadre dont la durée ne respecterait pas celle indiquée à cet article.

Toujours aux termes de cette disposition innovante : « L'accord-cadre peut prendre les formes suivantes :

a) Accord-cadre fermé basé sur des critères prédéfinis, y compris pour l'attribution des marchés individuels subséquents fondés sur l'accord-cadre, signé avec un ou plusieurs fournisseurs et n'autorisant pas de nouveaux entrants pendant la durée de l'accord ;

b) accord-cadre fermé assorti d'une même restriction pour les nouveaux entrants mais mis en œuvre en deux étapes : la première afin de sélectionner plus d'un fournisseur, et la seconde pour la remise en concurrence des fournisseurs sélectionnés lors de la première étape et l'attribution du marché à celui ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante au regard du prix proposé et des conditions de livraison ;

c) accord-cadre ouvert organisé en deux étapes mais sans restrictions concernant la participation de nouveaux entrants ».

Quel que soit le type d'accord-cadre choisi, l'Autorité contractante doit toujours recourir, pour la présélection, à un appel public à la concurrence.

Tel que présenté dans ce texte, l'accord-cadre se révèle particulièrement adapté pour les achats répétitifs, mais dont les contours ne sont pas totalement délimités en amont, ou qui sont susceptibles d'évolutions technologiques. Par comparaison au marché à bons de commandes, il offre la possibilité de ne pas définir, à l'avance, l'ensemble des conditions d'exécution du contrat et de pouvoir mettre en concurrence les titulaires de l'accord-cadre afin de bénéficier, tout au long de l'accord cadre, de la meilleure qualité au meilleur prix.

VI.4.12 : Le cas des marchés de fournitures par crédit-bail

Le code des marchés publics n'aborde ce type de marché que dans l'article 4 consacré aux définitions. Le point 19 de cet article vise les « fournitures », notamment les biens mobiliers de toutes sortes y compris les biens acquis par crédit-bail.

Un contrat ayant pour objet la prise en crédit-bail de produits ou de matériels constitue un marché de fournitures.

L'article 2, de la loi n°2012- 02 du 03 janvier 2012 sur le crédit-bail au Sénégal désigne ce contrat comme « toute opération de location de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels à usage professionnel, spécialement acquis en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque cette opération, quelle que soit sa dénomination, prévoit à terme la faculté pour le locataire d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ».

Sur le plan organique, l'article 6 de cette loi précise les différentes parties prenantes à une opération de crédit bail, tel que défini ci-dessus :

- le crédit-preneur qui peut être lui-même le fournisseur du bien qu'il vend au crédit-bailleur puis le reprend dans le cadre d'un contrat de crédit-bail,
- le crédit-bailleur doit être :
 - une banque ou
 - un établissement financier de crédit bail ou de location avec option d'achat ou
 - tout autre établissement financier à caractère bancaire ou Système Financier décentralisé ayant obtenu l'autorisation requise.

Sur le plan financier, le règlement d'un marché public de fournitures en crédit-bail se fait au moyen d'un loyer selon une périodicité déterminée par le contrat. Dans ce cadre, les loyers seront payés à terme échu en vertu du principe du service fait.

Mais il est essentiel pour les Autorités contractantes de ne pas considérer toute opération de location d'un bien comme étant un contrat de crédit-bail. L'article de la 4 loi n° 2012- 02 du 03 janvier 2012 rappelle l'importance de distinguer le crédit-bail, des autres opération comme « la location simple », « la vente », « la location-vente », « la vente à crédit », « la vente à tempérament », etc.

Sur ce point, les Autorités contractantes sont invitées à se référer à l'article 5 de cette loi du 03 janvier 2012 pour déterminer si une opération donnée peut être qualifiée, ou non, de location vente. Trois conditions **non cumulatives** sont posées par cette disposition :

- à la fin de la période de location, la propriété du bien loué peut être transférée au crédit-preneur moyennant le paiement d'un montant fixé d'avance,
- la durée de la location couvre la majeure partie de la durée de vie économique du bien objet du contrat de crédit-bail ;
- le montant total des loyers actualisés couvre une grande partie du coût du bien objet du contrat de crédit-bail.

L'intérêt d'un tel concept pour les Autorités contractantes réside en l'allégement des conditions de financement de biens qu'elles acquièrent, notamment par un étalement du prix sur toute la durée du contrat.

VI.4.13 : Le cas des marchés de fournitures par location-vente

La location-vente est également très brièvement abordée par le Code des marchés publics au point 19 de son article 4.

Il s'agit d'une opération dans laquelle le prêteur (le titulaire du marché) offre à l'emprunteur (l'autorité contractante) la location d'un bien, assortie d'une promesse unilatérale de vente, qui peut se dénouer par le transfert de la propriété (à l'emprunteur).

Par comparaison avec le crédit-bail, avec un marché de location-vente, c'est le fournisseur qui fournit directement le bien à l'Autorité contractante.

Mais tout comme le crédit-bail, son intérêt réside dans le fait qu'il est adapté au contexte de contrainte budgétaire, notamment en ce qu'elle permet la satisfaction d'un besoin immédiat de de l'Autorité contractante avec une contrepartie financière étalée sous forme de loyers, jusqu'au terme du contrat.

VI.4.14 : Les marchés de gestion et d'entretien par niveau de services (GENIS)

Ce type de marché est abordé dans une seule disposition du Code, en l'occurrence le point 3 de l'article 14 qui dispose : *« Les marchés de gestion et d'entretien par niveau de services (GENIS) qui se fondent sur une obligation de résultats en lieu et place de l'obligation de moyens des marchés classiques, peuvent être contractés pour une durée allant jusqu'à trois (3) ans ».*

Ce type de marché est analysé le plus souvent du point de vue de sa finalité, qui est d'assurer un service de qualité aux usagers. Lié le plus souvent aux infrastructures routières, il recouvre un ensemble d'activités nécessaires pour assurer continuellement aux usagers le niveau de service visé. Dans ce cadre, l'opérateur en charge de ce marché de GENIS sera en charge de bon nombre d'activités ayant pour objet la gestion et le suivi systématique de l'infrastructure concernée.

Outre cet objet, pour aider à une bonne compréhension de ces marchés de type GENIS, auxquels fait référence le point 3 de cet article 14 du code, il convient de noter qu'il y a une différence essentielle entre ceux-ci et les marchés « classiques » de travaux. En effet, ces marchés de GENIS se fondent sur une obligation de « résultats », tandis que les marchés classiques de travaux reposent, eux, sur une obligation de « moyens ».

Cette obligation de résultats a des incidences sur la rémunération du titulaire d'un tel marché. En effet, avec les marchés de type GENIS, les entreprises ne sont plus rémunérées en fonction directe des «moyens» mis en œuvre, c'est-à-dire du volume d'activités qu'elles auront déployé en termes de travaux physiques, mais sur la base de leurs « résultats », correspondant à la mise à niveau initiale de l'infrastructure, conformément aux normes prescrites.

Cette rémunération tiendra compte également des prestations d'entretien nécessaires pour assurer les niveaux de qualité prescrits sur l'infrastructure objet du marché, ainsi qu'à certaines améliorations spécifiques à celle-ci, en fonction des cahiers des charges.

En tout état de cause, ces résultats devront être dûment constatés et devront rendre compte des «niveaux de service» effectivement atteints, conformément au marché. Si le niveau de service requis n'est pas atteint pour un mois donné, la rémunération de ce mois sera soumise à refaction, conformément aux prescriptions des cahiers des charges.

C'est pourquoi d'ailleurs la procédure d'appel d'offres mettra les entreprises en concurrence sur la base, certes du niveau de qualité des services proposés, mais aussi en tenant compte de la rémunération mensuelle, fixe et forfaitaire, qu'elles demandent sur un volume déterminé de l'objet du marché.

Pour en revenir à la disposition précitée, il convient de retenir que ces marchés sont conclus pour une durée d'une (1) année, renouvelable au maximum deux (2) fois.

VI.4.15 : La procédure de demande de renseignement de prix

La mise en œuvre de la procédure relative aux demandes de renseignements et de prix (DRP), telle que prescrite à l'article 78 du Code des marchés publics, suscite de la part des Autorités contractantes un certain nombre d'interrogations résultant des difficultés d'interprétation dudit texte.

Les questions soulevées portent essentiellement sur :

- le choix du type de procédure : ouverte ou restreinte ?
- le recours ou non aux Commissions des marchés statutaires pour le dépouillement des demandes de renseignements et de prix ;
- le contenu des lettres d'invitation et des cahiers des charges ;
- la forme des documents contractuels ;
- les délais de préparation des offres et d'exécution des prestations ;
- les obligations des Autorités contractantes en matière d'information vis-à-vis des soumissionnaires.
- la question de la présence (ou pas) des soumissionnaires à la séance d'ouverture des plis,
- la question de la coïncidence (ou pas) entre la date limite de dépôt des offres et celle d'ouverture des offres

Trois types de procédure de DERP sont prévues par la réglementation, notamment l'arrêté n°00107 du 07-01-2015, du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. On note en effet :

- la DERP simple dispensée de forme écrite et qui nécessite seulement la présentation d'une facture ou d'un mémoire ;
- la DERP à compétition restreinte ;
- la DERP à compétition ouverte.

La DERP simple

Le choix de cette procédure dépend des conditions de seuils suivants :

- travaux d'un montant estimatif inférieur à 5 millions de francs CFA toutes taxes comprises;
- prestations intellectuelles d'un montant estimatif inférieur à 5 millions de francs CFA toutes taxes comprises ;
- fournitures ou services d'un montant estimé inférieur à 3 millions de francs CFA toutes taxes comprises.

La faiblesse de ces montants explique le peu de formalisme requis pour cette procédure. On parle ainsi de «demande de cotations». Cette procédure de DRP ne nécessite pas l'intervention d'une Commission des marchés et la procédure est prise en charge par la PRMP de l'Autorité contractante.

L'allègement du formalisme pour ce type de procédure est noté au niveau de la liberté d'appréciation dont dispose l'Autorité contractante sur les modalités de consultation des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires. L'article 2 de l'arrêté précité pose tout de même une condition sur le nombre de candidats consultés : au minimum trois (3). En outre, il n'y a aucune obligation d'établissement d'un cahier des charges formel. L'Autorité contractante peut également se passer d'une saisine écrite ou de mesures de publicité.

Cet allègement du formalisme pour les DRP simple se note également sur les modalités de soumission pour les candidats consultés. Les propositions financières formulées par ceux-ci sont soumises sous forme de facture pro forma et transmises librement sous enveloppe, par télécopie ou par courrier électronique. Mais quel que soit le type de transmission choisi, il faudra veiller à ce que la date de réception par l'Autorité contractante soit établie. A cet effet, si les propositions sont transmises sous enveloppe, il faudrait que ce soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou au porteur, contre remise d'un récépissé daté et signé.

Si l'envoi se fait par télécopie, il est nécessaire de bien vérifier le rapport de transmission ; enfin, si l'envoi électronique est choisi, il ne sera pas inutile de procéder à un paramétrage qui permettrait de générer un accusé de réception du courriel par l'Autorité contractante.

Mais l'absence de formalisme n'a aucune incidence sur le principe selon lequel les marchés sont attribués au soumissionnaire ayant proposé l'offre évaluée la moins-disante. Un procès-verbal sera dressé par l'Autorité contractante et signé par la personne habilitée, laquelle peut-être la PRMP ou toute autre agent ayant reçu une délégation à cet effet.

Enfin, les commandes découlant de la DRP simple feront l'objet de règlement sur simple mémoire ou facture.

La DRP selon la procédure à compétition restreinte pour les travaux, fournitures et services dont la valeur TTC se présente comme suit :

1. Pour ce qui concerne les marchés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics :
 - a) montant inférieur à 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
 - b) montant inférieur à 15.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
 - c) montant inférieur à 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
2. Pour ce qui concerne les marchés des sociétés nationales, des sociétés anonymes à participation publique majoritaire et des agences ou autres organismes ayant la personnalité morale, mentionnés à l'article 2.1 d) :
 - a) montant inférieur à 50.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
 - b) montant inférieur à 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
 - c) montant inférieur à 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Tout comme la précédente forme de DRP examinée, celle à compétition restreinte est allégée du point de vue des formalités de publicité, notamment avec un choix libre reconnu à l'Autorité contractante.

L'Autorité contractante sollicitera simultanément, par écrit, des prix auprès d'au moins cinq (5) entreprises choisies, en priorité, parmi les prestataires ayant manifesté leur intérêt pour les acquisitions concernées qui sont définies en référence à des normes.

Contrairement à la DRP simple donc, celle à compétition restreinte nécessite une lettre d'invitation (qui peut être individuelle ou collective, avec la liste des entreprises sollicitées), l'établissement d'un cahier des charges, une lettre de soumission et un projet de contrat.

Comme pour la procédure ouverte, c'est la Commission des marchés qui doit procéder à l'ouverture des plis et à l'évaluation des offres, avant de proposer un attributaire provisoire à l'Autorité contractante.

Après attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant, l'Autorité contractante en informe les concurrents non retenus ; la publication de l'attribution devra se faire sur le site des marchés publics. A cet effet, l'Autorité contractante communique à la DCMP, qui assure la collecte et l'analyse des données ainsi que l'établissement des statistiques sur les marchés publics, la liste des personnes consultées, le nom de l'attributaire ainsi que la nature et le montant du marché.

Même si les montants des acquisitions sont plutôt faibles, il n'en demeure pas moins que dans le cadre des DRP simples ou à compétition restreinte, les choix des Autorités contractantes doivent tenir compte des capacités des candidats pour participer au marché pour exécuter la commande conformément aux besoins objet de la procédure.

La DRP à compétition ouverte pour les travaux, fournitures et services dont la valeur TTC se présente comme suit :

1. Pour ce qui concerne l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, les marchés lorsque le montant est inférieur à :
 - 70 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 25.000.000 Francs CFA pour les travaux ;
 - 50 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 15.000.000 Francs CFA pour les services et fournitures courantes ;
 - 50 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 25.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles.
2. Pour ce qui concerne les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale, mentionnés à l'article 2.1 d) du Code des marchés publics, les marchés dont le montant estimé est inférieur à :
 - 100 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 50.000.000 Francs CFA pour les de travaux ;
 - 60 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 30.000.000 Francs CFA pour les services et fournitures courantes ;
 - 60 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 30.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles.

S'agissant des formalités, l'article 5 de l'arrêté précité précise que l'Autorité contractante qui adopte cette procédure lance un avis public d'appel à la concurrence (dans un journal quotidien ou sur le portail dédié aux marchés publics) avec un délai minimal de dépôt des offres qui est de 15 jours calendaires, à compter de la date de publication.

Cette procédure est plus formelle et un dossier d'appel à la concurrence doit même être établi. La commission des marchés de l'Autorité contractante procède à l'évaluation en fonction des critères mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence. Elle propose à l'Autorité contractante, dans un délai maximum de sept (07) jours à compter de la séance d'ouverture des plis, l'attribution du marché au candidat qui a l'offre conforme évaluée la moins-disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence, suivant le modèle type validé par l'ARMP.

Cette même disposition précise également que dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, l'Autorité contractante avise immédiatement les autres candidats du rejet de leurs offres, leur restitue les garanties de soumission, le cas échéant, et publie un avis d'attribution provisoire. Cette publication doit se faire selon les mêmes formes que pour l'avis d'appel à la concurrence.

En tout état de cause, quel que soit le type de DRP mis en œuvre, l'usage de la liberté de choix doit toujours se faire dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Les Autorités contractantes ne doivent pas comprendre ces procédures comme étant un moyen de se soustraire opportunément aux contraintes procédurales du Code des marchés publics. Ces souplesses ont été introduites par la réglementation dans le but de répondre de manière optimale à l'impératif que doit respecter toute Autorité contractante : la meilleure utilisation des deniers publics.

Il est indiqué aux Autorités contractantes qu'elles doivent utiliser, pour ces procédures, les dossiers types validés par l'ARMP.

Les DRP à compétition ouvertes sont immatriculées auprès de la DCMP.

VI.4.16 : La suppression de la procédure de l'adjudication

Le mode de dévolution des marchés par adjudication qui se fonde sur le critère exclusif du prix, a été supprimé depuis le CMP de 2007. La procédure d'appel d'offres devient la règle dans la passation des marchés ; cette règle est clairement précisée à l'article 60.3 du CMP qui dispose que « *l'appel d'offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe* ». Les bases d'attribution des marchés font désormais appel à des critères relatifs à la qualité technique des offres, pourvu que ces critères soient clairement définis dans les Documents de l'Appel d'Offres.

VI.5 Les exigences vis-à-vis des candidats et fournisseurs

VI.5.1 : L'exigence de production des pièces administratives aux seules entreprises nationales en cas d'appel d'offre international

Pour examiner la recevabilité d'une candidature, la Commission des marchés vérifie, entre autres éléments, si l'entreprise concernée a satisfait à certaines formalités administratives. Par ces documents produits, l'Autorité contractante pourra vérifier si l'entreprise candidate est en règle notamment par rapport à ses obligations sociales, fiscales, financières, etc.

Mais le deuxième alinéa de l'article 46 du CMP apporte une souplesse à cette règle puisqu'il prévoit que pour les appels à la concurrence internationale, les candidats étrangers sont dispensés de fournir un numéro de compte de contribuable et NINEA ainsi qu'un numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, ou le numéro d'immatriculation au registre des métiers ; Mais si ces dispenses sont notées au stade de la soumission, l'article 46 du CMP exige néanmoins que préalablement au paiement définitif pour solde, ces entreprises étrangères fournissent les documents nécessaires établissant qu'ils ont satisfait à leurs obligations fiscales, sociales et vis-à-vis de l'IPRES.

Commettrait donc une irrégularité, l'Autorité contractante qui, dans le cadre d'un appel d'offres international, déclarerait irrecevable la candidature d'une entreprise étrangère pour des motifs liés à l'absence d'un compte de contribuable et NINEA ou au défaut de production d'une attestation de qualification et de classement.

Ces dérogations s'expliquent par une volonté d'éviter de rendre difficiles, voire insurmontables, pour cette catégorie d'appel d'offres, les conditions d'accès à la commande publique nationale, pour les entreprises étrangères. Toutefois, cette dispense n'empêche certes par l'Autorité contractante de réclamer au candidat ou soumissionnaire la justification de ce qu'il est régulièrement enregistré dans son pays d'origine.

Les attestations en question (pour les marchés de travaux) sont celles de qualification et de classement prévu par le décret relatif à la qualification et la classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et de travaux publics. En matière de marchés de bâtiments et de travaux publics, même dans le silence du dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs et artisans nationaux de bâtiments et travaux publics sont tenus de produire l'attestation de qualification et de classement prévue au décret n° 83-856 du 10 août 1983 et comme indiquée dans la section VI.5.2 du présent guide.

A propos du compte de contribuable et NINEA dont les entreprises étrangères sont dispensées en cas d'appel d'offres international, il faut savoir que selon la réglementation applicable, toute organisation exerçant au Sénégal doit figurer dans un répertoire des entreprises, des établissements et des associations lui fournissant une identification satisfaisante pour faciliter ses démarches administratives. Le numéro d'identification national des entreprises et des associations (NINEA) est le numéro unique par lequel une organisation est enregistrée dans ce répertoire.

Au demeurant, l'article 4 de l'arrêté n°00863 du 22-01-2015 pris par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, en application de l'article 79 du Code, et qui régleme les marchés passés par les communes ayant un budget annuel initial inférieur à 300 millions de FCFA (si le marché est imputé sur ce budget), apporte une dérogation sur ce dernier point. Cette disposition prévoit en effet que ces catégories d'Autorités contractantes peuvent ne pas exiger la production des attestations justifiant, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, que le candidat a satisfait à ses obligations à l'égard de la Caisse de Sécurité sociale, de l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), des services chargés des recouvrements fiscaux et de l'inspection du travail. Mais cette dérogation n'est applicable qu'à leurs marchés inférieurs à 25 millions de F CFA.

Mais sur un plan plus général, l'avant dernier alinéa de l'article 44 du Code apporte une certaine souplesse sur la production de certains documents administratifs. Il s'agit notamment des documents établissant que le candidat a satisfait, au moment de sa soumission, à ses obligations à l'égard de la Caisse de Sécurité sociale, de l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), des services chargés des recouvrements fiscaux et de l'Inspection du Travail. Lesdits documents sont produits à la signature du marché et les candidats doivent s'engager sur l'honneur, dans leurs offres, qu'ils sont en règles avec ces différentes administrations.

VI.5.2 : L'attestation de qualification et de classement des entreprises

Enfin, pour être admises à participer aux marchés des travaux, les entreprises candidates sont tenues de produire un certificat de qualification. Ce certificat est délivré selon des critères objectifs et transparents par l'organisme officiel responsable de la certification des entreprises.

Cette obligation est d'autant plus importante que l'article 43-g du CMP fait de sa non observation, un critère d'exclusion de la commande publique, notamment pour les entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics. Cette disposition est à combiner avec l'article 46 du Code.

Outre pour cette catégorie de candidats, cette attestation de qualification et de classement des entreprises est également requise pour les candidats aux marchés relatifs à la défense et à la sécurité de l'Etat quand l'Autorité contractante exige une qualification préalable. Dans cette dernière hypothèse, le système de qualification peut être soit celui de l'Autorité contractante, soit celui d'un organisme tiers. Si c'est celui d'un organisme tiers, la règle de la transparence des procédures exige que l'Autorité contractante communique ses nom et adresse aux candidats intéressés ou sollicités.

En tout état de cause, la PRMP ne peut aucunement exiger la production d'un tel certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.

VI.5.3 : Le délai de production des pièces justificatives

L'article 44 du CMP précise que le défaut de fournir la garantie de soumission (quand elle est applicable) à l'ouverture des plis entraîne le rejet de l'offre. Il est précisé toutefois que ce rejet est décidé au stade de l'évaluation préliminaire en considération du fait que la séance d'ouverture des plis n'est qu'une séance de constatation, notamment par le recensement des éléments contenus dans les plis.

En revanche, il est indiqué que les documents prévus aux alinéas a) à f) du même article, et éventuellement h) et i, non fournis ou incomplets, sont exigibles dans le délai imparti à l'Autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire.

Il faut alors prendre en considération l'article 70 du CMP qui précise que « *la Commission compétente doit faire sa proposition d'attribution dans un délai maximum de quinze (15 jours) à compter de la séance d'ouverture des plis (...). Exceptionnellement, ce délai peut faire l'objet de prorogation dans la limite maximale de dix (10) jours (...)* ». En application de l'article 44 susvisée, les pièces justificatives susvisées aux alinéas a) à f et éventuellement h et i) devront, le cas échéant, être fournies dans ce même délai spécifié à l'article 70 du Code des marchés publics.

En revanche, l'Autorité contractante peut être amenée à demander aux candidats et soumissionnaires tout document de nature à confirmer leur qualification, ou à justifier de l'accomplissement d'obligations qu'ils n'auraient pu produire pour des raisons indépendantes de leur volonté, et ce dans le délai qu'elle leur impartit elle-même et qui est différent de celui indiqué à l'article 70 susvisé.

Tout soumissionnaire qui ne fournirait pas les documents sollicités, dans les délais exigés par l'Autorité contractante, verra alors son offre écartée.

VI.5.4 : L'interdiction des soumissions concertées

Le principe de la concurrence est à la base de cette interdiction. Ainsi, lorsque deux ou plusieurs entreprises ayant des liens capitalistiques ou de gérances étroites pouvant induire des possibilités de soumission concertée, veulent concourir à la fois à un appel d'offres, il est nécessaire que lesdits liens entre ces sociétés soient portés à la connaissance de l'Autorité contractante lors du dépôt des offres. Cette information revêt, en effet, une grande importance pour que l'Autorité contractante puisse, par des démarches appropriées, apprécier l'indépendance réelle des offres remises et exercer un choix éclairé. Tout soumissionnaire se trouvant dans une situation de conflit d'intérêts en présentant plus d'une offre dans le cadre d'une procédure de marché doit être disqualifié. C'est dans ce même esprit qu'il faut comprendre l'article 47-8 du CMP qui pose l'interdiction aux candidats et soumissionnaires de présenter, pour le même marché ou le même lot, plusieurs offres, notamment en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements.

Sur ce point, le sens de ces règles est d'éviter des ententes ou un arrangement anticoncurrentiel qui aura comme conséquence une définition de prix ne correspondant pas aux réalités du marché.

VI.5.5 : La lettre de soumission

La lettre de soumission est la matérialisation de l'offre du candidat et de son acceptation des dispositions du marché. Elle doit établee en un seul original et obligatoirement être signée, sous peine d'irrégularité et de rejet de l'offre.

VI.5.5.a. : Les mentions de l'acte de soumission

En application de l'article 11 du CMP, la lettre de soumission doit notamment mentionner :

- l'engagement du candidat à respecter les cahiers des charges applicables et les dispositions du marché ;

- l'engagement du candidat de ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
- l'engagement à respecter les dispositions de la charte de transparence et d'éthique en matière de marché public ;
- le prix ;
- les rabais éventuels intégrés dans la lettre ;
- le délai de validité de l'offre ; et,
- l'identité et la qualité de la personne signataire de l'acte.

Des modèles de lettre de soumission sont intégrées dans les dossiers d'appel d'offres.

VI.5.5.b. : Les rabais

Dans la formulation de son offre et la détermination de son prix, le candidat peut accorder des rabais à l'Autorité contractante. Ces rabais peuvent être conditionnels et liés à l'obtention de plusieurs marchés ou lots ou, inconditionnels. Leur prise en compte est précisée dans les modèles de rapports d'évaluation des offres.

Dans la lettre de soumission, ces rabais doivent être mentionnés de façon distincte du prix total de l'offre. Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont ensuite précisés et notamment les postes du détail quantitatif et estimatif auquel ils s'appliquent.

Les rabais éventuels sont d'ailleurs lus à haute voix lors de l'ouverture des plis. La pratique du rabais est courante en matière de marchés à commandes. Dans l'hypothèse où des rabais ont été accordés à l'Autorité contractante dans la formulation de l'offre, ceux-ci sont maintenus même en cas de révision du prix du marché.

VI.5.6 Les garanties

VI.5.6.a. Les conditions d'agrément

Les candidats aux marchés publics doivent fournir des garanties émanant d'organismes financiers ayant reçu l'agrément du Ministre chargé des Finances. Le site de l'ARMP comporte dans son espace législation une fenêtre précisant la liste des organismes financiers bénéficiant de cet agrément. Cette liste mentionne d'ailleurs la durée de validité desdits agréments et ceux qui sont expirés. Les Autorités contractantes sont donc invitées à être particulièrement attentives à ces dispositions.

VI.5.6.b. Les différents types de garantie et leur montant

- La garantie de soumission

Pour la garantie de soumission, le montant exigé par l'alinéa 1 de l'article 114 du CMP, est fixé entre 1% et 3% de la valeur estimée du marché ; le montant doit toujours être indiqué dans l'AAPC et / ou dans les DAO ; elle doit servir à éviter la remise d'offres non sérieuses qui seraient retirées avant la fin du processus de sélection.

Cette garantie n'est tout de même pas applicable aux marchés de prestations intellectuelles. Dans l'hypothèse d'une candidature d'un groupement d'entreprises, la garantie doit désigner comme soumissionnaires tous les membres du groupement qui a soumis l'offre. En application de cette règle, si la garantie est fournie par un membre du groupement, elle ne doit pas être établie au nom exclusif d'une composante dudit groupement, mais doit obligatoirement mentionner toutes les entités du groupement d'entreprises liées solidairement par l'offre soumise, sous peine de voir sa validité entachée d'une irrégularité.

- Toutefois, dans le but de faciliter l'accès à la commande publique, en application de l'arrêté n°00860 du 22 janvier 2015 du Ministre de l'Economie et des Finances, l'Autorité contractante peut ne pas exiger la fourniture d'une garantie de soumission pour les marchés d'un montant estimé inférieur aux seuils suivants : 80 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures et de services autres que des prestations intellectuelles ;
- 100 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.

Ces seuils sont donc plus élevés que ceux prévus par l'ancienne réglementation.

Un autre assouplissement est prévu par le dernier alinéa de l'article 114 du CMP qui dispose que *«les groupements d'ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives d'artistes et les artisans individuels suivis par les chambres consulaires, les organismes d'études, d'encadrement ou de financement agréés sont dispensés de fournir une garantie de soumission quand la valeur de soumission ne dépasse pas 50.000.000 de francs CFA»*.

En dessous de ces différents seuils, et eu égard à la rédaction de l'article 1er de cet arrêté, cette dérogation est simplement une faculté et non une obligation ; c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'article 114 du CMP.

La garantie de soumission demeure valable pendant une durée de 28 jours à compter de l'expiration de la durée de validité des offres qui est de 90 jours.

- La garantie de restitution d'avance

Le CMP distingue les avances faites au titre des dépenses engagées et les avances de démarrage.

Les premières sont accordées en raison des dépenses engagées en vue de l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet d'un marché.

Les avances sont versées sur production des justifications de débours contrôlées par l'Autorité contractante et contre remise d'une garantie de restitution d'égale montant. Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé en contrepartie des dépenses engagées ne peut en aucun cas excéder 60 % du montant initial du marché. Les articles 93 et 94 du CMP détaillent les conditions et limites de versement de ces avances.

L'Autorité contractante peut également accorder une avance forfaitaire de démarrage. Cette avance de démarrage est versée après réception de la demande de paiement accompagnée de la garantie correspondante. Le montant de l'avance de démarrage ne peut excéder 20 % calculé soit sur le montant initial du marché, taxes comprises lorsque la durée d'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à un an, soit lorsque la durée d'exécution est supérieure à un an sur le montant des prestations à réaliser au cours d'une première tranche de douze mois.

La garantie de restitution d'avance a ainsi pour objectif de protéger l'Autorité contractante d'une utilisation de l'avance par le titulaire soit à d'autres fins, soit en cas de défaut d'exécution du marché. Le montant de cette garantie est toujours égal à celui des avances.

- La garantie de bonne exécution

Quant à la garantie de bonne exécution, elle est destinée à protéger l'Autorité contractante contre les risques d'exécution défectueuse du marché.

Son montant est limité à un maximum de 5% et elle doit être constituée dans sa totalité au moment où le titulaire signe le marché. Les Autorités contractantes devront indiquer le montant de la garantie dans les cahiers des charges, notamment dans le CCAP. Si en cours d'exécution, un avenant est signé, l'Autorité contractante adaptera ce montant de 5% à la nouvelle valeur (en hausse ou en baisse) du marché.

En application de l'article 1er de l'arrêté n° 866 du 22/01/15 du Ministère des Finances, les seuls marchés concernés par cette obligation de garantie de bonne exécution sont ceux d'un montant égal ou supérieur aux seuils ci-après :

- 70 millions de F CFA TTC pour les marchés de fourniture et de services autres que les prestations intellectuelles ;
- 100 millions de F CFA TTC pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles.

Sont donc dispensés de cette garantie de bonne exécution, les marchés qui sont en dessous de ces seuils, ainsi que ceux passés entre établissements ou organismes soumis au contrôle de l'Etat et visés par le contrôleur de l'établissement ou de l'organisme considéré.

Si cette garantie est applicable dans un marché donné, l'Autorité contractante ne doit surtout pas procéder à un quelconque paiement tant qu'elle n'est pas constituée par le titulaire du marché. C'est pourquoi, quand le titulaire d'un marché demande le paiement d'un acompte, sans que la garantie de bonne exécution soit constituée ou complétée, l'Autorité contractante devra opérer sur l'acompte, une retenue correspondant au taux de cette garantie. La conséquence d'une telle situation est que le titulaire perd jusqu'à la fin du marché, la possibilité de substituer à la retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution.

L'outil financier qui constitue la garantie de bonne exécution peut être un cautionnement que le titulaire peut remplacer par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire d'un même montant que la garantie remplacée.

Le cautionnement consiste dans l'engagement d'une personne physique ou morale dénommée la caution, d'exécuter l'obligation du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L'Autorité contractante, et le titulaire du marché doivent savoir que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Quant à la garantie à première demande, elle est souscrite par un donneur d'ordre, le titulaire du marché, au profit d'un bénéficiaire, en l'occurrence l'Autorité contractante. Elle doit être exécutée, sans discussion possible (c'est son avantage par rapport à la caution) par l'établissement bancaire qui en est le garant, dès lors que l'Autorité contractante décide de l'appeler.

Comme pour les garanties de soumission, les garanties de bonne exécution doivent être fournies par des organismes financiers agréés par le Ministre des Finances.

Les garanties à première demande et les cautions personnelles et solidaires doivent être établies selon un modèle fixé par le Ministre chargé des Finances. Les dossiers d'appel d'offres type comportent des modèles afférents à chaque type de garantie. L'attention des candidats est attirée sur la nécessité d'obtenir des établissements bancaires concernés des garanties conformes à ces modèles et aux exigences des dossiers d'appel d'offres.

La garantie de bonne exécution est remboursée ou la caution ou garantie à première demande est libérée dans l'une des deux hypothèses suivantes :

- l'absence de période de garantie, au moment du règlement pour solde définitif, ou
- si le marché prévoit un délai de garantie, à la réception provisoire des travaux, fournitures ou services.

Mais, en tout état de cause, la garantie ne peut être libérée qu'après l'achèvement des obligations d'exécution du marché et au plus tard trente jours après cette date (CCAG applicable aux marchés de Fournitures et prestations de services courants et CCAG applicable aux marchés de travaux).

- La retenue de garantie

La vocation même d'une retenue de garantie réside dans la préoccupation de couvrir les réserves formulées éventuellement à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles intervenant pendant le délai de garantie. Elle sera prélevée sur tous les montants à régler à l'entrepreneur et égale à un pourcentage indiqué dans le CCAP mais qui ne pourra être supérieur à cinq (5) pour cent du montant du marché. Mais si le titulaire le souhaite, il pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande d'un montant égal à la totalité des sommes à retenir. Si le titulaire veut remplacer la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire, il faudra nécessairement l'accord de l'Autorité contractante. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'article 118 du CMP.

Le montant de la retenue de garantie est libéré à l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue est libérée un mois au plus tard après la date de leur levée.

VI.5.7 Contenu de l'acte d'engagement

L'Acte d'engagement confirme l'engagement contractuel des parties, à savoir l'acceptation de l'offre en vue de l'exécution des prestations, moyennant le paiement d'un prix. Il décline l'ensemble des pièces contractuelles constitutives du marché et leur ordre de prévalence.

Le modèle d'Acte d'Engagement figurant dans les Dossiers types d'Appel d'Offres est destiné à servir de guide pour l'établissement du cadre d'Acte d'Engagement, qui devra être adapté à chaque opération, à joindre au DAO. Le cadre d'Acte d'Engagement et ses annexes, établis par la PRMP, figurant dans le DAO devra être complété et signé par le Candidat. Il comporte les éléments de son offre et son adhésion aux dispositions du marché et constitue la pièce principale de ce dernier. Les Autorités contractantes sont invitées à utiliser le modèle standard joint aux dossiers d'appel d'offres.

VI.6. La réception et le traitement des candidatures et offres

VI.6.1 La présentation et la sécurisation des offres

VI.6.1.a. La présentation des offres

Les dispositions de l'article 61 du CMP précisent que *« les offres sont présentées sous la forme d'une soumission, comme indiqué à l'article 11 du CMP, établie en un seul original par les candidats aux marchés, accompagnée du nombre de copies mentionnées dans les cahiers des charges. Elles doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités. Une même personne ne peut, sous peine de rejet, soumettre plus d'une offre »*.

En matière de travaux, fournitures et services, le candidat place l'original de son offre et toutes les copies, y compris les variantes éventuellement autorisées dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention «ORIGINAL», «VARIANTE» ou «COPIE», selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure cachetée. Les dossiers d'appel d'offres précisent les mentions devant figurer sur chaque enveloppe, mais on peut d'emblée préciser que l'enveloppe extérieure doit :

- a) être adressée à l'Autorité contractante conformément aux indications de l'AAPC et des DAO, notamment le DPAO ;
- b) comporter l'identification de l'appel d'offres indiqué dans les Instructions aux Candidats, et toute autre identification indiquées dans les **DPAO** ;
- c) comporter la mention « ne pas ouvrir avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture des plis ».

Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipulé, l'Autorité contractante ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

En revanche, en matière de prestations intellectuelles, la proposition technique doit être placée dans une enveloppe séparée et cachetée ; il en est de même pour la proposition financière. Les candidats joindront par ailleurs les pièces à caractère administratif requise par l'Autorité contractante.

Les Candidats doivent placer l'original et toutes les copies de la Proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention « **PROPOSITION TECHNIQUE** », qu'ils cachettent. De même, l'original et les copies de la Proposition financière sont placés dans une enveloppe cachetée portant clairement la mention « **PROPOSITION FINANCIERE** » suivie du nom de la mission, et de l'avertissement « **NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE** ». Les Candidats placent ensuite ces deux enveloppes dans une même enveloppe cachetée extérieure portant l'adresse de soumission, le numéro de référence, ainsi que la mention « **À OUVRIR UNIQUEMENT PAR LA COMMISSION DES MARCHES DE L'AUTORITE CONTRACTANTE** ».

VI.6.1.b. La sécurisation des offres

La procédure de passation des marchés est marquée, du moins jusqu'à l'ouverture des offres, par son caractère confidentiel. Le contenu secret des offres doit être protégé tant vis-à-vis de l'Autorité contractante que des différents candidats. Et c'est à l'Autorité contractante qu'il revient la responsabilité de sécuriser ces documents.

Cette sécurisation est organisée à la fois par un dispositif assurant l'enregistrement des offres destiné à garantir notamment le respect des délais de la procédure, mais également par les conditions dans lesquelles les offres sont gardées jusqu'à leur ouverture.

Ainsi, dès leur réception, les offres sont numérotées (indication sur chacune des enveloppes du numéro d'ordre et de la date et de l'heure de réception) puis enregistrées sur un registre ; un récépissé du dépôt est remis au candidat ; après enregistrement, la conservation des plis cachetés est assurée par un fonctionnaire désigné par la PRM dans un coffre ou un local fermé. Un modèle de registre de dépôt des offres est inclus dans le manuel de procédure élaboré par l'ARMP.

VI.6.2 Les formalités liées à l'ouverture des plis pour les marchés de travaux, de fourniture, de service et de prestations intellectuelles

L'ouverture des plis pour ces types de marchés doit se faire dans le respect de certaines formalités.

VI.6.2.a. Commission des marchés et commission interne de dépouillement

Les Autorités contractantes doivent éviter de mettre en place des commissions internes de dépouillement en lieu et place d'une commission des marchés établie conformément à l'article 36 du CMP et à l'arrêté pris en application de ce même article, qui fixe le nombre et les conditions de désignation des membres de la Commission des marchés des Autorités contractantes (question déjà traitée dans le présent guide).

Une fois mis en place, cette commission doit impérativement se conformer aux exigences de l'arrêté susmentionné.

Pour cela, outre l'application de ses modalités d'organisation et de fonctionnement rappelées dans le présent guide, les Autorités contractantes doivent respecter la règle selon laquelle les copies des actes de nomination des membres des commissions et de leurs suppléants, visés à l'article 36, alinéa 4 du Code des marchés publics, doivent être communiquées à l'Autorité de Régulation des Marchés publics et à la Direction Centrale des Marchés publics au plus tard le 05 janvier de chaque année.

Ces membres nommées, et leurs suppléants, signent une déclaration dans laquelle ils indiquent avoir pris connaissance des dispositions du décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 portant approbation de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics. Les copies de ces déclarations doivent également être communiquées à l’Autorité de Régulation des marchés publics et à la Direction Centrale des Marchés publics.

VI.6.2.b. Le rejet des plis hors délais

La Commission des marchés doit impérativement éviter d’ouvrir les plis à une date et une heure différentes de celles qui sont indiquées dans le dossier d’appel d’offres ou de consultation.

Cette règle qui est une application du principe de transparence et du respect des procédures, s’accompagne aussi d’une certaine rigueur car la commission ne doit pas procéder à l’ouverture des plis reçus hors délais, c’est-à-dire au-delà des date et heure limites de dépôt des offres. Dans une telle hypothèse, ils sont retournés en l’état aux candidats concernés. La mention du rejet, après examen des plis et du registre spécial comportant la date de leur réception, apparaît sur le procès-verbal d’ouverture des plis.

VI.6.2.c. L’organisation de la séance d’ouverture

En application du principe de la transparence, la séance d’ouverture des plis est publique. La réglementation précise que tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l’Autorité contractante à assister ou à se faire représenter à l’ouverture des plis. Ce n’est pas le cas en revanche de l’ouverture des propositions techniques qui se déroule en l’absence des candidats en matière de prestation intellectuelles.

Les plis sont ouverts en présence des membres de la Commission des marchés. Par ailleurs, des personnes qualifiées peuvent être désignées par la DCMP en qualité d’observateurs pour contrôler les opérations d’ouverture.

L’article 39 du CMP précise que : « [...] Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents [...] ». En conséquence, si ce quorum fait défaut, ce même article précise que « [...] la commission des marchés est à nouveau convoquée et elle se réunit valablement en présence de deux de ses membres dont au moins un représentant de l’autorité contractante ».

Mais le quorum n’est exigé que pour les réunions des membres des commissions des marchés portant sur l’adoption des rapports d’évaluation et des procès-verbaux d’attribution provisoire. Concernant l’ouverture des plis, l’exigence est toute autre. En effet, pour ces séances, la présence du Président de la Commission, du secrétaire de séance, ainsi que des soumissionnaires, le cas échéant, suffit pour assurer la validité des délibérations. Telles sont les précisions apportées à l’article 7 de l’arrêté portant application de l’article 36 du Code des marchés publics.

Il faut aussi préciser que lorsque la séance d’ouverture des plis doit s’étaler sur plus d’une journée, l’Autorité contractante peut prononcer la suspension de la réunion qui sera reprise le lendemain. En conséquence, elle prendra sous sa responsabilité, toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les offres non encore ouvertes, notamment par l’intervention d’un officier ministériel (huissier), et inscrira à l’avance dans le dossier d’appel d’offres, toutes les modalités liées à la reprise de la séance d’ouverture des plis.

VI.6.2.d. L’établissement d’un procès verbal d’ouverture des plis

Le procès-verbal auquel fait référence l’article 67 du Code des marchés publics doit être un compte rendu fidèle de la séance d’ouverture des plis et doit être rigoureusement tenu car faisant partie des documents à envoyer à la DCMP. Toutes les informations relatives aux candidats et aux offres sont, dans un premier temps, communiquées à haute voix pendant la séance. Il en est ainsi du nom de chaque candidat, du montant de chaque offre, de la présence ou de l’absence de garantie financière, des rabais éventuels ainsi que de toute autre information que l’autorité contractante juge utile de faire connaître.

Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, ces informations sont consignées dans le procès-verbal signé par les membres de la Commission des marchés présents et remis à tous les candidats pour les besoins d'information, de transparence et d'un éventuel recours. Ledit PV est établi par un membre de la Commission de passation des marchés, désigné à cet effet par l'Autorité contractante.

VI.6.3 La possibilité de procéder au rejet de l'offre pour cause d'absence de garantie de soumission au moment de l'ouverture des plis

Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires et candidats des marchés passés par appel d'offres sont tenus de fournir une garantie de soumission sauf en matière de prestations intellectuelles. La présence ou l'absence de la garantie financière est constatée dès l'ouverture des offres et indiquée dans le procès-verbal d'ouverture.

Toutefois, les dispositions de l'article 68 du CMP précisent qu'« avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la Commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l'article 44, et rejette les offres non recevables ».

La garantie de soumission est une des pièces mentionnées par l'article 44 du CMP. En conséquence, le rejet de la garantie de soumission peut intervenir dès l'ouverture des offres, entraînant ainsi, au stade de l'évaluation, le rejet de l'offre.

Mais la commission peut ne pas procéder à un tel rejet si elle intervient dans le cadre d'un marché concerné par l'arrêté n°00860 du 22 janvier 2015 du Ministre de l'Economie et des Finances. En effet, la garantie de soumission peut ne pas être requise pour les marchés d'un montant estimé inférieur aux seuils suivants : 80 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures et de services autres que des prestations intellectuelle, 100 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux. En conséquence, dans ce cadre, si l'Autorité contractante décide de ne pas exiger cette garantie de soumission, son absence ne peut pas être sanctionnée. Par contre, même si le montant du marché est inférieur à ces seuils, et que l'Autorité contractante décide quand même d'exiger cette garantie de soumission, les soumissionnaires devront s'y conformer sous peine de rejet de leur offre, au stade de l'évaluation.

En tout état de cause, le rejet dont il est question ici nécessite un examen rigoureux de cette pièce de la part de la Commission des marchés compétente.

A l'ouverture des plis, et après examen de la garantie de soumission, son rejet peut être décidé si, par exemple :

- elle n'est pas établie dans les formes indiquées par l'Autorité contractante dans les DAO (défaut de signature, établissement par une institution financière ou bancaire non agréée, défaut d'identification de l'organisme émetteur ou du soumissionnaire) ;
- elle ne respecte pas le montant indiqué dans les DAO.

VI.6.4 Règles applicables en matière de participation des entreprises publiques

Les modalités d'intervention de l'entreprise publique candidate ne doivent pas fausser les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence entre cette entité publique et d'autres entreprises privées. Cette exigence vise à faire respecter le principe d'égalité d'accès à la commande publique. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il faut comprendre l'article 43-h du Code des marchés publics qui n'admet pas la participation des entreprises ou agences publiques, aux procédures de marchés, lorsqu'elles sont soumises à la tutelle technique de l'Autorité contractante. Cette participation n'est admise que pour les entreprises ou agences publiques qui peuvent établir :

- i. qu'elles jouissent de l'autonomie juridique et financière ;
- ii. qu'elles sont gérées selon les règles du droit commercial ; et,

iii. qu'elles ne sont pas des agences qui dépendent de l'Autorité contractante.

En tout état de cause, dans l'hypothèse où cette participation serait possible, la personne publique qui soumissionne devra être en mesure de justifier, le cas échéant, que le prix proposé a été déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat. En outre, et surtout, elle doit établir qu'elle n'a pas bénéficié, pour déterminer le prix proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués en sa qualité de personne publique, ou à raison des missions qu'elle accomplit.

VI.6.5 Application de la combinaison économiquement la plus avantageuse en matière d'allotissement
Les travaux, fournitures ou services peuvent être repartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct, lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises.

En cette matière, la directive UEMOA n° 04/2005 précise en son article 47 que « le dossier d'appel d'offres fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution et indique que la Commission d'évaluation des offres attribuera les marchés sur la base de la combinaison des lots évaluée la moins disante par l'Autorité contractante ».

La notion de combinaison économiquement la plus avantageuse en matière d'allotissement n'a donc pas pour objet de remettre en cause le principe de « moins-disance » dans l'évaluation faite, mais de souligner la liberté pour l'Autorité contractante de choisir au stade de la définition du marché la division en lots lui apparaissant la plus pertinente et au stade de l'évaluation les combinaisons d'offres lui apparaissant les plus avantageuses, tout en respectant pour chaque lot le principe de « moins-disance » en faisant application des critères prévus à l'article 59 du Code des marchés publics.

VI.6.6 L'examen de la variante

VI.6.6.a. Modalités de présentation

Elles sont prévues à l'article 62 du Code des marchés publics. Même si l'Autorité contractante doit définir ses besoins avec précision, il n'est pas exclu de laisser une part d'initiative aux candidats.

A ce propos, l'Autorité contractante doit clairement indiquer dans le DAO, si les soumissionnaires sont autorisés à présenter des variantes. Sauf indication contraire dans les DAO, les variantes ne seront pas prises en compte.

Au cas où les variantes sont sollicitées, le cahier de charges doit indiquer les exigences minimales qui leur sont associées ainsi que les modalités de leur présentation. La variante est présentée en plus de l'offre de base. Les modalités d'évaluation des variantes et des offres de base doivent être spécifiées dans le DAO.

Quand les candidats sont autorisés dans les DAO à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Cahier des Clauses techniques.

Les candidats souhaitant offrir des variantes techniques de moindre coût doivent d'abord chiffrer la solution de base telle que décrite dans le Dossier d'appel d'offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l'Autorité contractante a besoin pour procéder à l'évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix, méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.

VI.6.6.b. Modalités d'évaluation

La Directive UEMOA précitée précise en son article 59, alinéa 3, que « *seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l'offre de base évaluée la moins disante sera prise en considération* ».

Cette précision a été reprise à l'article 59 du CMP qui précise par ailleurs en son point 3 que les variantes ne peuvent être prises en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence et le dossier d'appel à la concurrence.

VI.6.6.c. Les options

Les options sont des prestations complémentaires qui doivent être limitées de manière à ne pas fausser le jeu de la concurrence.

La distinction entre la variante et l'option ne porte pas sur le fond ; elle repose sur la personne qui en est à l'origine. L'option résulte d'une demande de l'Autorité contractante alors que la variante est une solution proposée par le candidat.

VI.6.7 Les offres anormalement basses

L'article 59.4 du CMP précise que la Commission des marchés compétente peut rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix.

Le candidat peut justifier son prix notamment du fait :

- a) de l'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;
- b) des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux ou pour fournir les produits ou les services ;
- c) de la nécessité d'utiliser des ressources qui sinon resteraient inactives.

Les informations demandées peuvent ainsi concerner :

- les modes de fabrication pour les produits ;
- les modalités de prestation pour les services ;
- les procédés mis en œuvre pour la construction ;
- pour les offres basses, le caractère exceptionnellement favorable de certaines conditions pour le candidat (propriété intellectuelle, proximité, subventions, disponibilité de matériel à coût marginal ou organisationnelle, capacité commerciale pour réduire certains coûts, intérêt particulier du projet au regard de considérations commerciales, etc.).

Il sera utilement demandé au candidat un tableau de décomposition des prix pour tout ou partie jugé significative.

Le manuel de procédure de passation des marchés élaboré par l'ARMP précise les modalités de détermination des offres anormalement basses et le calendrier de réception des explications du candidat et de réponse par l'Autorité contractante.

Toujours est-il que d'ores et déjà, il est précisé à l'Autorité contractante que l'échange avec le soumissionnaire considéré, tel qu'institué par l'article 59.4 du CMP est obligatoire, même si, de par sa connaissance du secteur économique sur lequel porte la procédure, ou de la performance des outils d'analyse dont elle dispose, ladite autorité a des certitudes réelles sur le caractère anormalement bas de l'offre.

Cette règle a été rappelée dans la décision du CRD, synthétisée ci-après¹⁰.

Par lettre du 12 septembre 2013 reçue le 16 septembre 2013 au secrétariat du CRD sous le n° 456/13, le Directeur du Matériel et du Transit administratif a saisi le CRD d'une demande d'avis sur la possibilité d'utiliser les informations fournies par les services du Ministère du Commerce comme base de jugement des offres anormalement basses.

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d'avis a pour objet d'inviter le CRD à se prononcer sur la possibilité de saisir les services du Ministère du Commerce pour avoir des informations sur les prix de biens mobiliers afin de pouvoir disposer d'une base de jugement d'une offre anormalement basse.

A cette problématique, le CRD eut la réponse suivante :

« (...) Considérant toutefois que si l'Autorité contractante dispose d'un outil de détection des offres suspectées d'être anormalement basses, pour autant, l'offre ne peut être rejetée qu'après que l'Autorité contractante aura demandé au candidat concerné d'apporter, sur le détail des prix, des justificatifs qui n'ont pas été convaincants ;

Qu'il en résulte que la Commission des marchés ne peut rejeter une offre qu'en l'absence de réponse du candidat ou lorsque les explications fournies ne permettent pas d'établir le caractère économiquement viable de l'offre suspectée d'être anormalement basse ;

Qu'en considération de ce qui précède, si l'usage de documents des services du Commerce peut être admis pour détecter des offres anormalement basses, par contre, le rejet des offres suspectées ne peut intervenir qu'après demande d'informations adressée par l'Autorité contractante ».

¹⁰Avis n°006/13/ARMP/CRD du 02 octobre 2013 du CRD statuant en Commission Litiges sur la demande de la direction du matériel et du transit administratif relative à la possibilité d'utiliser des informations fournies par les services du Ministère du Commerce comme base de jugement des offres anormalement basses

VII. SIGNATURE ET APPROBATION DES MARCHES PUBLICS

La signature et l'approbation des marchés sont des formalités impératives qui doivent être accomplies par des autorités distinctes selon le principe posé par la directive UEMOA n° 004 en son article 16.

VII.1 La signature des contrats

La signature des contrats de marché relève de la responsabilité de la PRMP, conformément aux dispositions réglementaires explicitées dans le corps du présent guide (paragraphe III.3). La signature des contrats nécessite une habilitation conformément aux dispositions de l'article 27 du CMP ; soit cette habilitation résulte de la réglementation elle-même (cf, article 28 du CMP), soit par exemple le Ministre pour la signature des marchés passés par les départements ministériels, soit elle est le fait d'une délégation de compétence par l'Autorité contractante. Cette délégation de compétence doit être conforme aux textes réglementaires applicables. En conséquence, et en dehors de ces cas, et à peine de nullité, les marchés conclus ou signés, en l'absence d'une telle délégation sont nuls et de nullité absolue. L'attention des Autorités contractantes est attirée sur le fait qu'au-delà de l'irrégularité de la procédure qu'elle cause, la signature du marché par une personne non habilitée à cet effet est une faute administrative grave passible de sanction à l'encontre de l'agent concerné. Enfin, Avec le nouveau texte (article 85 du Code), la transmission du marché à la PRMP pour signature doit se faire dans un délai minimum de 10 jours (contre 15 dans l'ancien texte) à compter de la publication de l'avis d'attribution définitive.

VII.2 L'approbation des contrats

L'acte d'approbation, matérialisé par la signature de l'Autorité compétente à ce titre, est la formalité administrative qui achève la procédure de passation de marché. Toutefois, conformément à l'article 68 de la directive UEMOA repris à l'article 85 du CMP, le pouvoir de cette autorité est limité en ce que le refus de visa ou d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits. Pour bien comprendre le sens de l'article 29 du CMP qui régit cette formalité administrative, il est nécessaire de l'appréhender sous trois angles :

- quelles sont les autorités d'approbation ?
- quels sont les délais d'approbation ?
- à quel moment l'approbation prend-elle effet ?

VII.2.1 Les autorités compétentes

VII.2.1.a. Pour les marchés de l'Etat

- Le *Ministre chargé des Finances* : pour un seuil supérieur ou égal à 300.000.000 F CFA ;
- Le *Ministre dépensier* : pour un seuil entre 100.000.000 et 300.000.000 F CFA ;
- Le *gouverneur de région* pour les régions hors la Région de Dakar (où le Ministre dépensier reste compétent) : pour un seuil inférieur à 100.000.000 F CFA.

VII.2.1.b. Pour les marchés des collectivités locales

Pour ces entités, l'article 29 du CMP est à combiner avec le Code des collectivités locales. En effet, le principe de la libre administration des collectivités locales implique que certains actes pris par les organes de celles-ci entrent en vigueur de plein droit dès leur transmission au représentant de l'Etat, sauf s'il en est décidé autrement par ledit représentant. En revanche, certains actes demeurent soumis à l'approbation préalable du représentant de l'Etat avant leur entrée en vigueur. Les marchés publics, en fonction d'un seuil déterminé font partie de cette dernière catégorie d'actes.

Le Représentant de l'Etat procède à l'approbation du marché dans les situations et cas suivants :

- a) pour les départements : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 100.000.000 FCFA ;
- b) pour les villes et les communes :
 - villes de la région de Dakar, communes chef lieux de région et commune d'un budget égal ou supérieur à 300.000.000 FCFA : tout marché égal ou supérieur à 50.000.000 FCFA ;
 - autres communes : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 15.000.000 FCFA.

VII.2.1.c. Pour les marchés des établissements publics, agences et autres organismes visés à l'article 2.1 c) et d) Pour l'approbation des marchés de ces entités, l'article 29 du CMP désigne les entités suivantes :

- **Le Ministre chargé des Finances** : pour un seuil supérieur ou égal à 300.000.000 F CFA ;
- **Le Président du Conseil d'Administration ou de l'organe délibérant** : pour un seuil supérieur ou égal à 100.000.000 de F CFA mais n'atteint pas 300.000.000 F CFA ;
- **le Directeur ou l'organe équivalent de l'établissement public** : pour un seuil inférieur à 100.000.000 F CFA

Le problème d'interprétation qui se pose à ce niveau est la compétence, en matière d'approbation, du directeur de l'établissement public (même si cette compétence est subordonnée au montant du marché qui doit être inférieur à 100 millions de F CFA). En effet, l'article 28-d du CMP précise que « *la personne responsable du marché des établissements publics, agences et autres organismes ayant la personnalité morale visée à l'article 2-1-d) est l'organe exécutif désigné conformément aux règles qui leur sont applicables* ». Or, le Directeur est bien l'organe exécutif d'un établissement public, donc chargé de signer les marchés de celui-ci.

Dans la mesure où l'approbation constitue un acte de contrôle, l'autorité administrative qui l'effectue doit obligatoirement être distincte de celle qui procède à la signature du marché. C'est ce que prévoit d'ailleurs l'article 16 de la directive UEMOA n°04/2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'UEMOA. Cette disposition précise que « *les marchés publics, selon la qualité de l'Autorité contractante, sont transmis à une autorité d'approbation, centrale ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l'autorité signataire (...)* ». Elle a d'ailleurs été reprise à l'article 29 alinéa 2 du Code des marchés publics qui dispose que « *dans tous les cas, les fonctions d'autorité signataire et d'autorité approbatrice ne peuvent être cumulées* ». En l'état de cette contradiction, et jusqu'à la modification des textes, il serait donc souhaitable que pour ces Autorités contractantes, les marchés supérieurs à 100 millions de francs CFA soient approuvés par l'organe délibérant lui-même et les marchés inférieurs par le président du Conseil d'administration, seul.

VII.2.1.d. Pour les marchés des Sociétés nationales (SN) et des Sociétés anonymes à participation publique majoritaire (SAPPM)

L'article 30 du CMP prévoit l'approbation des marchés de ces sociétés par leur représentant légal.

Pour instaurer un contrôle interne, il est cependant requis l'avis favorable du Conseil d'Administration, matérialisé par le procès-verbal des délibérations, avant même la signature du marché pour les marchés passés par une SN ou une SAPPM créée depuis moins de 12 mois, ou lorsque le représentant légal décide de retenir un candidat autre que celui proposé par la Commission des marchés.

VII.2.1.e. En cas d'avenants

Cependant, pour l'ensemble des marchés susvisés, des modifications peuvent apparaître en cours d'exécution nécessitant ainsi la conclusion d'un avenant entre l'Autorité contractante et le titulaire. Dans une telle hypothèse, afin de vérifier si ce changement financier a une incidence sur les formalités d'approbation, l'Autorité contractante doit opérer un cumul du montant initial et de celui de l'avenant. Le dernier alinéa de l'article 29 précise que lorsque l'avenant a pour effet de faire passer le montant du marché en dessous du seuil pour lequel l'autorité approbatrice a compétence, celle-ci reste compétente. L'attention des Autorités contractantes est attirée sur le fait qu'un avenant avec des incidences financières peut avoir des implications sur la désignation de l'autorité d'approbation. Plus concrètement, un marché dont l'approbation relève du Ministre dépensier peut, en fonction du montant d'un éventuel avenant, « basculer » sous la compétence du Ministre de l'Economie et des Finances pour cette ultime formalité de contrôle. La règle à retenir ici est que le montant de l'avenant doit toujours être additionné à celui du marché initial. Ainsi, le seuil à considérer est la somme de cette opération et toutes les conséquences légales doivent en être tirées par les Autorités contractantes.

L'exemple suivant illustre parfaitement cette règle (les faits sont tout de même régis par le Code de 2007) ¹¹.

A la suite de l'appel d'offres relatif aux travaux de construction d'un village artisanal à Mbour pour le compte du Ministère de l'Industrie et de l'Artisanat, l'entreprise SOPRESCOM a été déclaré attributaire pour un montant de 81 406 843 F CFA et le marché a été approuvé le 11 janvier 2005 par le Ministre du Patrimoine bâti, de l'Habitat et de la Construction. Après l'approbation d'un premier avenant sans incidence financière ayant pour objet la détermination de la source du financement du reliquat du projet pris en charge par la commune de Mbour, la Direction générale de la Construction des Bâtiments et Edifices publics (DGCBE) a saisi le 12 janvier 2009, la DCMP aux fins d'immatriculation d'un deuxième avenant d'un montant de F CFA 20 129 022 F CFA pour la prise en charge de cantines supplémentaires.

Par lettre n° 144/MEF/DCMP/ind du 14 janvier 2009, la DCMP déclare que l'approbation dudit avenant est du ressort du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances. La DGCBE saisit le Comité de Règlement des Différends pour avis.

La problématique juridique était la détermination de l'autorité compétente chargée d'approuver un avenant dont le montant global du marché (contrat initial et avenant) atteint le seuil fixé par l'article premier du décret n° 2007-1590 du 31 décembre 2007 modifiant le décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics.

La CRD adopta le raisonnement suivant :

« Considérant qu'en référence à l'article 23.1 du Code des marchés publics un avenant est une modification à un contrat dont l'approbation relève des représentants habilités de l'autorité contractante et du titulaire du marché ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 54 de Code des marchés publics, la détermination de la valeur d'un marché par l'application de seuils de passation doit prendre en compte l'ensemble des travaux se rapportant à une même opération, celle-ci comporte un ou plusieurs ouvrages ;

Considérant que l'article premier du décret n°2007-1590 du 31 décembre 2007 portant modification du Code des Marchés publics exige que les marchés des départements ministériels d'un montant compris entre 100 000 000 de francs CFA et 500 000 000 de francs CFA soient approuvés par le Ministre chargé des Finances ;

Qu'à cet égard, le montant du marché global incluant le contrat initial et les avenants ayant dépassé le seuil minimum prévu par le décret n° 2007-1590 du 31 décembre 2007 portant modification du Code des marchés publics, il revient au Ministre chargé des Finances d'en approuver son avenant ».

VII.2.2 Les délais d'approbation

A partir de la réception du dossier de marché, l'autorité d'approbation a 15 jours pour se prononcer. L'article 85 du CMP précise implicitement qu'au-delà de ce délai de quinze jours, l'approbation est réputée effectuée. Enfin, il faut aussi préciser que les pouvoirs de l'autorité saisie sont strictement encadrés, car celle-ci ne peut refuser l'approbation que si elle note une absence de documents attestant de l'existence de crédits suffisants pour le marché. La décision de refus devra être dûment motivée et est susceptible de recours devant le CRD. Ce recours peut être introduit aussi bien par l'Autorité contractante, que par le titulaire du marché.

VII.2.3 La prise d'effet de l'approbation

L'approbation du point de vue de l'Autorité contractante est réputée acquise à l'expiration du délai de 15 jours mentionné au paragraphe VII.2.2 ci-dessus. Si l'approbation est intervenue de manière expresse (différente du silence gardée par l'autorité compétente), elle prend effet à partir de sa notification à l'Autorité contractante. Toutefois, s'agissant de la prise d'effet du marché vis-à-vis de son titulaire, l'article 86, alinéa 3 du CMP précise que « Le marché ne produit effet à l'égard du titulaire qu'à compter de sa notification ».

¹¹AVIS N°..../09/ARMP/CRD DU 25 mars 2009 du Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges sur la demande d'avis de la Direction générale de la Construction des Bâtiments et Edifices publics portant sur la conduite à tenir suite à la décision de la DCMP de soumettre à l'approbation du Ministre de l'Economie et des Finances l'avenant du marché portant sur les travaux de construction d'un village artisanal à Mbour.

VIII. LES REGLES EN MATIERE D'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

VIII.1 Le prix du marché

VIII.1.1 Les incoterms

Le contenu des prix des fournitures sera essentiellement défini par rapport aux obligations mises à la charge du fournisseur conformément aux conditions de livraison mentionnées dans les documents du Marché.

Ces conditions pourront généralement être définies par référence aux «*Règles officielles de la Chambre de Commerce internationale pour l'interprétation des termes commerciaux*» (dénommées INCOTERMS). Il s'agit de règles de droit privé, régulièrement mises à jour, établies par la Chambre de Commerce internationale.

La majorité des termes de livraison définis par les INCOTERMS concerne les ventes internationales. Cependant, certains d'entre eux sont applicables aux ventes à l'intérieur d'un même pays et sont couramment appliqués dans les marchés nationaux.

Selon les règles actuellement en vigueur (INCOTERMS 2010), les INCOTERMS sont classés en quatre catégories selon leur première lettre, par ordre croissant d'obligations pour le Fournisseur.

Le manuel de procédure élaboré par l'ARMP assure une présentation schématique de l'ensemble de ces termes.

VIII.1.2 Le contrôle des prix du marché

Certains marchés (entente directe, prestations intellectuelles, marchés dont l'évaluation et la désignation de l'attributaire s'effectuent exclusivement sur la base de la qualité technique de la proposition) ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle spécifique des prix de revient durant l'exécution des prestations. Le marché précise alors les obligations de transmission d'informations financières et comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis en vue de permettre ce contrôle.

Si le titulaire ne fournit pas les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, la Personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision de la personne publique, indépendamment de la résiliation éventuelle aux torts du titulaire.

VIII.2 Le règlement du prix du marché

VIII.2.1 Le versement d'avances aux titulaires de marchés publics

L'octroi des avances vise à faciliter l'exécution des marchés et assurer l'égalité d'accès aux marchés entre les entreprises disposant d'une trésorerie suffisante pour démarrer l'exécution des prestations et celles qui n'en disposent pas.

VIII.2.1.a. Le montant des avances

Le régime d'octroi des avances vise à faciliter l'exécution des marchés. A la lecture des articles 94 à 97 du Code des marchés publics, il apparaît qu'il faut distinguer deux catégories d'avances : les avances en raison des dépenses engagées et celles dites de démarrage. Cette distinction, déjà prévue dans le précédent code, constitue un changement par rapport au texte de 2007 qui ne prévoyait que les avances de démarrage.

- les avances en raison des dépenses engagées :

Leur montant est plafonné à 60 % du montant initial du marché contre remise d'une garantie de restitution d'égal montant. Mais la seule production de cette garantie n'ouvre pas droit au paiement de cette avance. Le titulaire doit surtout produire également les justificatifs des sommes qu'il a engagées et qui sont en rapport avec l'exécution des prestations objet du marché.

Mais le plafond de 60% du montant initial du marché tel que précisé par l'article 94-4 du CMP doit être appliqué différemment selon les circonstances d'exécution des prestations.

1. Si le titulaire du marché justifie que les travaux, fournitures ou services à exécuter nécessitent soit la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages importants, le montant des avances ne peut excéder la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché, ni 40% du montant initial du marché.
2. Dans le cas d'un marché de travaux nécessitant l'emploi sur le chantier d'engins lourds de travaux publics, dans les conditions expressément déterminées par le marché, le montant des avances ne peut excéder ni 60 % de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier, ni 30 % du montant initial du marché. Les avances ne peuvent être versées que lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ou, s'il s'agit de matériels dont le titulaire du marché ne disposait pas dans l'Etat du Sénégal au jour de l'approbation du marché, dès que les matériels peuvent être présentés au service chargé du contrôle de l'exécution du marché.
3. Si le titulaire du marché justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnement en matériaux, matières premières, ou autres biens destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, le montant des avances ne peut excéder 50% du montant du contrat d'achat ou de la commande considérée. En outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord de l'ordonnateur du budget concerné, excéder la valeur des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance.
4. Si le titulaire du marché justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables, d'une nature différente de celles visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus telles qu'achats de brevets, frais d'études, frais de transport, nécessités par l'exécution du marché, le montant des avances ne peut excéder le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché.
5. Si le titulaire du marché est chargé d'acquérir pour le compte de l'autorité contractante, soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués, le montant des avances ne peut excéder 60 % du montant des dépenses se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérée. Les avances peuvent être versées préalablement au paiement effectif de ces dépenses dès la conclusion du contrat d'achat ou de commande.

Avec ces dispositions, le Code des marchés publics cherche à préserver les finances du titulaire du marché qui ne doit pas être laissé sans contrepartie par rapport aux dépenses souvent lourdes nécessitées par l'exécution des prestations.

Un contrôle est néanmoins toujours nécessaire. En effet, au-delà des plafonds à respecter, l'Autorité contractante doit s'assurer que :

- les dépenses effectuées sont réellement liées à l'exécution des prestations objet du marché ;
- que le matériel acheté correspond à celui qu'avait présenté le titulaire dans son offre au stade de la soumission ;
- que ce matériel est réellement nécessaire à l'exécution des prestations objet du marché ;
- que les prix d'achat et de revient indiqués dans les factures présentées par le titulaire sont sincères et reflètent la réalité du marché (les INCOTERMS sont très utiles à ce niveau)
- etc.

- les avances de démarrage :

Le Code des marchés publics, en son article 97, précise que ce montant ne peut excéder 20 % calculé soit sur le montant initial du marché, taxes comprises lorsque la durée d'exécution de celui-ci est inférieur ou égale à un an, soit lorsque la durée d'exécution est supérieure à un an sur le montant des prestations à réaliser au cours d'une première tranche de douze mois.

La base de la détermination du montant des avances est donc annuelle. Commettrait donc une irrégularité l'Autorité contractante qui, pour un marché d'une durée de trois ans, verse au titulaire 20% du montant des prestations que celui-ci doit exécuter dans les deux premières années.

Cette règle du calcul du montant des avances sur la base de la première année d'exécution du marché est aussi valable pour les marchés de clientèle et les marchés à commande.

VIII.2.1.b. Le remboursement des avances

- pour les avances en raison des dépenses engagées :

Les Autorités contractantes prendront le soin de préciser dans le CCAP, le rythme de remboursement de ces avances comme le précise l'article 96 du CMP. Le rythme de remboursement tiendra compte de la proportion des éléments ayant donné lieu à avances dans la partie du marché déjà exécutée.

Ce remboursement devra se faire par opération de déduction des sommes dues ultérieurement au Titulaire à titre d'acompte ou de solde.

- Pour les avances de démarrage :

Le remboursement des avances ne pose pas de problèmes particuliers. L'Autorité contractante ne fera que déduire leur montant des sommes dues au titulaire du marché.

L'article 97.4 du CMP fixe le début de ce remboursement des 20% au moment où le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint ou dépasse 40 % du montant initial du marché. Quant à l'achèvement de ce remboursement, il doit se faire lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 %. En d'autres termes, une fois que les prestations effectuées par le titulaire du marché atteignent, en termes de prix de base, 80% du montant total du marché, l'Autorité contractante devra avoir terminé de déduire des sommes dues au titulaire du marché, la totalité des avances que ce dernier a déjà reçues.

Mais il peut arriver que le marché ne donne pas lieu à versement d'acomptes et fasse l'objet d'un seul règlement ; dans une telle situation, l'article 97.4 du CMP, précise que l'avance forfaitaire est déduite en une seule fois du règlement unique.

VIII.2.2 Le versement d'acomptes aux titulaires de marchés publics

Les acomptes sont versés pour des prestations réalisées en cours d'exécution du marché. Mais ce versement n'est possible qu'à condition que le marché prévoie un délai d'exécution supérieur à trois mois. Contrairement donc aux avances (de démarrage) qui portent sur des prestations à venir, l'acompte rémunère un service fait. Il peut être d'une grande utilité pour des prestataires comme les PME qui peuvent rencontrer des difficultés pour faire face aux dépenses occasionnées par les prestations exécutées.

L'interdiction d'un double paiement implique nécessairement que des acomptes, soient déduits des sommes déjà versées au titre des avances.

VIII.2.3 Les délais de paiement

Le CMP instaure un régime de paiement encadrant les modalités et délais de paiement des marchés publics.

VIII.2.3.a. Le droit à paiement

L'article 106 du CMP précise que « les délais de constatation du droit à paiement du titulaire du marché sont fixés par les Cahiers des charges. Dans le mois qui suit la constatation du droit à paiement, le titulaire du marché et éventuellement les sous-traitants, bénéficiaires des dispositions de l'article 111 doivent être, le cas échéant, avisés des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l'objet d'un acompte au moins partiel ou d'un règlement pour solde. Si cette notification n'est faite qu'après expiration de ce délai d'un mois le retard ouvre droit automatiquement à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'à celui de la notification ».

Les sous-traitants dont il est question dans cette disposition sont ceux qui bénéficient du droit au paiement direct par l'Autorité contractante. La constatation du droit au paiement pour le titulaire et pour ces sous-traitants devra se faire dans les mêmes conditions.

VIII.2.3.b. Le délai de constatation du droit à paiement

Il est fixé par le cahier des charges. En matière de travaux, le CCAG intégré dans le dossier d'appel d'offres standard élaboré par l'ARMP, indique que : « le Maître d'Œuvre fixe la date des constatations ; lorsque la demande est présentée par l'Entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit (8) jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le Maître d'Œuvre contradictoirement avec l'Entrepreneur ».

Ces constats servent de base à l'établissement des décomptes, établis par l'Entrepreneur sur une base mensuelle. Les acomptes mensuels à régler à l'Entrepreneur sont quant à eux établis par le Maître d'Œuvre à partir de ces décomptes.

Les contestations portant sur ces constatations sont encadrées quant à elles dans un délai maximum de trente jours.

En d'autres termes, le délai de constatation est inséré dans un cadre mensuel lié à l'établissement des décomptes ; dans un cas comme dans l'autre l'Entrepreneur a la responsabilité d'initier la constatation de ces droits.

VIII.2.3.c. Le délai de paiement des acomptes

Conformément aux dispositions du CCAG Travaux, « le Maître d'Œuvre notifie à l'Entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'Entrepreneur a été modifié. Le paiement de l'acompte doit être fait au compte bancaire désigné au CCAP, et intervenir quarante-cinq (45) jours au plus tard après la date à laquelle le projet de décompte est remis par l'Entrepreneur au Maître d'Œuvre ».

Là encore, le point de départ du délai de paiement reste à l'initiative de l'Entrepreneur à travers la remise du projet de décompte. Il revient au Maître d'Œuvre de procéder aux modifications nécessaires dans ce délai.

Les dispositions de l'article 107 précisent quant à elle le point de départ du délai de paiement de 45 jours du CMP, compté en cas de contestation du droit à paiement, à partir du jour où le créancier a régularisé son dossier, suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article 106 du CMP.

VIII.2.3.d. Les intérêts moratoires en cas de retard

Pour inciter les Autorités contractantes à respecter cette règle, l'article 107.2 du CMP prévoit que le défaut de règlement dans ce délai de quarante cinq jours fait courir de plein droit et sans autres formalités des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'au jour du règlement. C'est donc un délai de rigueur qui est donné ici à l'Autorité contractante. Ces intérêts sont calculés sur le montant des droits à acompte ou à paiement pour solde à un taux supérieur de 2% au taux d'escompte de l'Institut d'émission.

VII.2.4 Les règles de paiement des sous-traitants

Le Titulaire du marché peut faire appel à d'autres entreprises pour exécuter certaines prestations, qu'il ne peut ou qu'il ne veut pas assurer lui-même. La sous-traitance favorise l'accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises.

VII.2.4.a. Les conditions préalables

Il n'y a pas de relation contractuelle entre le Maître d'Ouvrage et le sous-traitant. Seul le titulaire du marché est tenu par une obligation contractuelle vis-à-vis du Maître d'Ouvrage : il est responsable de l'ensemble des prestations exécutées au titre du marché, par lui-même et par les Sous-traitants. Par conséquent, en cas de défaillance des sous-traitants, l'Autorité contractante tiendra le Titulaire du marché pour seul responsable.

Le choix de sous-traiter peut être opéré par le Titulaire au moment de l'offre, de la proposition ou après la conclusion du marché. En tout état de cause, l'acceptation du Sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement doivent être prononcés avant l'exécution des travaux rémunérés par le paiement. Cet agrément sera alors un élément à part entière du marché. Dans ce cadre, l'article 48 du CMP favorise le recours en priorité à des petites et moyennes entreprises de droit sénégalais ou à des petites et moyennes entreprises communautaires.

La sous-traitance ne peut être totale ; en outre, afin de permettre à l'Autorité contractante d'avoir une lecture claire de l'exécution du marché, il est fait obligation au Titulaire du marché de préciser la répartition des prestations entre lui et chaque Sous-traitant.

VII.2.4.b. Le droit au paiement direct

Quant au règlement des prestations effectuées par les Sous-traitants, il est important de préciser qu'ils peuvent bénéficier d'un paiement direct de la part de l'Autorité contractante, avec l'accord du Titulaire du marché.

L'article 110 pose les conditions suivantes pour bénéficier de ce droit au paiement direct.

a) le Sous-traitant doit être agréé par l'Autorité contractante par une disposition expresse insérée, soit dans le marché, soit dans un avenant ; il est tenu de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers ;

b) le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise, la nature et la valeur des travaux, des fournitures ou services à exécuter par le Titulaire et par chacun des Sous-traitants nommément désignés ;

c) le Titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits en sus des titres de paiement émis en règlement des travaux, fournitures ou services exécutés par le Sous-traitant comme s'ils l'étaient par lui-même.

Ces conditions ne sont pas seulement applicables au règlement pour solde. Elles sont en effet valables également pour le versement des avances et acomptes.

Les dispositions de l'article 111 du CMP précisent en outre que le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.

VII.2.5 Le nantissement des créances nées du marché

Traité aux articles 121 à 127 du CMP, il s'agit d'un contrat conclu entre le Titulaire d'un marché public et un organisme financier (créancier nanti) dans lequel le premier va donner en gage au second, pour le financement du marché, une créance résultant de l'exécution du marché.

L'Autorité contractante doit être pleinement informée de toute opération de nantissement ou de cession de créances que ses cocontractants envisagent de faire (en rapport bien sûr avec le marché).

Le créancier nanti doit en effet ainsi notifier (de manière écrite), ou faire signifier à l'Autorité contractante une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement.

Mais en tout début de procédure, avant même que le contrat de nantissement ne soit envisagé ou conclu, l'article 122 du CMP, oblige l'Autorité contractante ou son représentant dûment habilité, de remettre au Titulaire du marché, après visa de l'ordonnateur du budget de la personne morale, une copie certifiée conforme de l'original du marché, revêtue de la mention «*exemplaire unique délivré en vue du nantissement*».

Sur ce dernier point, une difficulté d'application de cet article 122 peut se poser notamment par rapport à la question de la détermination de l'autorité responsable de la certification de la conformité de la copie du marché à nantir .

Sur cette question, par lettre du 09 mars 2009, la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) a saisi l'Autorité de Régulation des Marchés publics d'une demande de précision sur l'autorité habilitée à certifier la conformité de la copie d'un marché proposé à un nantissement.

Dans sa saisine, la DCMP estime qu'en tant qu'organe chargé du contrôle externe, il apparaît plus opportun de lui confier la responsabilité de procéder à la certification de la copie du marché à nantir¹².

Pour le CRD, «*Considérant que sous l'empire du décret n° 2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des Marchés publics, les attributs liés à la certification étaient exercés par le Bureau des Marchés du Ministère de l'Economie et des Finances, pour garantir exclusivement l'authenticité de la copie de l'original du marché à l'égard des tiers, notamment le bénéficiaire du nantissement ;*

¹²Avis n° 004/09/ARMP/CRD du 25 mars 2009 du CRD statuant en Commission Litiges sur la demande de la Direction centrale des Marchés publics portant sur la détermination de l'autorité habilitée à certifier la conformité de la copie d'un marché délivrée pour nantissement

Considérant que même si le nouveau Code des marchés publics ne détermine pas expressément l'autorité responsable de la certification de la conformité de la copie du marché à nantir, il est constant que la DCMP, organe chargé du contrôle a priori des procédures de passation des marchés, dispose des prérogatives liées à l'immatriculation et à l'archivage des marchés approuvés ; et qu'à ce titre la DCMP doit être habilitée à confirmer l'authenticité des copies de marchés destinées à un nantissement ;

Considérant que la fonction d'ordonnancement sur les marchés financés ou gagés sur le budget de l'Etat étant du ressort du Ministère de l'Economie et des Finances, il appartient à celui-ci d'en attribuer l'exercice à toute entité relevant de son autorité ».

Pour une parfaite application de l'article 122 susvisé, les Autorités contractantes sont donc invitées à saisir la DCMP pour l'authentification des copies de leurs marchés.

VIII.3 Les modifications au cours de l'exécution du marché

VIII.3.1 Les modifications relatives au prix

- La révision du prix

Eléments déclencheurs de la révision

L'objet de la révision des prix d'un marché est de tenir compte de la variation des conditions économiques constatées entre la date d'établissement des prix initiaux définis par les cahiers des charges et les dates d'expiration des délais fixés contractuellement pour l'achèvement de la réalisation des prestations objet du marché.

Formule de révision

Lorsqu'un marché est passé à prix révisable, les prix de ce marché sont révisés par application de la formule de révision de prix qui doit figurer audit marché.

Les cahiers des charges précisent la périodicité et les modalités d'application de la formule.

La formule est du type suivant :

$$REV = X + (a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo +$$

Dans laquelle :

- REV est le coefficient de révision qui s'appliquera à chaque paiement ;
- X constitue la partie fixe non révisable des paiements et (a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de pondération des facteurs sujets à révision sur la base des valeurs des indices, T, S, F, etc., étant précisé que $a + b + c + ... = 1$;
- T, S, F, etc., et To, So, Fo, représentent la valeur des indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule, étant précisé que les valeurs de T, S, F, seront celles en vigueur au cours du mois où interviendra le fait générateur de paiement, et les valeurs To, So, Fo, sont celles en vigueur au cours du mois de dépôt des offres.

Les valeurs de a, b, c, d, etc. et la définition spécifique des indices T, S, F etc. utilisés dans la formule doivent être précisées dans le dossier d'appel d'offres.

Normalement, les indices intervenant dans les formules de révision doivent être officiellement fixés et publiés périodiquement. En l'absence de source officielle, il peut être fait recours à des prix ou à des indices indiqués dans le dossier d'appel d'offres.

Dans le cas où les indices officiels devant servir à la révision de prix ne seraient connus qu'avec retard, des révisions provisoires seront calculées sur la base des dernières valeurs connues desdits indices ou à défaut sur la base des valeurs arrêtées d'un commun accord. Les révisions seront réajustées dès la parution des valeurs relatives aux mois considérés.

Sans que l'attributaire ait besoin de présenter une demande spéciale, la modification des prix est appliquée aux prestations qui restent à exécuter à partir de la variation des indices constatée par l'Autorité contractante.

Les nouveaux prix résultant de l'application de la formule de révision des prix sont pris en considération dans les paiements, sans que la passation d'un avenant au marché ne soit nécessaire.

L'alinéa 2 de l'article 23 du Code des marchés publics qui énumère les objets sur lesquels peut porter un avenant, n'inclut pas la prise en compte des nouveaux prix résultant de l'application de la formule de révision des prix.

Pour tenir compte des hausses éventuelles de prix, les marchés comportant une clause de révision de prix et leurs avenants doivent être engagés pour un montant majoré d'une provision pour tenir compte de la révision de prix. Normalement, cette provision ne devrait pas dépasser 5% du montant du marché ou de son avenant.

En cas de retard imputable à l'attributaire, dans l'exécution des prestations objet d'un marché à prix révisibles, l'Autorité contractante doit prendre toutes les dispositions utiles pour neutraliser l'effet de la révision des prix, en faisant application au montant des prestations exécutées pendant la période comprise entre la date contractuelle de fin d'exécution des prestations et la date réelle de leur achèvement, du plus faible des deux coefficients obtenus, sur la base des indices du mois d'exécution des prestations et de ceux du dernier mois du délai contractuel.

Il est important de noter que l'introduction même par avenant d'une clause de révision de prix dans un marché qui n'en prévoyait pas est impossible, car un tel acte fausserait le libre jeu de la concurrence ; l'exemple suivant illustre parfaitement cette règle¹³.

En effet, par lettre mémoire en date du 17 octobre 2011, AGEROUTE Sénégal a saisi le CRD aux fins de solliciter son avis relativement à la requête introduite par le groupement AREZKI/Green Line pour la prise en compte du préjudice financier subi du fait de l'augmentation des prix du gasoil, du bitume et du ciment lors de l'exécution des travaux d'aménagement de la route Labé- Sériba- Médina Gounass- Tambacounda et de facilitation du transport sur le corridor Conakry/ Dakar (tronçon Médina Gounass- Frontière Guinée).

¹³ Avis n° 015/11/ARMP/CRD du 26 octobre 2011 du CRD en Commission Litiges sur la demande d'autorisation introduite par AGEROUTE SENEGAL pour la prise en charge sous forme d'avenant, le préjudice financier subi par le groupement AREZKI/Green Line suite à l'augmentation des prix du gasoil, du bitume et du ciment dans le cadre de l'exécution des travaux d'aménagement de la route LABE- SERIBA- MEDINA GOUNASS- TAMBA- COUNDA et de facilitation du transport sur le corridor CONAKRY/DAKAR (tronçon Médina Gounass- frontière Guinée), subséquemment à l'avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP).

A l'appui de sa demande, le requérant a produit les copies des pièces suivantes :

- copie de la notification de l'Ordre de service n° 29/DGTOA/AATR ;
- lettre d'AREZKI n° 0200/YSR/AKS/2011/DAF du 25 mai 2011 et ses annexes (état des prix officiels en FCFA au titre du gasoil établi par le « Comité national des Hydrocarbures », l'Indice du Moniteur des prix du bitume, l'Etat des prix officiels en FCFA de la tonne de ciment CEM II 32,5 en sacs de 50 kgs établi par la SOCOCIM ;
- la lettre de la DCMP n° 4534/MEF/DCMP/13 du 03 octobre 2011 ;
- copie du procès verbal de réception provisoire des travaux.

En l'espèce, dans le cadre de l'exécution de ce marché, le groupement AREZKI/Green Line, désigné titulaire à la suite d'un appel à la concurrence, a saisi par lettre du 25 mai 2011, AGEROUTE Sénégal pour demander l'actualisation des prix du marché à la suite des « très fortes hausses qui ont frappé les produits pétroliers, essentiellement le gasoil et le bitume depuis la date de remise de notre offre (le 18 mars 2009) à nos jours ».

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, la DCMP a formulé son désaccord parce que selon elle, une clause de révision non prévue au contrat initial ne peut être introduite par voie d'avenant pour prendre en compte une fluctuation des prix.

Saisie à son tour pour avis, le CRD adopta le raisonnement suivant :

«(...) Considérant que selon les dispositions de l'article 10.4 du cahier des Clauses administratives générales du dossier d'appel d'offres (DAO), les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables ;

Que cette révision des prix ne peut intervenir que si elle est expressément prévue dans le Cahier des Clauses administratives particulières par le biais d'une formule de révision ;

Considérant qu'en application de cette disposition, l'Autorité contractante a pris l'option, au niveau de la clause 4 de la Lettre de marché souscrite par les parties le 24 septembre 2009, de mentionner que les prix sont fermes et non révisables, malgré la durée de dix-huit (18) mois prévue pour l'exécution des prestations ;

Considérant également que le groupement d'entreprises AREZKI/Green Line fait droit à une révision des prix des intrants, sur la base des quantités de gasoil, de bitume et de ciment consommés depuis le démarrage des travaux jusqu'en avril 2011, alors qu'il avait toute latitude d'introduire une requête pour la prise en charge desdites variations lors de la signature des avenants n° 1 et 2 respectivement souscrits le 10 juin 2010 et le 18 octobre 2010 ;

Que ne l'ayant pas fait, il ne peut attendre la fin du marché litigieux dont les travaux ont fait l'objet d'une réception provisoire le 09 juillet 2011, pour introduire auprès de l'organe chargé du contrôle a priori, la demande de prise en charge du préjudice financier subi, si l'on se réfère aux dispositions de l'article 23.3 du Code des marchés publics modifié qui prévoit qu'aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet ; par conséquent »,

La révision ne fut donc pas acceptée, et le CRD indiquait que « pour obtenir réparation du préjudice évoqué, l'attributaire du marché peut introduire, devant le juge, une requête pour obtenir une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le Code des Obligations de l'Administration ».

- L'actualisation du prix

Le montant d'un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite de validité des offres et la date du début d'exécution du marché, en appliquant la formule d'actualisation stipulée dans le cahier des charges.

La formule est du type suivant :

$$ACT = (a) T/T_0 + (b) S/S_0 + (c) F/F_0 + \dots$$

- REV est le coefficient d'actualisation qui s'appliquera au montant du marché ;
- (a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de pondération des facteurs sujets à actualisation sur la base des valeurs des indices, T, S, F, etc ;
- Les valeurs respectives des paramètres a, b, c, etc. sont fixées dans le cahier des charges, étant précisé que $a + b + c + \dots = 1$;
- T, S, F, et T_0 , S_0 , F_0 , représentent la valeur des indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule ; la définition et l'origine de ces indices sont spécifiées dans le cahier des charges, étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur à la date d'actualisation du prix, et les valeurs T_0 , S_0 , F_0 , sont celles en vigueur à la date limite de validité des offres.

Les valeurs a, b, c, d, et la définition spécifique des indices T, S, F utilisés dans la formule, doivent être précisées dans le cahier des charges.

L'actualisation ne s'applique qu'à un marché à prix ferme ; elle est sans objet dans le cas d'un marché à prix révisable.

Contrairement à la révision des prix qui ne peut être introduite par avenant à un marché à prix ferme, l'actualisation des prix d'un marché conclu à prix ferme sans clause d'actualisation, peut être autorisée par avenant.

D'une manière générale, lorsqu'un marché est conclu à prix ferme, les modalités de l'actualisation doivent normalement être prévues dans les cahiers des charges.

VIII.3.2 Les modifications relatives aux prestations

VIII.3.2.a. Les avenants

L'avenant est l'acte par lequel les parties à un contrat conviennent de modifier ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses. Un avenant ne peut ni modifier l'objet d'un contrat ni en bouleverser l'économie. La seule exception à cette règle concerne les sujétions techniques imprévues découlant de circonstances non imputables aux parties. Un avenant n'est pas un marché à part mais est soumis aux mêmes procédures de conclusion et d'approbation qu'un marché. De plus, toutes les garanties exigées au titre du marché de base le sont pour l'avenant.

L'article 23 du Code des marchés publics énumère de manière limitative les objets sur lesquels peut porter un avenant ; il s'agit des cas suivants :

- modification sans incidence financière affectant l'Autorité contractante ou le Titulaire du marché ;
- modification de la masse des fournitures, travaux ou services au-delà des limites prévues par le DAO ;
- réalisation de prestations non prévues au marché mais rendues nécessaires pour la réalisation de son objet du fait de sujétions techniques imprévues ;
- modification du délai d'exécution du marché initial.

L'introduction de nouveaux prix dans un avenant doit être accessoire ; la variation porte substantiellement sur la masse des prestations.

Par ailleurs, le COA comme le Code des marchés publics, proscrivent les avenants de régularisation ; autrement dit, un avenant ne peut couvrir des prestations complémentaires au marché initial, prestations qui auraient été effectuées avant même la procédure de passation et de notification dudit avenant. L'avenant doit également intervenir avant la réception provisoire des prestations ou fournitures objet du marché de base.

Ces deux conditions imposent une démarche proactive de la part de l'Autorité contractante à qui il revient de sacrifier aux formalités de conclusion et d'approbation de l'avenant dans le strict respect des dispositions réglementaires ainsi que des exigences de programmation des prestations.

Conformément à l'article 24 du Code des marchés, le taux maximal d'un avenant est limité à 30% du montant du marché initial après prise en compte des variations consécutives à d'éventuelles clauses d'actualisation et ou de révision.

L'avenant, comme le marché complémentaire, visé à l'article 76 du CMP, est attribué au titulaire du marché initial. Mais il ne peut être dissocié du contrat de base ni constituer un nouveau marché, alors que le marché complémentaire constitue un nouveau marché, autonome, mais justifié notamment par l'existence d'un précédent contrat. La passation de l'avenant ayant pour objet l'exécution de travaux dissociables des travaux prévus par le marché initial est irrégulière : l'exécution de ces travaux doit donner lieu à la conclusion d'un marché distinct.

Il est important de préciser qu'un ordre de service ne peut pas se substituer à un avenant. A titre d'exemple, une suspension des délais pour cause d'intempérie peut être déclenchée par ordre de service mais une prorogation des délais contractuels ne peut être matérialisée que par avenant.

VIII.3.2.b. Les ordres de services

L'ordre de service est un acte administratif pris par l'Autorité contractante (ou le Maître d'Ouvrage délégué) à l'intention du Titulaire du marché. Il est la manifestation de son pouvoir de direction dans l'exécution du marché. En principe, les ordres de service sont écrits, datés et signés par l'autorité qui les prend. Lorsqu'ils sont réguliers, ils s'imposent à l'Entrepreneur.

Il existe trois exceptions à ce principe selon lesquelles le titulaire peut valablement refuser de se conformer à un ordre de service :

- lorsque l'ordre de démarrage des travaux n'intervient pas dans le délai prévu au contrat ;
- lorsque l'ordre de service concerne des travaux supplémentaires d'une nature différente de l'objet du marché et dépassant la masse initiale des travaux ;
- et, quand une tranche conditionnelle du marché n'est pas débloquée dans le délai contractuellement prévu.

Quoi qu'il en soit, le titulaire peut toujours contester l'ordre reçu en émettant des réserves écrites dans les délais prescrits à compter de leur réception pour les marchés de travaux.

Si ces ordres de services, de par leur procédure ou objet, engendrent un contentieux, le titulaire du marché peut entamer une procédure de contestation auprès du Comité de Règlement des Différends (article 138 du Code des marchés publics) ou du juge compétent en fonction de la qualité de l'Autorité contractante (article 139 du Code des marchés publics).

VIII.3.2.c. Les marchés complémentaires

A la différence de l'avenant, le marché complémentaire concerne des prestations non prévues au contrat initial et induisant généralement de manière significative de nouveaux prix à établir dans le cadre de négociations. C'est pourquoi d'ailleurs, le marché complémentaire est rangé dans la catégorie des marchés par entente directe par l'article 76.1b du Code des marchés publics. Il constitue un contrat totalement détaché du marché initial mais rendu nécessaire pour la réalisation de l'objet de ce dernier. De fait, il a pour objet des fournitures, services ou travaux qui ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal.

De plus, le marché complémentaire ne peut être conclu que si le contrat initial a été attribué suite à un appel d'offres.

Le montant d'un marché complémentaire est plafonné à un tiers du montant révisé du marché initial augmenté de ses avenants.

Le marché complémentaire ne doit pas être assimilé à une échappatoire pour une Autorité contractante ayant épuisé ses possibilités de recours à un avenant. L'avenant et le marché complémentaire sont deux modes différents qui obéissent à des conditions clairement définies par le Code des marchés publics en ses textes susvisés.

VIII.4 Les incidents d'exécution du marché public

VIII.4.1 L'ajournement

L'ajournement consiste à suspendre pour une durée déterminée, l'exécution d'un marché ; l'ajournement d'un marché peut être prononcé par l'Autorité contractante avant ou après le début de l'exécution du marché. L'ajournement ne peut intervenir que lorsqu'une circonstance indépendante de la volonté de l'Autorité contractante contraint cette dernière à suspendre l'exécution d'un marché ou à différer son lancement.

Mais il peut être décidé également être décidé en cas de manquement du Titulaire du marché à ses obligations. Cette dernière possibilité est prévue aux articles 128 et 131 du Code des marchés publics. Cette dernière disposition dispose que « *l'Autorité contractante peut ordonner l'ajournement des fournitures, prestations ou travaux, objet du marché, avant leur achèvement, notamment en cas de retard dans l'exécution d'un ouvrage ou dans la livraison d'une fourniture lui incombant et nécessaire à l'exécution du marché, ou pour toute autre raison qui lui est propre* ».

Mais quel qu'en soit le motif, cet ajournement des prestations ne peut excéder trois (3) mois. C'est l'interprétation qu'il faut faire de l'article 132.1 du Code des marchés publics qui prévoit la possibilité, pour le titulaire du marché, de demander la résiliation du marché « *lorsque l'Autorité contractante prescrit l'ajournement du marché pour plus de trois mois (...)* » ou en cas « *d'ajournements successifs dont la durée globale dépasse trois mois, même dans le cas où l'exécution du marché a été reprise entre-temps* ».

Le préjudice causé par l'ajournement peut être compensé par une indemnité payée au Titulaire du marché. Mais cette indemnité prévue à l'article 132 du Code des marchés publics n'est pas due si cet ajournement a été consécutif à une défaillance du Titulaire du marché public.

L'article 132.1 du Code des marchés publics dispose que « *l'indemnité pour préjudice subi à laquelle a droit le titulaire du marché en cas d'ajournement inférieur à trois mois ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet ajournement, telles qu'elles résultent des justificatifs produits par le titulaire* ».

Cette indemnité doit être juste et doit être proportionnel au préjudice subi. Mais c'est au Titulaire d'apporter les preuves de son préjudice et les pièces établissant toutes les dépenses antérieures à l'ajournement et strictement rendues nécessaires par l'exécution des prestations objet du marché.

Quant au délai de demande de l'indemnité, l'article 134.4. du Code des marchés publics dispose que *« la demande du titulaire n'est recevable que si elle est présentée dans le délai de deux mois à partir de la date de notification de l'ordre de service prescrivant l'ajournement de l'exécution du marché »*.

Cette demande est à adresser à l'Autorité contractante elle-même ou à son supérieur hiérarchique, le cas échéant. Si cette demande est rejetée, le Titulaire peut saisir le Comité de Règlement des Différends. Tant qu'il n'est pas satisfait des décisions rendues sur ses différentes demandes, il peut poursuivre la procédure de demande d'indemnisation devant le juge compétent. Si le marché le prévoit, cette divergence peut être réglée au moyen d'une procédure d'arbitrage.

VIII.4.2 La résiliation

Elle est prévue aux articles 129 et suivants du Code des marchés publics. La résiliation d'un marché consiste en l'arrêt définitif de son exécution avant sa date normale d'achèvement.

• La résiliation à l'initiative de l'Autorité contractante

Les articles 129 et 132 du Code des marchés publics indiquent, respectivement, les principaux cas possibles de résiliation des marchés à l'initiative de l'Autorité contractante et à la demande du Titulaire.

L'article 129 du Code dispose : *« Tout marché public peut faire l'objet d'une résiliation totale ou partielle à l'initiative de l'Autorité contractante :*

- a) en cas de manquement grave du Titulaire à ses obligations contractuelles, notamment, en matière environnementale ;*
- b) lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public ;*
- c) en cas de survenance d'un événement affectant la capacité juridique du Titulaire du marché dans les conditions fixées par les cahiers des charges ».*

La résiliation pour violation des règles environnementales n'existait pas dans l'ancien Code des marchés publics (celui de 2007). Mais pour que cette disposition puisse être appliquée pleinement, il faut qu'il y ait, dans les documents contractuels, un cahier des clauses environnementales. Si ce document n'est pas établi, les Autorités contractantes doivent alors prendre le soin de définir ces obligations environnementales dans le CCAP et, également, dans le contrat lui-même.

Outre ces cas de résiliation, le Code des marchés publics prévoit des cas où l'Autorité contractante peut prononcer la résiliation de plein droit et sans indemnités. Ces cas sont prévus à l'article 130 du Code des marchés publics.

Ces résiliations sont prononcées :

- a) en cas de décès du cocontractant personne physique, si l'Autorité contractante n'accepte pas, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux ;*
- b) en cas de faillite, si l'Autorité contractante n'accepte pas, dans l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de l'entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation ;*
- c) en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le cocontractant n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise.*

Pour ces deux derniers cas, le dernier aliéna de l'article 130 dispose que *« (...) les mesures conservatoires ou de sécurité dont l'urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office et mises à la charge du Titulaire du marché »*.

Ces mesures prises dans ces circonstances n'ouvrent droit à aucune compensation financière au profit du Titulaire.

Il conviendrait d'ajouter à ces résiliations à l'initiative de l'Autorité contractante, le cas prévu par l'alinéa 3 de l'article 149 qui dispose que la résiliation peut aussi être prononcée en cas de constatation de violations des règles de passation de marchés commises par le Titulaire, même si elles ont été constatées après l'attribution du marché. Ces violations sont définies à l'article 148 du CMP.

Mais dans toutes les situations où la résiliation n'est pas de plein droit et s'explique par un manquement du Titulaire à ses obligations, l'Autorité contractante doit d'abord adresser à celui-ci une mise en demeure. Celle-ci doit avoir pour objet de rappeler les obligations non respectées tout en accordant au titulaire un délai pour se conformer à ses engagements sous peine de résiliation. Cette mise en demeure doit être adressée par tout moyen permettant de déterminer une date certaine de réception par le titulaire.

Une résiliation consécutive à une défaillance du Titulaire peut avoir des conséquences financières très importantes pour ce dernier. En effet, en plus des indemnités que peut demander l'Autorité contractante, le Titulaire défaillant doit supporter les conséquences financières de la passation d'un nouveau marché avec un autre Prestataire, Entrepreneur, Fournisseur ou Consultant. C'est le sens du deuxième alinéa de l'article 136 du Code des marchés publics qui dispose que *« lorsqu'il résulte du nouveau marché, passé aux risques et périls du titulaire défaillant, des excédents de dépense, ceux-ci sont prélevés sur les sommes dues au cocontractant ou, à défaut, sur la garantie de bonne exécution ou sur la retenue de garantie, sans préjudice des droits à exercer sur lui en cas d'insuffisance »*.

Pour les besoins de mise en œuvre de cette disposition, l'Autorité contractante doit établir un décompte provisoire de résiliation afin, par exemple, de mettre à la charge du titulaire les conséquences onéreuses du marché de substitution. Dans le cas d'un marché de travaux, par exemple, il conviendra de constater les travaux. L'inventaire des ouvrages réalisés, des matériaux approvisionnés, du matériel et des installations de chantier est dressé de manière contradictoire dans un procès-verbal. Le bilan financier devra aussi être établi. Toutes les mesures conservatoires nécessaires doivent alors être prises, notamment concernant la sécurité du chantier et, si nécessaire, l'exécution des sûretés établies par le titulaire.

Le décompte définitif de la résiliation ne sera établi qu'une fois le marché de substitution totalement réglé.

Les dépenses mises à la charge de l'Entrepreneur doivent correspondre au coût d'achèvement des travaux et doivent permettre de couvrir la différence résultant des conditions financières du marché réadjudgé et de celles du marché initial, y compris s'il y a lieu, l'actualisation des prix.

Toutefois, le nouveau marché doit normalement avoir le même objet que le marché initial, et les travaux qui y sont prévus ne devraient pas différer de ceux ayant fait l'objet du marché initial.

Il faut noter tout de même que des interprétations diverses peuvent se poser quant à l'autorité compétente pour prononcer la résiliation. Pourtant, l'article 129 du CMP, en son point 2, reconnaît à l'Autorité contractante la compétence pour prononcer la résiliation. En effet, cette disposition précise que *« (...) l'Autorité contractante ne peut prononcer la résiliation pour manquement du titulaire à ses obligations qu'après mise en demeure préalable restée sans effet »*. Cette même formulation était déjà utilisée dans les anciens textes, notamment les codes de 2007 et 2011.

Toujours est-il que la question de cette compétence pour prononcer la résiliation d'un marché public s'interprète différemment, et l'ARMP a eu à apporter une réponse¹⁴.

En effet, par lettre mémoire en date du 26 avril 2011, le Directeur de la Direction centrale des Marchés publics avait saisi le CRD d'une demande d'avis relative à la détermination de l'autorité compétente pour résilier un marché.

¹⁴Avis n° 008/11/ARMP/CRD du 04 mai 2011 du CRD statuant en Commission Litiges sur la demande d'avis de la Direction centrale des Marchés publics relative à la détermination de l'autorité compétente pour résilier un marché.

En l'espèce, la DCMP a exposé avoir été saisie par l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) pour avis sur le dossier d'appel d'offres relatif à la poursuite des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Fatick-Bambey, suite à la résiliation du marché initialement contracté avec le Groupement d'entreprises ZAKHEIM/SOECO pour la réalisation desdits travaux.

AGEROUTE n'a pas produit d'arrêté de résiliation puisqu'elle considérait que « le Code des marchés publics ne prévoit pas pour la résiliation [d'un marché public] un arrêté du Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances en charge du Budget ».

C'est dans ces conditions que la DCMP avait saisi l'ARMP pour avis et celle-ci, invoquant le parallélisme des formes en matière administrative, a indiqué que l'autorité compétente pour approuver un marché public, lui donnant donc effet, l'est également pour prononcer sa résiliation. Le raisonnement du CRD était le suivant : « Considérant qu'en dehors de ces prescriptions, le Code ne fournit aucune indication sur la procédure de résiliation et l'organe compétent pour donner effet à la décision de résiliation ;

Considérant qu'à cet égard, il est de principe, qu'en l'absence de procédures spéciales expressément prévues, un acte qui a été entouré obligatoirement de certaines formes substantielles ne peut être mis à néant ou modifié par un acte contraire que moyennant l'accomplissement des mêmes formalités ; qu'en vertu de ce principe dit de parallélisme des formes et des procédures, ce qui était nécessaire pour l'acte initial l'est encore pour l'acte résolutoire ;

Considérant que, s'agissant des marchés publics, aux termes de l'article 82 du Code des marchés publics, les marchés signés sont soumis à l'approbation d'autorités désignées à cet effet par l'article 29 du Code qui dispose que l'acte d'approbation, matérialisé par la signature de l'autorité compétente à ce titre, est la formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché ;

*Que, par ailleurs, l'article 44 du Code des Obligations de l'Administration dispose que « **lorsque le contrat est soumis à l'approbation d'une autorité administrative autre que celle qui contracte, il ne peut produire effet qu'après cette approbation** » ;*

Considérant qu'il résulte de cette disposition combinée à celle des articles 29 et 82 du Code des marchés publics, que l'approbation est une formalité substantielle à la conclusion des marchés publics ;

Or, considérant que selon le principe du parallélisme des formes ou des procédures, les formalités substantielles qui ont prévalu à la conclusion d'un acte, doivent nécessairement être observées pour sa modification ou sa résolution ;

Qu'à cet égard, par application des dispositions de l'article 29 du Code des marchés publics, l'autorité compétente pour donner effet à la décision de résiliation d'un marché litigieux est celle désignée pour l'approuver ».

En définitive, pour éviter tout problème d'interprétation entre cet avis et l'article 129.2 du CMP précité, il faut juste comprendre que l'initiative de la résiliation ainsi que la décision provisoire, sont prises par l'Autorité contractante. Par contre, pour que cette décision prenne effet, il faudrait que celle-ci la transmette à l'autorité qui a approuvé le marché pour qu'elle se prononce sur cette décision. Il est indiqué aux Autorités contractantes qu'elles doivent transmettre à cette autorité d'approbation tous les éléments du dossier, notamment les faits à l'origine de la décision (provisoire) de résiliation et les échanges que les deux parties au contrat ont eus par la suite, sur cette question.

• La résiliation à l'initiative du Titulaire du marché

Cette possibilité est prévue à l'article 132 du CMP qui dispose : « Un marché public peut faire l'objet d'une résiliation à la demande du Titulaire :

- a) en cas de carence de l'Autorité contractante rendant l'exécution du marché impossible, constituant une faute grave au sens du Code des Obligations de l'Administration ;
- b) Lorsque l'Autorité contractante prescrit l'ajournement du marché pour plus de trois mois, soit avant, soit après un commencement d'exécution. Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée globale dépasse trois mois même dans le cas où l'exécution du marché a été reprise entre-temps ».
- c) En cas de survenance d'un événement imprévisible et irrésistible rendant impossible l'exécution du marché

Tous ces cas de résiliation visent à préserver la viabilité financière du Titulaire du marché public. Mais contrairement à l'Autorité contractante, le Titulaire du marché ne dispose pas du pouvoir de résiliation de plein droit du marché, même si cette dernière manque gravement à ses obligations contractuelles. Le titulaire doit toujours faire une demande auprès du juge du contrat. Le juge du contrat est le juge administratif, sauf en ce qui concerne les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire pour lesquels l'article 138 du Code des marchés publics attribue au juge de droit commun, compétence pour en connaître les litiges.

L'article 133.2 du Code des marchés publics prévoit une compensation financière dans tous les cas où la résiliation est imputable à l'Autorité contractante.

Dans ces cas, le titulaire peut demander le versement d'une indemnité correspondant au préjudice subi dûment constaté qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à la perte de ses bénéfices se rapportant au marché. Il doit nécessairement produire toutes les pièces justificatives permettant de déterminer avec exactitude le montant de ces pertes.

Tant qu'une faute ne lui est pas imputable, toutes les prestations déjà exécutées doivent être réglées aux conditions du marché.

Le sort des prestations exécutées avant la résiliation du marché est réglé par l'article 133.3 du Code des marchés publics qui reconnaît la possibilité, pour, le titulaire, de demander qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés ou livrés, puis à leur réception définitive après l'expiration de la période de la garantie.

Tout comme en matière d'ajournement, les demandes du Titulaire ne sont recevables que si elles sont exercées dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation.

VIII.4.3 La force majeure

Elle n'est admise que dans des conditions restrictives et cumulatives :

- 1- l'événement doit être totalement indépendant de la volonté des cocontractants

Il ne doit point être le fait ni du Titulaire du marché, ni de l'Autorité contractante ; il doit leur être totalement extérieurs.

- 2- l'événement doit être imprévisible dans sa survenance

Cette condition signifie qu'il faut que l'événement constitutif d'une force majeure n'ait pu raisonnablement être envisagé par les parties au moment de la conclusion du marché ;

- 3- l'événement doit être irrésistible dans ses effets

L'événement doit mettre le titulaire dans l'impossibilité absolue d'exécuter le contrat ; il doit être un obstacle insurmontable à l'accomplissement des prestations objet du marché. Un événement peut être indépendant de la volonté des parties et imprévisible sans pour autant constituer une force majeure étant donné qu'il n'a engendré que des difficultés mineures ou, en tous cas, qui ne mettent pas le Titulaire dans l'impossibilité d'exécuter le marché.

Quant aux effets, la force majeure permet, pour le Titulaire, de se libérer de ses obligations contractuelles. L'exonération peut être partielle ou totale dans tous les systèmes de responsabilité. Elle permet au Titulaire de demander la résiliation du marché sans être tenu au paiement d'une indemnité.

Par ailleurs, si la force majeure, sans rendre définitivement impossible l'exécution du contrat, l'a retardée pendant un certain temps, le titulaire peut :

- prétendre à l'exonération des pénalités de retard pour la fraction du retard imputable à la force majeure ;
- et, s'il poursuit l'exécution du contrat, demander qu'il lui soit fait application de la théorie de l'imprévision lorsque ce retard aura entraîné le bouleversement de l'économie de son contrat.

VIII.4.4 La substitution d'entreprise

Cette procédure évoquée précédemment, est prévue à l'article 136 du Code des marchés publics. Lorsque l'Autorité contractante prononce la résiliation d'un marché pour manquements graves du titulaire, elle a la possibilité, pour éviter de compromettre l'exécution des prestations, de substituer une autre entreprise à l'entreprise défaillante. Si dans cette hypothèse, elle décide de recourir à une procédure autre que l'appel d'offres ouvert, elle devra solliciter l'avis de la DCMP.

Si le recours à une nouvelle entreprise doit entraîner un accroissement du montant de la commande, le surcoût viendra en déduction des sommes dues par l'Autorité contractante au titulaire défaillant. A l'inverse, si le recours à un nouvel intervenant se traduit par des économies sur le montant initial, celles-ci restent entièrement acquises à l'Autorité contractante sans que le Titulaire défaillant ne puisse prétendre au reversement d'une partie de ces économies.

L'établissement du marché de substitution doit être basé sur l'offre soumise par le nouveau Titulaire à laquelle sont appliquées les formules de révision ou d'actualisation des prix dans les conditions prévues par le cahier des charges.

Lorsque toutes les tentatives se seront avérées infructueuses, il sera alors procédé à une nouvelle consultation dans les conditions prévues par le Code des marchés publics (appel d'offres ouvert ou restreint).

VIII.5 La fin des prestations

VIII.5.1 Le procès-verbal de réception des prestations

La réception des travaux, fournitures ou services est l'occasion d'établir un constat sur la conformité ou non des prestations par rapport aux prescriptions du marché.

Elle est régie par l'article 109 du CMP qui précise que dans l'hypothèse où les prestations fournies par le titulaire ne correspondent pas exactement aux conditions convenues dans le marché, plutôt que de refuser la réception correspondante, la commission chargée de la réception peut proposer au titulaire d'appliquer une réfaction sur le prix global du marché ou sur les prix unitaires. Si un accord est établi sur cette proposition de réfaction, une réception provisoire est effectuée constatant l'accord des parties sur la réfaction retenue.

En tout état de cause, un procès-verbal de réception provisoire ou définitif doit nécessairement être établi. Il doit être dûment signé d'une part, pour l'Autorité contractante, par les personnes habilitées pour attester de la réalité de la prestation et de son exécution conforme à la commande et, d'autre part, par le Titulaire du marché. Ce procès-verbal doit contenir toutes les informations relatives aux constats des différentes parties. En cas de réception provisoire, la nature des malfaçons doit nécessairement être précisée.

VIII.5.2 Le classement et l'archivage des dossiers de marchés

L'article 1^{er} de l'arrêté pris en application de l'article 35 du Code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes précise que c'est celles-ci qui doivent procéder au classement et à l'archivage de tous les documents relatifs aux marchés publics passés par les différents services.

En application de cette réglementation, il appartient aux Autorités contractantes de veiller à l'accomplissement de cette formalité qui est une phase du processus de passation du marché public. Au-delà de l'importance que cette formalité revêt dans la mise en œuvre du principe de la transparence dans les procédures de marchés publics, elle facilite l'accomplissement du contrôle a posteriori de l'ARMP, que ce soit par le biais des enquêtes ou des audits. En outre, cette formalité est très importante pour la Direction des Statistiques et de la Documentation qui est chargée de la mise en œuvre de la politique de l'ARMP en matière de statistiques, de documentation et d'archivage.

Pour institutionnaliser davantage cette obligation pour les Autorités contractantes, l'ARMP a d'ailleurs adopté une résolution (n°23/09) relative à l'adoption du manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés publics.

IX. LES REGLES DU CONTENTIEUX DES MARCHES PUBLICS

IX.1 Les recours dans la procédure de passation de marché

1./ L'obligation du recours préalable

Ce recours préalable est à exercer auprès de l'Autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique.

• Les aspects de la procédure susceptibles de faire l'objet du recours préalable

C'est l'article 89 du Code des marchés publics qui les énumère. Sont concernés notamment :

- la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché,
- les conditions de publication des avis,
- les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées,
- le mode de passation et la procédure de sélection retenus,
- la conformité des documents d'appels d'offres à la réglementation,
- les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation.

• Le délai du recours gracieux ou hiérarchique

Désormais, avec la nouvelle rédaction de l'article 89 du CMP, les délais sont exprimés en jours ouvrés et francs (avec l'ancien texte, c'était en jours ouvrables)

Il est indiqué aux Autorités contractantes que l'expression « **jours ouvrés** » indique : tous les jours effectivement travaillés dans une entreprise considérée.

Avec un délai indiqué en « **jours francs** », le décompte s'opère à partir de la fin du jour de référence par durée de 24 heures ; elle est utilisée pour calculer un délai qui ne court qu'à partir de la fin du jour de référence.

Exemple : un délai de 7 jours francs, débutant un lundi, s'achève le lundi suivant au soir minuit.

Pour en revenir à l'article 89 précité du CMP, le délai d'exercice du recours préalable est de cinq (5) jours francs à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché, de l'avis d'appel d'offres ou de la communication de la demande de proposition.

Pour calculer, correctement, ce délai, il ne faut pas prendre en compte le jour de la publication de l'avis d'attribution, de l'avis d'appel d'offres ou de la communication de proposition. Si cette publication est apparu un jeudi par exemple, le premier jour des délais est le vendredi et le dernier jour est le mardi à minuit.

Avec un délai indiqué en « *jours francs* », le décompte s'opère à partir de la fin du jour de référence par durée de 24 heures ; elle est utilisée pour calculer un délai qui ne court qu'à partir de la fin du jour de référence.

Exemple : un délai de 7 jours francs, débutant un lundi, s'achève le lundi suivant au soir.

Pour en revenir à l'article 89 précité du CMP, le délai d'exercice du recours préalable est de cinq (5) jours francs à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché, de l'avis d'appel d'offres ou de la communication de la demande de proposition.

Pour calculer, correctement, ce délai, il ne faut pas prendre en compte le jour de la publication de l'avis d'attribution, de l'avis d'appel d'offres ou de la communication de proposition. Si cette publication est apparu un jeudi par exemple, le premier jour des délais est le vendredi et le dernier jour est le mardi à minuit.

• La forme du recours gracieux ou hiérarchique

Le recours prévu à l'article 89 du Code des marchés publics doit ;

- identifier le requérant,
- rappeler les références de la procédure de marché visée ;
- contenir des éléments de fait et de droit (c'est le sens de l'article 89 qui exige que ce recours invoque « *une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics* ») ;
- préciser les prétentions du requérant ; ce qu'il demande à l'Autorité contractante ou à son supérieur hiérarchique ;
- être daté et signé du requérant ;
- comporter en annexe l'avis concerné ou la partie du DAO faisant l'objet de la contestation.

Ce recours doit être envoyé par tout moyen permettant de déterminer une date de réception certaine par son destinataire. C'est la raison pour laquelle l'article 89 du Code dispose que ce recours doit être notifié par « *une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé* ».

Si en tant qu'Autorité contractante vous êtes saisie d'un recours gracieux, vous disposez de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de celui-ci, pour y répondre. La réponse doit être la plus intelligible possible et porter, le cas échéant, sur tous les motifs invoqués par le requérant. Le défaut de réponse dans le délai sus-indiqué constitue une décision implicite de rejet, attaquable également devant le CRD de l'ARMP.

2. / Le recours devant le Comité de Règlement des Différends de l'ARMP

Les recours sont introduits auprès du Secrétariat du Comité de Règlement des Différends selon des modalités définies aux articles 90 et suivants du Code des marchés publics.

Ce comité est compétent pour connaître des contestations portant notamment sur les décisions relatives à l'attribution des marchés, les conditions de publication des avis (cas de non respect des délais de publication, publication dans un support inapproprié), le mode de passation et la procédure de sélection, la conformité des documents d'appel d'offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues (cas de spécifications propres à une marque de fabrication), les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées (cas des cautions fixées à un niveau disproportionné par rapport à la taille du marché), et les critères d'évaluation (cas de critères de jugement subjectifs ou sans rapport avec l'objet du marché).

Pour éviter le fait accompli consistant à finir la procédure de passation d'un marché incriminé sans attendre la décision du CRD, l'article 91 du Code des marchés publics précise qu'en cas de recevabilité, ce recours est suspensif de la procédure de passation. L'Autorité contractante doit faire arrêter la procédure dès qu'elle y a été invitée par l'organe de régulation et ne la poursuivre qu'après notification par décision du CRD.

Cette recevabilité dépendra des éléments suivants :

• Le délai de recours devant le CRD

Le second alinéa de l'article 89 est très utile pour une bonne compréhension des délais de recours devant le CRD. Cet alinéa dispose que « *la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq jours ouvrables, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d'un rejet implicite du recours gracieux* ».

Pour saisir le CRD, l'article 90 du Code des marchés publics précise : « *En l'absence de suite favorable de son recours gracieux, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de trois (3) jours mentionné à l'article précédent pour présenter un recours au Comité de Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé auprès de l'organe chargé de la régulation des marchés publics* ».

Le non respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité du recours conformément aux dispositions des articles 89 du CMP et 9 de l'arrêté portant manuel de procédure du CRD.

• **Forme du recours devant le CRD**

Tout comme le recours gracieux, le recours auprès du CRD doit :

- identifier le requérant ;
- rappeler les références de la procédure de marché visée ;
- contenir des éléments de fait et de droit ; préciser les prétentions du requérant ; ce qu'il demande au CRD ;
- être daté et signé par le requérant qui doit par ailleurs justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir ;
- être accompagné, le cas échéant, d'une copie de la réponse de l'Autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique, sur le recours préalable.

Mais une attention particulière doit aussi être portée à l'article 91 du Code des marchés publics en ce qu'il précise que « (...) ce recours n'est pas suspensif si l'Autorité contractante certifie par notification écrite adressée au Comité de Règlement des Différends et à la direction chargée du contrôle des marchés publics que l'attribution du marché doit être poursuivie immédiatement pour des raisons tenant à la protection des intérêts essentiels de l'Etat résultant de situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe naturelle ou technologique ».

Dans cette situation, le CRD vérifiera néanmoins si les motifs invoqués par l'Autorité contractante sont fondés. En tout état de cause, en cas de suspension, si le CRD ne se prononce pas dans le délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la réception des documents complémentaires demandés dans le cadre de l'instruction du recours, l'Autorité contractante peut reprendre la procédure de passation.

Il convient enfin de noter que les décisions rendues par le CRD ne sont susceptibles de recours qu'auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême.

IX.2 Les procédures de dénonciation

Aux termes de l'article 20 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, « le Comité de Règlement des Différends est chargé de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit le Comité en formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics, il saisit le Comité en formation disciplinaire ; s'ils constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes ».

Cette fonction doit être clairement dissociée de la fonction de règlement des litiges en cas de recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés. Dans cette hypothèse, en application des dispositions de l'arrêté portant manuel de procédure du CRD, ce dernier n'est soumis à aucun délai, sauf à respecter le principe du contradictoire et à statuer dans un délai raisonnable. Toujours est-il que les dénonciations doivent être traitées avec rigueur afin de donner plein effet à la disposition précitée. Avant la mise en œuvre de toute procédure d'enquête, l'ARMP vérifie si les faits dénoncés relèvent bien des procédures de la commande publique.

L'exemple qui suit illustre bien les solutions importantes auxquelles peut mener une dénonciation de faits avérés, en l'espèce de fausses attestations et de faux états financiers produits par une entreprise¹⁵.

¹⁵DECISION CRD N° 058/12/ARMP/CRD DU 31 mai 2012 statuant en Formation disciplinaire sur des faits reprochés à l'entreprise AFRIK Travaux relatifs à la production de faux documents dans le cadre de l'appel d'offres de l'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt public (AGETIP) ayant pour objet la construction d'un centre socio-culturel et l'extension du marché central de Marsassoum

Dans le cadre de l'appel d'offres ayant pour objet des travaux de construction et de réhabilitation de voiries dans la ville de Thiès, des indices d'irrégularités commises par l'entreprise AFRIK TRAVAUX, dans le cadre de l'appel d'offres dont objet rappelé ci-dessus, sont apparues. Après transmission de l'offre d'AFRIK TRAVAUX et instruction, ces indices ont été confortés et, mis au courant de cette situation, le Directeur Général de l'ARMP a saisi d'une dénonciation le Président du CRD qui a, à son tour, a saisi l'organe de règlement des différends siégeant en formation disciplinaire. AFRIK TRAVAUX a produit les attestations de bonne exécution de travaux prétendument délivrées par la Générale d'Entreprises.

L'ARMP a saisi d'une demande de confirmation, le Directeur général de la Générale d'Entreprises, et celui-ci a apporté la réponse suivante : « Suite à votre courrier référencé 000053/ARMP/CRD/PR/CE, nous vous confirmons que toutes les attestations produites sont fausses. Pire, certains de ces chantiers cités n'existent même pas dans les livres de la Générale d'Entreprises » ;

La dénonciation a indiqué aussi que la société AFRIK TRAVAUX a produit, en outre, des états financiers des exercices 2007, 2008 et 2009 prétendument certifiés par le cabinet d'expertise comptable et fiscale GAYE & Associés ;

Saisi par l'ARMP d'une demande de confirmation, le Directeur dudit cabinet, dans sa réponse a infirmé l'authenticité desdits documents. Dans le cadre de la mise en œuvre du principe du contradictoire, l'ARMP a procédé à l'audition de la Directrice générale de la société, laquelle a confirmé ces faits et l'existence de faux documents.

Sanction : En raison de ces circonstances, il a été prononcé l'exclusion d'AFRIK TRAVAUX des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée de dix (10) ans, en application de l'article 148 du Code des marchés publics sénégalais.

IX.3 La consignation

Le recours est présenté sous forme de « requête enregistrée au secrétariat du Comité de Règlement des Différends. Le requérant est tenu de verser à la Caisse de Dépôts et Consignations des frais de recours fixés à 50 000 F CFA. Une quittance lui est alors délivrée. La quittance est jointe à la requête ou au mémoire ». La consignation est reversée au requérant lorsque son recours est fondé.

L'absence de versement des frais est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de la requête.

IX.4 Les délais

La question de l'article 92 du CMP précise que : « la décision du Comité de Règlement des Différends en matière de passation des marchés doit être rendue dans les sept (7) jours ouvrables à compter de la réception des documents complémentaires demandés dans le cadre de l'instruction du recours, faute de quoi l'attribution du marché ne peut plus être suspendue ».

La question s'est posée de déterminer si le CRD pouvait statuer dans des délais aussi brefs, alors qu'il est saisi de recours nécessitant parfois des investigations complexes. De fait, la rédaction de l'article 92 du Code des marchés publics montre bien que la seule conséquence à tirer de cette disposition a trait à son effet sur la suspension de la procédure. Cette interprétation est confirmée par les dispositions combinées des articles 7 et 12 de l'arrêté portant manuel de procédure du CRD dans lesquelles il est bien indiqué que le CRD statue à titre provisoire dans ce délai de 7 jours, faute de quoi la suspension de la procédure devient caduque. Rien n'interdit donc au CRD après avoir prononcé la suspension dans le délai de 7 jours ouvrables à compter de la réception du recours de statuer au fond ultérieurement.

IX.5 Le Contrôle et les sanctions des irrégularités commises dans la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de service public

Assurer la transparence dans l'exécution des marchés publics et veiller à la régularité des procédures, tel est l'objectif du système de contrôle mis en place et des sanctions prévues par le Code des marchés publics et les autres textes applicables à cette catégorie de contrat public.

« Toute personne impliquée dans la passation des marchés publics pour le compte d'une Autorité contractante, d'un candidat à un marché ou à un autre titre, est tenue de respecter les règles d'éthique concernant en particulier l'absence de participation à toute pratique de corruption active ou passive et doit signer une déclaration écrite relative à cet engagement conformément à la réglementation applicable » dispose l'article 29 du Code des Obligations de l'Administration.

Cette disposition est complétée par celle de l'article 30 qui, en cas de non respect des règles relatives à la passation des marchés, donne pouvoir au Comité de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, de prononcer les sanctions suivantes :

- exclusion temporaire ou définitive de la commande publique ou pénalités pécuniaires à l'encontre les candidats aux appels publics à la concurrence ou des titulaires de marchés auteurs de fautes commises lors de la passation ou de l'exécution des marchés
- sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires ou agents publics, auteurs de fautes commises dans le cadre de la préparation, de la passation ou de l'exécution des marchés publics, délégations de service public ou contrats de partenariat.

En matière d'exclusion de la commande publique, il convient d'explicitier aux Autorités contractantes la « portée temporelle » d'une telle sanction, comme l'a eu à traiter le CRD dans un avis daté du 1er février 2012¹⁶.

Par mémoire en date du 27 décembre 2011, le Directeur de la Générale d'Entreprises et des Services (G.E.S) avait saisi le CRD d'une demande d'avis pour être édifié sur la situation des marchés pour lesquels sa société avait soumissionné avant la notification de la décision excluant celle-ci des marchés publics, délégation de services publics et contrat de partenariat lancés au Sénégal ainsi que dans tout autre Etat membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) pour une période d'un an.

Cette demande d'avis s'expliquait par le fait que le 16 juillet 2010, la GES avait été désigné par le Port Autonome de Dakar comme étant l'attributaire provisoire d'un marché relatif aux travaux d'entretien courant des installations ferroviaires en zones nord et sud sur l'emprise portuaire de Dakar. Le candidat EGT avait introduit un recours auprès du CRD pour contester cette attribution. Le CRD rendit la décision n° 108/10/ARMP/CRD du 18 août 2010, constatant que la société GES a produit une attestation de travaux similaires en date du 14/12/2009, portant le nom et la signature de la Société d'Exploitation ferroviaire des Industries chimiques du Sénégal (SEFICS) qui, en retour par courrier en date du 11 août 2010, a déclaré n'avoir jamais émis d'attestation au nom de GES dont elle ignorait d'ailleurs l'existence jusqu'à cette date. En réponse à ces faits, par décision n° 231/11/ARMP/CRD du 24 novembre 2011, la G.E.S fut donc sanctionné d'une exclusion pour une période d'une année.

Etant attributaire du marché lancé par le PAD, la G.E.S SARL voulait savoir si cette sanction du CRD s'applique aux appels d'offres pour lesquels elle avait pris part avant le 30 novembre 2011.

Selon le CRD, la décision de sanction disciplinaire du CRD étant un acte de portée individuelle, le point de départ de son entrée en vigueur est la date de sa notification au (x) mis en cause et qu'ainsi, ladite décision devient, en principe, opposable à partir de cette date et pour toute la durée de la sanction ;

¹⁶Avis n° 002/12/ARMP/CRD du 01 février 2012 du CRD statuant en Commission Litiges sur la saisine de la société G.E.S. SARL sur la portée de la sanction d'exclusion prononcée contre elle par le CRD de l'ARMP.

Considérant, toutefois, que l'article 43 du Code des Obligations de l'Administration dispose que « l'approbation par l'Autorité contractante compétente vaut conclusion du marché » **et que, par conséquent, les décisions de l'Autorité contractante, prises avant la réalisation de la formalité d'approbation, sont à titre provisoire et ne confèrent aucun droit acquis ;**

Qu'en considération de ce principe, les instructions aux soumissionnaires des dossiers-types rappellent, du reste, que l'Autorité contractante se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre, et d'annuler la procédure d'appel d'offres et d'écarter toutes les offres à tout moment avant l'attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des candidats ;

Que dès lors, une sanction d'exclusion, notifiée dans la phase d'attribution provisoire du marché, fait opposition à l'attribution définitive du marché au (x) mis en cause ;

Qu'en revanche, si la notification de la sanction intervient après l'approbation du marché par l'Autorité compétente, le titulaire ne peut se voir opposer la décision du CRD au nom du principe des droits acquis ».

Les Autorités contractantes peuvent donc bien être confrontées à une question d'effectivité d'une sanction frappant un soumissionnaire alors que celui-ci est désignée attributaire provisoire d'une procédure. Afin de ne commettre aucune mauvaise application du droit, ces Autorités contractantes sont invitées à situer dans le temps la date de notification de ladite sanction :

- si la sanction qui a été prononcée à l'occasion d'une procédure antérieure, a été effectivement notifiée avant l'approbation du marché, l'attribution provisoire au profit de l'entreprise concernée ne peut être prononcée. En effet, on ne peut pas attribuer un marché à un soumissionnaire alors que celui-ci est déjà frappé par une sanction devenue effective.
- Si, par contre, l'approbation a eu lieu alors que la sanction n'a pas encore été notifiée à l'entreprise, l'attribution provisoire devient définitive et il n'est pas question de revenir là-dessus.

Les sanctions prévues en matière de passation et d'exécution des marchés publics, peuvent viser aussi bien les actes que les personnes.

IX.5.1 Les sanctions visant les actes

Les sanctions visant les actes relatifs à la passation des marchés sont de deux ordres : les sanctions destinées à faire respecter la légalité des actes et celles visant à assurer la régularité de la procédure.

IX.5.1.1 Contrôle et sanctions de la légalité des actes en matière de marchés publics par le juge de l'excès de pouvoir

Le contrôle de la légalité effectué par le juge de l'excès de pouvoir porte sur le contrôle et la sanction de la conformité des actes administratifs à la loi et aux règlements. Il est exercé consécutivement à un recours en annulation devant le juge de l'excès de pouvoir. Celui-ci peut connaître notamment des actes unilatéraux détachables du marché.

Aux termes de l'article 140 du Code des Obligations de l'Administration, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge les actes détachables suivants :

- l'autorisation de contracter ;
- la décision de contracter ou de ne pas contracter ;
- l'opération d'attribution ;
- l'approbation du contrat.

Le recours est ouvert à tout candidat à une procédure de passation d'un marché et au représentant de l'Etat qui, en vertu des dispositions de l'article 246 du Code des collectivités locales, défère au juge de l'excès de pouvoir les actes mentionnés aux articles 243 et 244 dont les conventions relatives aux marchés ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel et commercial qu'il estime entachés d'illégalité.

Si l'acte détachable est le support nécessaire du contrat passé, le contrat passé en vertu de cet acte détachable est lui-même potentiellement entaché d'illégalité.

L'annulation de l'acte détachable peut en effet avoir pour conséquence la nullité du contrat passé lorsque cette nullité résulte d'une illégalité grave comme par exemple le défaut d'approbation ou de qualité de l'autorité signataire qui n'avait plus compétence pour signer le contrat.

La nullité du contrat peut également résulter d'un vice de forme ou de fond qui lui est propre.

Ainsi, en même temps que l'annulation de l'acte détachable, le requérant peut demander au juge d'enjoindre la sanction de cette nullité.

Toutefois, et indépendamment des recours pouvant viser la procédure d'attribution elle-même, l'article 31 du COA organise en cas de non respect des règles relatives à la passation des marchés, une procédure spéciale, déjà évoquée ci-dessus, de recours non juridictionnel devant un organe placé au sein de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, et qui est ouverte à toute personne qui a participé à une procédure de passation et n'a pas été désignée attributaire. Cette procédure permet la remise en cause de l'ensemble des actes préparatoires de la procédure jusqu'à la décision d'attribution.

IX.5.1.2 Contrôle et sanctions des irrégularités à la procédure de passation des marchés publics par le CRD

Les marchés étant des contrats administratifs, ils doivent respecter les principes liés à la liberté d'accès à la commande publique, à l'égalité de traitement des candidats, et à l'objectivité des procédures.

La procédure devant le CRD contribue à assurer le respect de ces principes. Elle est la voie la plus indiquée en raison de sa célérité, pour régler les contestations relatives à la régularité de la passation des marchés publics.

Aux termes de l'article 92 du Code des marchés publics, le CRD a pour mission principale de corriger les violations constatées ou d'empêcher que d'autres dommages causés aux intérêts concernés ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.

En effet, dès que le contrat est conclu et approuvé, même illégalement, le CRD n'est plus compétent à en connaître. Il appartient alors au juge du contrat que peut, du reste, saisir le CRD pour prononcer la nullité du marché illégalement conclu.

Toutefois, les délais minima prévus à l'article 85 du CMP pour la signature du marché permettent au CRD, une fois saisi d'ordonner la suspension de la procédure de passation jusqu'au prononcé de sa décision sur le litige comme prescrit à l'article 21 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.

Ainsi, lorsque le CRD relève un manquement aux règles applicables, il a la possibilité de décider conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté portant manuel de procédure du CRD de prendre :

- des mesures provisoires ;
- suspendre la procédure de passation du marché ;
- corriger les clauses à caractère discriminatoire ou contraires à la réglementation des marchés publics rendre des avis en guise de solution soumise aux parties dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges (il s'agit en fait de faire régulariser tout manquement affectant la procédure incriminée, tels que visés par exemple à l'article 24 du COA ou 92 du CMP).
- **des mesures définitives :**
- annuler les décisions résultant des irrégularités et violations de la réglementation constatées ;
- ordonner la suppression des dispositions discriminatoires.

Ainsi et à titre d'exemple l'annulation des décisions se rapportant à la procédure d'attribution et à la formation du contrat pourra résulter des irrégularités et violations suivantes :

- aux termes de l'article 6 du CMP, à l'exception des cas prévus à l'article 76, du Code des marchés publics, le marché doit avoir été préalablement inscrit dans les plans de passation ;
- l'autorisation préalable à laquelle la conclusion du marché est soumise n'a pas été obtenue (art. 18 du COA) ;
- le marché a été signé par une personne non habilitée à cet effet (article 27 du CMP) ;
- la convention définissant les rapports entre l'Autorité contractante et le Maître d'Ouvrage délégué ne prévoit pas les prescriptions relatives aux attributions confiées au maître d'ouvrage délégué, le mode de financement des fournitures, travaux ou services ainsi que les modes de décaissement des fonds nécessaires à l'exécution de la convention et les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par l'Autorité contractante aux différentes phases de l'opération ;
- les formalités de publicité prescrites et le principe de traitement égal des candidats à la commande publique n'ont pas été respectés.

Les marchés publics étant adossés aux règles de gestion des finances publiques, ils peuvent également donner lieu à des contrôles en matière de discipline budgétaire et financière par la Cour des comptes.

IX.5.1.3 Contrôle de la Cour des comptes

La Cour des comptes exerce un contrôle externe et a posteriori. Cet organe exerce trois compétences : le contrôle de l'exécution des lois de finances, le jugement des comptes des comptables publics et le contrôle du bon emploi des deniers de l'Etat. Les comptables publics sont tenus de produire leurs comptes conformément à la loi (reddition de comptes). Cette obligation pèse sur tous les organismes publics dotés de comptables publics. En matière de marchés publics, ce contrôle porte au plan juridictionnel sur le contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics, et au plan administratif, sur le bon emploi des deniers publics. Les différents contrôles de la Cour des comptes peuvent conduire à des sanctions personnelles prononcées contre les acheteurs publics.

IX.5.2 Le contrôle et les sanctions visant les personnes

IX.5.2.1 Contrôle et sanctions prononcées par le CRD

Lorsque les faits dénoncés ou déférés au CRD caractérisent des violations de la réglementation à la passation des marchés publics, le Président du CRD peut saisir soit la Commission Litiges, soit la Formation disciplinaire. Si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics, le Président du Comité saisit la Formation disciplinaire.

Celle-ci peut prononcer à l'encontre du candidat, soumissionnaire ou du titulaire de marchés, des sanctions sous la forme d'exclusion temporaire et de pénalités pécuniaires conformément aux dispositions des articles 23 du décret portant création de l'ARMP et 7 de l'arrêté portant manuel de procédure du CRD, lorsque celui-ci :

- a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
- a participé à des pratiques de collusion entre candidats afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels ou non concurrentiels, privant l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
- a influé sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon à bénéficier d'un avantage ;
- a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
- a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies.

Ces violations qui sont constatées par le CRD, sont sanctionnées par celui-ci sans préjudice de poursuites pénales contre le candidat, soumissionnaire ou le titulaire du marché incriminé et les fonctionnaires et agents publics impliqués.

Par ailleurs, et sans préjudice d'autres sanctions notamment pénales, les sanctions suivantes peuvent être prononcées et, selon les cas, de façon cumulative, à l'encontre de candidats reconnus coupables d'infractions à la réglementation des marchés publics :

- confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquels il a participé ;
- exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise contrevenante, ou dont celle-ci possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par le CRD.

Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, d'une délégation de service ou d'un contrat de partenariat, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou autres personnes morales de droit public peuvent également faire l'objet de sanctions disciplinaires et/ou de poursuites, soit devant les juridictions pénales soit devant la Chambre de discipline de la Cour des comptes.

IX. 5.2.2 Contrôle et sanctions par les juridictions judiciaires et administratives

IX. 5.2.2.a. Sanctions prononcées par les juridictions pénales

La violation des dispositions du Code des marchés publics ou d'autres textes relatifs à la commande publique peut être constitutive d'une infraction pénale. Ainsi, à toutes les étapes de la procédure de passation et d'exécution des marchés publics, les infractions suivantes peuvent être relevées et sanctionnées :

IX. 5.2.2.b. Les manquements commis lors de la passation de la commande publique

Il peut s'agir des délits suivants :

- l'octroi d'avantages injustifiés : ce délit constitue une atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité de traitement des candidats dans les marchés ;
- la prise illégale d'intérêt ; la prise illégale d'intérêts équivaut à la situation où une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public prend, reçoit ou conserve directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte (par exemple, la passation d'un marché public), en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.

C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'article 40-1 du CMP qui dispose que *«toute personne qui a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants un intérêt direct ou indirect, notamment en tant que dirigeant, associé ou employé, dans une entreprise candidate à un marché examné par la commission à laquelle elle appartient, doit en faire la déclaration, se retirer de la commission et s'abstenir de participer à toutes opérations d'attribution du marché considéré»*.

Ces conflits d'intérêts intéressent uniquement les membres de la Commission des marchés. C'est une règle qui est applicable à tout agent qui intervient dans la préparation, la passation, l'exécution, le contrôle et le paiement du marché.

- le faux et usage de faux ; le terme «*faux*» désigne juridiquement une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelques moyens que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression qui a pour objet ou qui peut avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. L'usage de faux est le fait de se servir de ces documents fallacieux. C'est l'exemple de l'établissement de fausses attestations ou de qualifications pour les entreprises de BTP en vue de leurs candidatures aux marchés publics de travaux. Il en est de même pour l'établissement de fausses factures sans aucune conformité avec la nature et l'ampleur des prestations réalisées par le titulaire du marché.

- la soustraction ou le détournement de biens : il s'agit de soustraction d'actes d'engagement destinée à fausser le jeu de la concurrence ou à d'actes tendant à minorer une dépense publique pour en détourner une partie, sous l'habillage de fausses factures.

- Les manquements aux règles d'exécution d'un marché public¹⁷

Il peut s'agir des délits suivants :

- le délit d'abus de biens sociaux ;
- le délit de recel.

- Les manquements commis lors des deux étapes de la procédure de conclusion d'un marché public

Il peut s'agir des délits suivants :

- la corruption passive ;
- le trafic d'influence.
- Les sanctions prononcées par les juridictions administratives

Conformément aux dispositions de l'article 33 du COA, les agents publics peuvent également être tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes.

IX. 5.2.3 Sanctions prononcées par la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes

En cas de faute de gestion ou de négligences graves commises dans les services, la Chambre de discipline budgétaire peut prononcer à l'encontre des fonctionnaires et agents publics des amendes et faire publier la décision au Journal officiel.

Ainsi, l'article 146 du CMP prévoit ainsi que :

Les agents de l'Etat et des autres personnes morales de droit public peuvent être déférés devant la Chambre de Discipline financière de la Cour des comptes, sans préjudice de poursuites pénales, pour avoir enfreint les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux marchés publics dans les cas suivants :

- a) ils ont procuré ou tenté de procurer un avantage anormal à un candidat ;
- b) ils sont intervenus à un stade quelconque dans l'attribution d'un marché, d'une délégation de service public à une entreprise dans laquelle ils ont pris ou conservé un intérêt ;
- c) ils ont fractionné des dépenses en vue d'échapper au mode de passation normalement applicable ou ont appliqué une procédure de passation sans l'accord requis ;
- d) ils ont passé un marché, une délégation de service public ou un contrat de partenariat avec un candidat exclu de la commande publique ou ont exécuté un marché ou contrat non approuvé par l'autorité compétente ;

¹⁷Cette division est contestable ; ces faits peuvent intervenir au moment de la passation

- e) ils ont manqué de manière répétée à l'obligation de planification et de publicité annuelle des marchés ;
- f) ils ont autorisé et ordonné des paiements après délivrance d'un titre de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestations incomplètes ou non conformes.

Toutefois, il convient de rappeler que le dispositif de la loi organique n° 2012-23 du 27-12-2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes élargit le champ d'actions à l'encontre des agents publics.

En effet, l'article 56 de cette loi précise que : « *Est déféré devant la Chambre de discipline financière, tout fonctionnaire civil, tout militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, tout membre du cabinet du Président de la République, du Président de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat, du Premier Ministre ou d'un ministre, tout agent d'une collectivité publique ou d'un établissement public, d'une société nationale, d'une société anonyme à participation publique majoritaire, d'une agence d'exécution ou structure administrative assimilée, d'une institution de sécurité sociale au sens de l'article 31 de et généralement, de tout organisme bénéficiant du concours financier de la puissance publique ou faisant appel à la générosité publique, toute personne investie d'un mandat public et toute personne ayant exercé, de fait, lesdites fonctions, à qui il est reproché un ou plusieurs faits énumérés à l'article 57 de la présente loi* ».

Aux termes de l'article 57, est punissable en matière de dépenses :

- 1) - le fait de n'avoir pas soumis à l'examen préalable des autorités habilitées à cet effet, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, un acte ayant pour effet d'engager une dépense ;
- 2) - le fait d'avoir imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense ;
- 3) le fait d'avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant la comptabilité de matières ;
- 4) - le fait d'avoir passé outre au refus de visa d'une proposition d'engagement de dépenses, excepté dans le cas où l'avis conforme du ministre chargé des finances a été obtenu préalablement par écrit ;
- 5) - le fait d'avoir engagé des dépenses sans avoir reçu à cet effet délégation de signature ;
- 6) - le fait d'avoir produit, à l'appui ou à l'occasion de ses liquidations, de fausses certifications ;
- 7) - le fait d'avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant les marchés ou conventions d'un organisme soumis au contrôle de la Cour ;

Sont notamment considérées comme infraction à la réglementation des marchés ou conventions :

- a) le fait d'avoir procuré ou tenté de procurer à un cocontractant de l'administration ou d'un organisme soumis au contrôle de la Cour, un bénéfice anormal, à dire d'expert ;
- b) le fait de n'avoir pas assuré une publicité suffisante aux opérations dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;
- c) le fait de n'avoir pas fait appel à la concurrence dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;
- d) le fait d'avoir procuré ou tenté de procurer un avantage anormal à un candidat à un marché public ;
- e) le fait d'être intervenu à un stade quelconque dans l'attribution d'un marché, d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat avec une entreprise dans laquelle l'agent concerné a pris ou conservé un intérêt ;
- f) le fait d'avoir fractionné des dépenses en vue de soustraire au mode de passation normalement applicable ou d'avoir appliqué une procédure de passation de marché sans l'accord requis ;
- g) le fait d'avoir passé un marché public, une délégation de service public ou un contrat de partenariat avec un candidat exclus des commandes publiques ou d'avoir exécuté un marché ou un contrat non approuvé par l'autorité compétente ;
- h) le fait d'avoir manqué à l'obligation de planification et de publicité annuelle des marchés publics ;
- i) le fait d'avoir autorisé et ordonné les paiements après délivrance d'un titre de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestations incomplètes ou non conformes.

8) le fait de s'être livré, dans l'exercice de ses fonctions, à des faits caractérisés créant un état de gaspillage ;

Sont notamment considérés comme réalisant un état de gaspillage :

- a) les transactions trop onéreuses pour la collectivité intéressée, en matière de commande directe, de marché ou d'acquisition immobilière ;
- b) les stipulations de qualité ou de fabrication qui, sans être requises par les conditions d'utilisation des travaux ou de fournitures, seraient de nature à accroître le montant de la dépense ;
- c) les dépenses en épuisement de crédits ;

9) - le fait d'avoir enfreint les règles régissant l'exécution des dépenses ;

10) - le fait d'avoir négligé, en sa qualité de chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrôler les actes de dépenses de ses subordonnés ;

11) - le fait d'avoir omis sciemment de souscrire les déclarations qu'ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales et sociales conformément aux codes en vigueur ou d'avoir fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes, et de façon générale,

12) - le fait d'avoir dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui ou à soi-même, directement ou indirectement, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé.

En matière de sanctions, l'article 59 précise que « *la chambre applique à titre de sanction une amende dont le minimum ne peut être inférieur à 100.000 francs CFA et dont le maximum pourra atteindre le double du traitement ou salaire brut annuel alloué à l'auteur des faits à la date à laquelle ceux-ci ont été commis* ».

S'agissant de l'engagement des poursuites, l'article 67 indique que la « *Chambre ne peut être saisie quatre années révolues après le jour de la découverte des faits de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues en matière de discipline financière* ».

Les poursuites devant la Chambre de discipline financière ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale ou disciplinaire de droit commun.



ANNEXE : LISTE AVIS ET DECISIONS DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS CITES DANS LE GUIDE

1- Avis n° 008/13/ARMP/CRD du 27 novembre 2013 du CRD statuant en Commission Litiges sur la soumission de la procédure d'acquisition d'œuvres d'art aux règles du Code des marchés publics

2- Avis n° 001/13/ARMP/CRD du 27 mars 2013 du CRD statuant en Commission Litiges sur la saisine de la Direction des services administratif et financier sur ordre du Directeur général de l'ARMP sur l'interprétation de la disposition 3.4.c).iii du Code des marchés publics

3- Avis N° 001/09/ARMP/CRD DU 26 janvier 2009 du CRD statuant en Commission Litiges sur la saisine de la DCMP relative à l'application du Code des marchés publics aux marchés relatifs à l'acquisition ou à la location de terrains, bâtiments existants ou autres biens immeubles

4- Avis n° 005/12/ARMP/CRD du 03 avril 2012 du CRD statuant en Commission Litiges sur la saisine de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes concernant la soumission d'un contrat de sponsoring au Code des marchés publics

5- Avis n° 017/10/ARMP/CRD du 11 août 2010 du CRD statuant en Commission Litiges sur la saisine de la société Universal Auto dénonçant la pratique qui consiste à exiger des candidats aux marchés de fourniture de véhicules neufs, l'autorisation du constructeur comme enfreignant les règles de la concurrence en ce qu'elle exclue les vendeurs d'automobiles indépendants du réseau des constructeurs

6- Avis n° 002/14/ARMP/CRD DU 19 février 2014 du Comité de Règlement des différends statuant en Commission Litiges sur la demande de la société SARRE-CONS relative à l'interprétation du critère « disposer d'un service après-vente et d'un magasin de pièces de rechange » dans les marchés publics d'acquisition de véhicules

7- Avis n° 13/12/ARMP/CRD du 17 octobre 2012 du CRD statuant en Commission litiges sur la saisine de la commune de Kaffrine concernant le refus du Pôle régional de Contrôle des Marchés publics de Kaolack d'immatriculer des marchés

8- Avis N° 005/13/ARMP/CRD du 02 octobre 2013 du CRD statuant en commission Litiges sur la saisine du centre des œuvres universitaires de Saint-Louis concernant l'exécution d'un marché de clientèle

9- Avis n°006/13/ARMP/CRD du 02 octobre 201du CRD statuant en Commission Litiges sur la demande de

la Direction du Matériel et du Transit administratif relative à la possibilité d'utiliser des informations fournies par les services du ministère du commerce comme base de jugement des offres anormalement basses

10- Avis n°..../09/ARMP/CRD DU 25 mars 2009 du Comité de Règlement des Différends statuant en Commission Litiges sur la demande d'avis de la Direction générale de la Construction des Bâtiments et Edifices publics portant sur la conduite à tenir suite à la décision de la DCMP de soumettre à l'approbation du Ministre de l'Economie et des Finances l'avenant du marché portant sur les travaux de construction d'un village artisanal à Mbour

11- Avis n° 004/09/ARMP/CRD du 25 mars 2009 du CRD statuant en Commission Litiges sur la demande de la Direction centrale des Marchés publics portant sur la détermination de l'autorité habilitée à certifier la conformité de la copie d'un marché délivrée pour nantissement

12- Avis n° 015/11/ARMP/CRD du 26 octobre 2011 du CRD en Commission Litiges sur la demande d'autorisation introduite par AGEROUTE SENEGAL pour la prise en charge sous forme d'avenant, le préjudice financier subi par le groupement AREZKI/GREENLINE suite à l'augmentation des prix du gasoil, du bitume et du ciment dans le cadre de l'exécution des travaux d'aménagement de la route LABE- SERIBA- MEDINA GOUNASS- TAMBACOUNDA et de facilitation du transport sur le corridor CONAKRY/DAKAR (tronçon Médina Gounass- frontière Guinée), subséquemment à l'avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP)

13- Avis n° 008/11/ARMP/CRD du 04 mai 2011 du CRD statuant en Commission Litiges sur la demande d'avis de la Direction centrale des Marchés publics relative à la détermination de l'autorité compétente pour résilier un marché

14- DECISION CRD N° 058/12/ARMP/CRD du 31 mai 2012 statuant en Formation disciplinaire sur des faits reprochés à l'entreprise AFRIK travaux relatifs à la production de faux documents dans le cadre de l'appel d'offres de l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public (AGETIP) ayant pour objet la construction d'un centre socio-culturel et l'extension du marché central de MARSASSOUM

15- Avis n° 002/12/ARMP/CRD du 01 février 2012 du CRD statuant en Commission Litiges sur la saisine de la société G.E.S. SARL sur la portée de la sanction d'exclusion prononcée contre elle par le CRD de l'ARMP.

Achévé d'imprimer sur les presses de l'Imprimerie Futures Printing Services
Août 2018



■ Autorité de Régulation des Marchés publics ■